

리담변리사학원

변호사시험 지적재산권법

기출문제와 해설 · 특허법

제1회 ~ 제15회

2012 ~ 2026

일러두기

1. 이 책의 구성

제1회부터 제15회까지의 변호사시험 지적재산권법 **제1문(특허법)**을 회차별로 한 장(章)씩 수록하였다. 각 장은 **문제 원문**과 **해설**로 이루어지며, 해설은 설문 순서를 따른다. 제2문(저작권법)은 수록하지 않았다.

2. 적용 법령

기출문제라도 **출제 당시의 법이 아니라 현행법을 적용**하여 풀이하였다. 수험생이 대비하는 시험이 현행 법으로 출제되기 때문이다. 따라서 **부칙(시행일·적용례·경과조치)은 다루지 않는다**. 발문이 구법 조문이나 용어를 인용하는 경우에만 현행 조문과의 대응관계를 밝혔다. 조문은 **2025. 11. 11. 시행 특허법**을 기준으로 하였다.

3. 표기 규칙

- **法 29① I** = 특허법 제29조 제1항 제1호. 다른 법률은 **民訴法·發振法**과 같이 법률명을 앞에 붙인다.
- 조문 가지번호는 **제99조의2**와 같이 적는다.
- 정의는 「」 안에 넣고, 요건은 i)·ii)로, 판단 항목은 I·II로 구분한다.
- 판례는 **대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체**와 같이 선고일과 사건번호를 함께 적는다.

4. 인용의 원칙

본문에 적은 **사건번호는 실재가 확인된 것만** 인용하였다. 확인 경로는 학원 판례 데이터베이스(cases·case_lower_courts), 리담특허법 교재, 국가법령정보센터 네 곳이며, 어느 곳에서도 확인되지 않은 번호는 적지 않고 사건번호 없이 법리만 서술하였다. 법리 서술은 교재의 해당 절을 통독하고 그 체계와 항목 구분을 따랐다.

5. 편집상의 표시

- ★ 는 그 설문의 배점이 갈리는 핵심 논점을 가리킨다.
- 회색 상자는 **사실관계**, 밑줄 친 인용 상자는 **답안 작성상의 유의점**이다.
- 각 장 끝의 **집필 근거**는 그 해설이 어느 교재 절과 조문에 기대고 있는지를 밝힌 것이다.

차례

제1회	2012	1
B+C+D+E의 침해 여부 · A+B+C'+D의 침해 여부 · 문제가 되는 특허요건 · 구성의 곤란성과 효과의 현저성 · ...		
제2회	2013	10
甲의 발명이 특허대상이 되는지 · 신규성과 진보성 · 乙과 丙의 분산 실시 · 부정 · ...		
제3회	2014	20
乙의 권리회복 조치 · 특허를 받을 수 있는 권리가 甲·乙의 공유인지 · 제44조 위반 (★) · 신규성 상실의 법리 · ...		
제4회	2015	30
乙 출원발명의 발명 성립성 · 특허를 받지 못한 乙이 실시하기 위한 조치 · 甲의 특허발명과 乙의 특허발명의 관계 · 甲이 허락하지 않을 때 乙이 취할 수 있는 조치 · ...		
제5회	2016	37
청색LED 발명의 특허요건 · 공동발명의 요건 · 공동발명일 때 乙의 동의 없는 지분 양도 가부 · 乙이 자기 명의로 적법하게 특허를 취득하기 위한 조치 · ...		
제6회	2017	44
출원공개 후 설정등록 전 실시에 대한 권리 · 설정등록 이후 실시에 대한 민·형사적 구제수단 · 특허무효사유로서 신규성·진보성 · 침해소송에서 甲이 특허무효를 주장할 수 있는지 · ...		
제7회	2018	53
甲이 乙과의 관계에서 적법하게 실시하기 위한 조치 · 丁의 반박("乙이 아닌 甲은 침해금지를 주장할 수 없다")의 타당성 · 甲이 丙을 상대로 소송상 주장할 수 있는 청구권 · 甲이 청구할 수 있는 특허심판원 심판절차 · ...		
제8회	2019	60
신규성 상실의 사유 · 비공개 시험 참가자의 무단 공개 · 언론에 공개한 경우 · 丙의 무단 출원 · ...		
제9회	2020	68
진보성의 의의 · 네 요소를 종합한 기술 A의 진보성 판단 · 무효의 항변과 권리남용의 항변 · 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자 · ...		
제10회	2021	76
미용을 위한 수술방법의 신규성과 공지예외 · 치료 목적 상안검 수술방법의 산업상 이용가능성과 法 32 · 도서관 창고에 보관된 박사학위논문과 신규성 · 수술용 바늘(물건발명)의 특허요건		
제11회	2022	82
발명 Y의 신규성·진보성 · 법원이 무효 주장을 직접 심리·판단할 수 있는지 · 등록주의와 권리범위 · 종래부터 권리범위가 부정된다 · ...		
제12회	2023	89

A 예방백신의 신규성·진보성 · B 치료방법의 산업상 이용가능성과 法 32 · 乙회사가 특허를 받을 수 있는지 · 法 99의2에 따른 특허권의 이전청구 · ...

제13회	2024	96
구성요소완비의 원칙과 甲의 침해 주장 · 설정등록을 하지 않은 전용실시권자의 침해금지청구 · 균등침해와 甲의 丁에 대한 침해금지청구		

제14회	2025	102
발명자의 확정 · 특허를 받을 수 있는 자, 권리의 성질과 양도 요건 · 신규성 위반인지, 공지예외에 해당하는지 · 침해에 대하여 취할 수 있는 조치 · ...		

제15회	2026	109
신규성 요건의 충족 여부 · 진보성 요건의 충족 여부 · 상업적 성공의 고려 가부 · 진보성은 구성과 효과로 판단한다 · ...		

CHAPTER 01

제1회 변호사시험 · 특허법

2012년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 5개

문 제

갑은, 렌즈부(A), 필름부(B), 발광부(플래시)(C) 및 본체부(D)로 구성된 카메라(이하, ‘본건 카메라’)를 발명하여 A+B+C+D로 구성된 카메라 제품에 대한 특허(이하, ‘본건 특허’)를 등록하였다. 본건 특허의 A, B, C 및 D는 모두 필수구성요소이다.

1. 을은 아래와 같이 두 가지 종류의 카메라 제품을 제조, 판매하고 있다. 을의 아래 각 행위가 특허법상 특허침해행위를 구성하는지를 설명하시오(단, 본건 특허는 유효하고, 본건 특허의 등록 후 을이 각 카메라를 제조, 판매하기 시작한 것으로 전제함).
 - (1) 을은, 본건 특허와 동일한 필름부(B), 발광부(플래시)(C) 및 본체부(D)로 구성되고, 전혀 다른 형태의 렌즈부(E)로 구성된 카메라(B+C+D+E)를 제조, 판매하고 있다.(15점)
 - (2) 을은, 본건 특허의 렌즈부(A), 필름부(B), 본체부(D)는 동일하게 구성하되, 본건 특허의 발광부(플래시)(C) 구성을 외부에 항상 노출되어 있는 형태의 외장형 발광부(플래시)(C')로 변경한 카메라(A+B+C'+D)를 제조, 판매하고 있다.(본건 특허의 발광부(플래시)(C)는 카메라 작동시 플래시가 필요한 때를 인식하여 플래시 앞커버가 자동적으로 열려 플래시가 몸체 안에서 밖으로 나와 작동이 되는 형태의 내장형 플래시임)(20점)
 2. 위 1.의 (2)에서 갑이 을을 상대로 특허권침해금지 청구소송을 제기함에 따라 을은 본건 특허 관련 분야 기술을 조사하게 되었는데, 그 과정에서 본건 특허의 A, B 및 D를 모두 구비한 비교대상발명 1(A+B+D)과 본건 특허의 발광부(플래시)(C)와 동일한 비교대상발명 2(C)의 각 문헌이 본건 특허의 출원일 이전에 공개되어 있음을 확인하게 되었다.(단, 비교대상발명 1과 비교대상발명 2를 결합하는 것에 특별한 어려움이 없다고 전제함)
 - (1) 위 사안에서 문제가 될 수 있는 본건 특허의 특허요건에 대하여 설명하시오.(15점)
 - (2) 을이 본건 특허에 대한 등록무효심판을 제기하여 특허심판원에서 등록무효심결이 있었으나, 위 등록무효심결에 대한 취소소송이 특허법원에 계속 중에 있어 본건 특허의 등록이 유지되고 있다고 가정할 경우, 위 특허권침해금지 청구소송의 변론 과정에서 위 특허요건과 관련하여 을이 제기할 수 있는 항변에 대하여 설명하시오.(10점)
 3. 필름 제조, 판매업자인 병은 본건 카메라용 필름을 제조, 판매하고 있다. 병의 필름 제조, 판매 행위가 특허법상 특허침해행위를 구성하는지를 설명하시오.(단, 본건 특허는 유효하고, 본건 특허의 등록 후 병이 본건 카메라용 필름을 제조, 판매하기 시작한 것으로 전제함)(20점)
- 본건 특허의 필름부(B)는, 본건 특허의 본질적인 구성요소로서 본건 특허의 필름부의 형태에 맞는 필름은 본건 카메라의 필름으로만 사용될 수 있어 다른 카메라 제품의 필름 용도로는 전혀 사용되지

아니하며 일반적으로 쉽게 구할 수 없고, 갑이 본건 카메라를 판매하기 시작할 때부터 위 필름의 교체가 예정되어 있었으며, 갑은 본건 카메라와 별도로 본건 카메라용 필름을 제조, 판매하여 왔다.

해 설

배점 80점 · 설문 5개(15 · 20 · 15 · 10 · 20). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 甲은 렌즈부(A)·필름부(B)·발광부(C)·본체부(D)로 구성된 카메라 A+B+C+D에 대하여 특허를 등록하였고 A~D는 모두 필수구성요소다. (1) 乙은 A를 전혀 다른 형태의 렌즈부 E로 바꾼 B+C+D+E를 제조·판매한다. (2) 乙은 내장형 플래시 C를 외장형 플래시 C'로 바꾼 A+B+C'+D를 제조·판매한다. (3) 乙은 출원일 이전에 공개된 비교대상발명 1(A+B+D)과 비교대상발명 2(C)를 찾아냈고, 두 문헌의 결합에 특별한 어려움이 없다. (4) 丙은 본건 카메라 전용 필름을 제조·판매한다.

문제 구조를 먼저 읽을 것 — 설문 2는 "설문 1의 (2)에서 甲이 乙을 상대로 침해금지청구 소송을 제기함에 따라"로 시작합니다. 설문 1-(2)에서 침해를 부정하면 설문 2가 성립하지 않습니다. 곧 출제자는 1-(2)를 균등침해 긍정으로 설계해 두고, 그 위에 무효항변을 얹는 2단 구조를 만든 것입니다. 균등 요건을 검토한 끝에 부정으로 결론짓는 답안은 45점(20+15+10)짜리 흐름 전체와 어긋납니다.

설문 1-(1) — B+C+D+E의 침해 여부 (15점)

I. 문언침해의 성부

「문언침해」란 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우를 말하고, 그 판단은 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)에 따른다. 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것이 아니므로, 확인대상발명이 필수적 구성요소 중 일부만을 갖추고 나머지가 결여된 경우에는 원칙적으로 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351).

사안의 乙 제품은 B·C·D를 갖추었으나 A를 결여하였다. 문언침해가 아니다.

II. 균등침해의 성부

1. 요건

특허발명이 A+B+C이고 제3자가 A+B'+C를 실시하는 경우 균등침해가 성립하려면 i) B를 B'로 변경하여도 과제의 해결원리가 동일하고, ii) 그 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) 그 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도이고, iv) 특별한 사정이 없어야 한다. 여기서 「특별한 사정」이란 i) 변경된 구성이 출원 시 이미 공지되었거나 공지기술로부터 쉽게

발명할 수 있었던 기술에 해당하는 경우, ii) 출원절차를 통하여 그 구성이 청구범위로부터 **의식적으로 제외**된 경우를 말한다.

2. 사안의 적용

발문은 E를 「**전혀 다른 형태의 렌즈부**」라고 명시하였다. 이는 A와 E 사이에 형태상의 차이가 있다는 데 그치지 않고, **A를 E로 바꾸는 것이 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도의 변경이 아님**을 전제한 서술로 읽어야 한다. 그렇다면 균등침해의 셋째 요건(변경의 용이성)이 충족되지 않는다. 나아가 렌즈부는 카메라의 결상(結像)을 담당하는 부분으로서 그 형태가 전혀 다르다면 **과제의 해결원리가 동일하다고 보기도 어렵고**, 그로 인한 작용효과가 실질적으로 동일하다고 단정할 수도 없다.

Ⅲ. 생략침해·불완전이용침해로 구성할 수 있는지

A를 결여한 실시라는 점에 착안하여 생략침해를 논할 여지가 있으나, 대법원은 **특허발명의 모든 구성 요소는 필수적이며 침해가 성립하려면 모든 구성요소가 갖추어져야 한다**는 구성요소 완비의 원칙에 서 있고(대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617; 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351), 이 입장에 따르면 생략침해·불완전이용침해는 인정될 수 없다. 더구나 사안은 A를 단순히 **뺀 것이 아니라 E로 대체한 것**이므로 생략발명의 문제도 아니다.

IV. 결론

乙의 B+C+D+E 제조·판매는 본건 특허권의 침해가 아니다.

설문 1-(2) — A+B+C'+D의 침해 여부 (20점)

I. 문언침해의 성부

乙 제품은 A·B·D를 그대로 갖추었으나 **C를 C'로 변경**하였다. 청구항의 구성요소 전부를 실시한 것이 아니므로 문언침해는 아니다. 균등침해 여부가 이 설문의 전부다.

Ⅱ. 균등침해의 요건별 검토

1. 과제 해결원리의 동일성

본건 특허의 발광부 C는 플래시가 필요한 때를 인식하여 앞커버가 자동으로 열리고 플래시가 몸체 밖으로 나와 작동하는 내장형이고, 乙의 C'는 항상 외부에 노출되어 있는 외장형이다.

여기서 판단의 기준은 「**발광부를 어떤 방식으로 수납·노출시키는가**」가 본건 발명의 과제 해결원리 그 자체인이다. 본건 특허의 청구항은 **A+B+C+D로 구성된 카메라**이고, 발명의 과제 해결원리는 **렌즈부·필름부·발광부·본체부를 결합하여 촬영에 필요한 광량을 확보하는 카메라를 구성하는 데** 있다고 볼 수 있다. 내장형이나 외장형이나는 발광부를 본체에 배치하는 방식의 차이에 지나지 않고 **촬영 시 필요한 광을 공급한다는 발광부의 기능 자체는 그대로**이므로, 과제의 해결원리는 동일하다고 볼 수 있다.

2. 작용효과의 실질적 동일성

C' 역시 촬영 시 플래시를 발광시켜 광량을 보충한다는 **동일한 작용효과**를 나타낸다. 내장형이 휴대 시 돌출을 없애고 렌즈 오염을 줄이는 등의 부수적 이점을 가질 수는 있으나, 이는 **발명 전체가 목적인 작용효과에 실질적 차이를 가져오는 정도**라고 보기 어렵다.

3. 변경의 용이성

플래시를 몸체에 내장하는 방식과 외부에 노출시키는 방식은 카메라 분야에서 널리 알려진 **설계상의 배치 방식**이다. 통상의 기술자라면 내장형 발광부를 외장형으로 바꾸는 것을 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다.

4. 특별한 사정의 부존재

기록상 C'가 출원 시 이미 공지되었다거나 출원경과에서 외장형이 의식적으로 제외되었다는 사정은 나타나 있지 않다. 다만 이 요건은 소송에서 乙이 다룰 여지가 있는 부분이고, 실제로 설문 2에서 乙은 이 방향이 아니라 **본건 특허 자체의 진보성**을 다투게 된다.

Ⅲ. 결론

네 요건이 모두 충족되므로 乙의 A+B+C'+D 제조·판매는 본건 특허권의 **균등침해**에 해당한다.

답안 작성 요령 — (1)과 (2)는 결론이 같리는 한 쌍이다. (1)에서 균등의 법리를 세워 두고 (2)에서 요건별로 포섭하되, 왜 A→E는 균등이 아니고 C→C'는 균등인지를 발문이 준 표현("전혀 다른 형태" vs "외부에 항상 노출되어 있는 형태")에 근거하여 대비시켜야 한다.

설문 2-(1) — 문제가 되는 특허요건 (15점)

I. 신규성이 아니라 진보성이다 (★)

이 설문의 첫 관문은 **신규성(法 29①)**과 **진보성(法 29②)**의 구별이다.

- **신규성** — 청구항에 기재된 발명을 하나의 공지기술과 대비하여 동일성을 판단한다. 복수의 공지기술을 조합하여 대비하여서는 아니 된다.
- **진보성** — 둘 이상의 인용대상을 상호 조합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단한다는 점에서 신규성과 다르다.

사안에서 비교대상발명 1은 A+B+D, 비교대상발명 2는 C이고, 어느 하나만으로는 **본건 특허 A+B+C+D와 동일하지 않다**. 따라서 **신규성은 부정되지 않는다**. 두 문헌을 조합해야 비로소 A+B+C+D에 이르므로, 문제되는 것은 **진보성**이다.

II. 진보성의 의의와 판단기준

「발명의 진보성」이란 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제29조 제1항 각 호의 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것을 말한다(法 29②). 진보성 없는 발명에 특허를 허여하면 i) 특허권의 난립으로 분쟁을 유발하고 ii) 모방 경향을 조장하여 발명의 질을 떨어뜨리므로, 공지기술보다 비약적인 발명에만 특허를 허여하는 것이다.

- **주체적 기준** — 심사관·심판관·법관이 통상의 기술자의 입장에서 판단한다.
- **객체적 기준** — 청구항에 기재된 발명을 공지기술과 대비하며, **둘 이상의 인용대상을 조합**할 수 있다. 조합의 용이 여부는 i) 통상의 기술자가 결합할 가능성, ii) 인용대상의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지, iii) 결합을 관련지를 합리적 근거가 있는지를 고려한다.
- **시기적 기준** — 특허출원 시를 기준으로 한다.
- **지역적 기준** — 국내 또는 국외(국제주의).

III. 판단방법 — 구성의 곤란성과 효과의 현저성

가장 가까운 인용대상(주선행발명)을 선택하여 청구항 발명과 대비해 차이점을 파악한 뒤, 그 차이에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지를 다른 인용대상·기술상식·경험칙에 의하여 판단한다. 구체적으로는 **구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작**하여 종합적으로 판단한다.

특히 **사후적 고찰(ex post facto)**은 금지된다. 해당 특허의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 쉽게 이끌어낼 수 있는 경우가 많으므로, 출원 전의 상태로 돌아가 판단하여야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

IV. 사안의 해결

- 주선행발명을 비교대상발명 1(A+B+D)로 삼으면 본건 특허와의 차이는 **구성요소 C의 유무**뿐 이고, 그 C는 비교대상발명 2에 **동일하게** 개시되어 있다.
- 발문은 「**두 발명을 결합하는 것에 특별한 어려움이 없다**」고 전제하였다. 결합의 용이성이 주어진 이상 **구성의 곤란성이 인정되지 않는다**.
- 두 구성을 결합한 것 이상의 **이질적이거나 현저하게 우수한 효과가 나타난다**는 사정도 보이지 않으므로 효과의 현저성도 인정되지 않는다.

따라서 본건 특허는 진보성이 부정되어 특허무효사유(法 133① I)에 해당한다.

설문 2-(2) — 무효심결 확정 전 乙의 항변 (10점)

I. 문제의 상황

특허무효심결이 있었으나 그 취소소송이 특허법원에 계속 중이어서 **아직 확정되지 않았고** 본건 특허의 **등록은 유지**되고 있다. 무효심결이 확정되어야 특허권은 소급하여 소멸하므로(法 133③), 현재로서는

특허권이 유효하게 존속한다. 이 상태에서 침해금지청구소송의 변론 과정에 乙이 제기할 수 있는 항변이 문제된다.

Ⅱ. 권리남용의 항변 (★ 이 설문의 핵심)

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 "특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다"고 하고, 나아가 "특허권 침해소송을 담당하는 법원으로서도 그러한 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다"고 판시하였다.

이 판결의 두 가지 의의는 i) 무효심결 확정 전이라도 특별한 사정이 없는 한 권리행사를 제한한다는 점, ii) 침해소송 법원이 진보성 위반 여부를 심리·판단할 수 있다는 점이다. 여기서 「특별한 사정」이란 무효사유가 존재하더라도 정정심판·정정청구에 의하여 그 무효사유를 극복할 수 있는 사정을 말한다.

사안에의 적용 — 앞서 본 것처럼 본건 특허는 비교대상발명 1·2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. 더욱이 특허심판원에서 이미 등록무효심결까지 내려진 상태이므로 「무효로 될 것이 명백한 경우」에 해당한다고 볼 유력한 사정이 있다. 甲이 정정에 의하여 무효사유를 극복할 수 있다는 특별한 사정이 없는 한, 乙은 甲의 침해금지청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 항변할 수 있다.

Ⅲ. 자유기술의 항변

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않는다. 이를 이유로 하는 항변이 자유기술의 항변이다.

권리남용의 항변과 비교하면 판단대상이 다르다.

	특허권 하자의 항변(무효의 항변)·권리남용의 항변	자유기술의 항변
판단대상	공지기술 vs 특허발명	공지기술 vs 확인대상발명
특허의 권리범위	부정하거나 권리행사를 제한	권리범위 자체는 언급하지 않음

자유기술의 항변은 특허권의 권리범위 자체를 부정하는 것이 아니라, 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 자유기술의 영역까지 권리범위가 확장되는 것을 제한하기 위한 것이다. 또한 확인대상발명이 특허발명의 모든 구성요소를 그대로 갖춘 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366).

사안에의 적용 — 乙의 확인대상발명 A+B+C+D가 비교대상발명 1·2로부터 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있는 것이라면 자유기술의 항변이 가능하다. 다만 자유기술의 항변에서 확인대상발명은 특허발명과 대응되는 구성만으로 한정할 것이 아니라 특정된 구성 전체를 두고 판단하여야 하므로(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64), 甲이 확인대상발명을 구체적으로 특정할수록 乙의 항변은 어려워진다.

IV. 소송절차의 중지신청

법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 **특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지**할 수 있다(法 164②). 乙은 특허법원에 계속 중인 심결취소소송의 결과가 나올 때까지 침해소송의 중지를 신청할 수 있다. **다만 중지 여부는 법원의 재량**이므로 항변과 병행하여야 한다.

V. 결론

乙은 ① **권리남용의 항변(주된 항변)** ② **자유기술의 항변** ③ **소송절차 중지신청**을 할 수 있고, 그 중 **권리남용의 항변이 이 사안에 가장 직접적**이다. 만일 그 사이 甲이 승소판결을 받아 확정되더라도, 후에 무효심결이 확정되면 乙은 **재심의 소**를 제기할 수 있다(民訴法 451①).

설문 3 — 丙의 필름 제조·판매 (20점)

I. 직접침해의 성부

본건 특허는 **A+B+C+D로 구성된 카메라**라는 물건발명이다. 丙은 **필름부(B)에 해당하는 필름만을 제조·판매**할 뿐 A+B+C+D를 갖춘 카메라를 생산·양도하는 것이 아니므로, 구성요소완비의 원칙상 **직접침해가 아니다**.

II. 간접침해의 성부 (★)

1. 근거와 취지

특허가 물건의 발명인 경우 **그 물건의 생산에만 사용하는 물건**을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 **업으로서** 하면 특허권을 침해한 것으로 본다(法 127 I). 이는 현재 침해에 이르지 않는 않았으나 **그대로 방치하면 침해로 이어질 개연성이 높은 예비적 행위**에 대하여, 구성요소완비의 원칙만 고수하면 책임을 물을 수 없게 되어 특허권의 효력이 현저히 감소하는 것을 막기 위한 것이다.

2. 「생산」에 해당하는지 — 부품 교체와 수리·재생산의 구별

여기서 먼저 넘어야 할 문제는, **정당하게 카메라를 구입한 사용자가 필름을 갈아 끼우는 것이 특허발명인 물건의 「사용」인가 「생산」인가**이다. 특허권자가 판매한 특허제품에 대해서는 권리가 소진되어 그 사용에는 효력이 미치지 않으므로, 필름 교체가 단순한 **수리·사용의 일환**에 그친다면 애초에 직접침해로 이어질 여지가 없어 간접침해의 전제가 흔들린다.

「생산」이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 말하며 가공·조립·수리도 포함될 수 있다. 부품 교체가 생산인지에 관하여 판례는 **비소모품과 소모품을 나누어** 판단한다. 마모되거나 소진되어 자주 교체하여야 하는 **소모품**의 경우에는 다음 네 요건을 모두 갖춘 때에 생산에 해당한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580).

소모품 교체가 「생산」이 되기 위한 요건	사안
i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것	필름부 B는 본건 특허의 본질적 구성요소 ○
ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것	본건 카메라 필름은 쉽게 구할 수 없음 ○
iii) 물건 구입 시 이미 그 교체가 예정되어 있었을 것	판매 시작 때부터 교체가 예정 ○
iv) 특허권자 측이 그 부품을 따로 제조·판매하고 있을 것	甲이 별도로 제조·판매 ○

발문의 마지막 문단은 이 네 요건을 그대로 옮겨 놓은 것이다. **네 요건이 모두 충족되므로 필름 교체는 「생산」에 해당한다.** 완제품 특허권자가 부품시장(after market)에서 과도한 독점권을 갖는 것을 막기 위하여 소모품의 경우 요건을 엄격히 요구하는 것인데, 사안은 그 엄격한 요건까지 갖춘 예외적 경우다.

3. 「...에만」 사용되는 물건인지 (전용성)

「...에만」이란 그 물건이 해당 발명 이외의 타용도를 갖고 있지 않다는 것을 의미한다. 널리 사용되는 기초상품이나 시중에서 쉽게 취득할 수 있는 범용품에는 간접침해가 성립할 여지가 없다. 타용도는 **상업적·경제적·실용적으로 실용성 있는 용도로서 사회통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정**되고, 단순히 이론적·실험적·일시적 사용 가능성이 있는 정도로는 타용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356).

사안의 필름은 **본건 카메라의 필름으로만 사용될 수 있고 다른 카메라 제품의 필름 용도로는 전혀 사용되지 아니한다.** 전용성이 인정된다.

4. 그 밖의 요건

丙은 필름 제조·판매업자로서 **업으로서** 이를 생산·양도하고 있고, 甲으로부터 실시허락을 받았다는 등 **정당한 권원**도 없다. 본건 특허의 **존속기간** 중이며 등록 후에 시작하였다. 간접침해에는 침해자의 고의·과실을 요하지 않는다.

Ⅲ. 직접침해와의 관계 — 종속설과 독립설

카메라를 구입한 최종 소비자가 필름을 교체하는 행위는 **개인적·가정적으로 이루어지는 것이어서 「업으로서」의 실시가 아니고, 그 결과 직접침해가 성립하지 않는다.** 이때에도 丙에게 간접침해를 물을 수 있는지가 문제된다.

- **종속설** — 직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다. 이에 따르면 丙의 책임은 부정된다.
- **독립설** — 직접침해와 별도로 간접침해의 요건만 갖추면 된다.

최종 실시가 개인적·가정적으로 유도되는 유형에 관하여는, 이를 **간접침해라고 하지 않으면 간접침해 규정의 실질적 실효성이 없어진다는** 입장이 우위에 있다. 실제로 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결은 **일반적인 실시가 개인적·가정적으로 이루어지는 레이저 프린터의 소모 부품인 감광드럼카트리지**

를 생산·판매하는 행위를 간접침해로 인정하였다. 본건 카메라와 그 전용 필름의 관계는 이 사안과 구조가 같다.

IV. 결론

丙의 필름 제조·판매 행위는 法 127조제1호의 간접침해에 해당하여 본건 특허권을 침해한 것으로 본다. 甲은 丙에 대하여 침해금지청구(法 126)와 손해배상청구(法 128)를 할 수 있다.

다만 침해금지청구권을 행사할 때 타용도 존재 여부의 기준시점은 간접침해 시가 아니라 사실심 변론종결 시다. 변론종결 시에 타용도가 생겼음에도 금지청구를 인정하면 특허발명과 무관한 용도에까지 특허권의 효력이 미치게 되기 때문이다.

출제 포인트 정리

- (1)과 (2)는 **균등침해의 결론이 갈리는 한 쌍**이다. 발문의 표현("전혀 다른 형태" vs "외부에 항상 노출되어 있는 형태")이 요건 포섭의 근거이며, (2)를 부정하면 **설문 2 전체가 무너진다는** 문제 구조까지 읽어야 한다.
- 신규성과 진보성의 구별이 설문 2-(1)의 첫 관문**이다. 비교대상발명이 **둘**이라는 사실 자체가 "신규성이 아니라 진보성"이라는 표지다. 신규성은 하나의 공지기술과만 대비한다.
- "결합에 특별한 어려움이 없다"는 전제는 **구성의 곤란성 부정**으로 직결된다. 여기에 **사후적 고찰 금지**를 함께 적어야 진보성 법리 서술이 완성된다.
- 설문 2-(2)의 축은 **2010다95390 전원합의체의 권리남용 항변**이다. i) 무효심결 확정 전이라도 ii) 침해소송 법원이 진보성을 심리·판단할 수 있다는 두 가지를 모두 써야 한다. 자유기술의 항변은 **판단대상이 확인대상발명**이라는 점에서 구별하여 병렬로 적는다.
- 설문 3의 마지막 문단은 **98후2580의 소모품 4요건을 그대로 옮긴 것**이다. 이를 알아보고 요건별로 대응시키면 20점의 골격이 완성된다. **전용성**(「...에만」)과 **종속설·독립설**까지 덧붙여야 배점이 채워진다.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 진보성(388~412), 하자 있는 특허권에 의한 권리행사·자유기술의 항변(1495~1504), 권리소진과 수리·재생산 (1470~1473), 직접침해의 유형(1628~1641), 간접침해(1690~1702). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 02

제2회 변호사시험 · 특허법

2013년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 4개

문 제

甲은 인터넷에서 경매를 효율적으로 수행하기 위한 역경매(reverse auction) 방식을 창안하여 아래와 같은 청구항을 작성하여 특허출원하였다.

[청구항] 한 사람의 구매자와 복수의 판매자와의 거래를 가능하게 하기 위하여 컴퓨터를 이용하는 방법으로서,

1단계: 구매자가 제안한 가격과 구매자의 결제정보(신용카드번호 등)를 컴퓨터에 입력받음

2단계: 입력된 제안 가격을 복수의 판매자에게 제공

3단계: 제안 가격에 대하여 판매자들에게서 수락의 의사표시를 입력받음

4단계: 제안 가격에 부합하는 최적 조건의 판매자 확정

5단계: 결제정보를 이용하여 확정된 판매자에 대한 대금지급으로 구성된 컴퓨터의 이용방법 위 사실관계에 기초하여 다음 질문에 답하시오.

1. 甲의 발명이 특허대상이 되는지 특허법상 ‘발명’의 정의 규정을 중심으로 검토하시오. (15점)
2. 甲의 특허출원 전에 실 거래계(off-line)에서 한 사람의 구매자가 제안한 가격을 복수의 판매자들에게 제공하고, 한 판매자가 이 제안 가격을 수락하면 구매자가 판매자에게 대금을 지급하면서 판매자로부터 판매물을 받는 방식의 경매 방법이 실제로 이용되고 있었다. 위의 사실을 전제로 하여 甲의 발명이 특허요건 가운데 신규성과 진보성을 충족하는지 여부에 대하여 설명하시오. (30점)
3. 甲의 발명이 한국특허청에 특허등록되었다고 가정할 경우(甲의 발명은 타국에 출원·등록하지 아니하였음),
 - (1) 乙은 위 발명의 1단계에서 4단계까지 수행하는 서버를 국내에서 운영·실시하고, 丙은 乙과 무관하게 위 발명의 5단계를 수행하는 결제시스템을 국내에서 운영·실시하는 경우, 乙과 丙의 실시가 甲의 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 검토하시오(단, 공동불법행위에 관한 논의는 제외). (25점)
 - (2) 제3자 丁(미합중국 캘리포니아 주에 본사 소재)은 위 영업방법을 수행하는 서버를 본사에 두고 영업을 하고 있다. 그리고 사용자들은 한국에서도 이 서비스를 접속·이용할 수 있다. 이 경우 丁의 실시가 甲의 특허권을 침해하는지 여부에 관하여 특허법상 원칙을 설명하고 이에 근거하여 판단하시오. (10점)

해 설

배점 80점 · 설문 4개(15 · 30 · 25 · 10). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 甲은 인터넷 **역경매(reverse auction)** 방식을 창안하여 「**한 사람의 구매자와 복수의 판매자와의 거래를 가능하게 하기 위하여 컴퓨터를 이용하는 방법**」으로 청구항을 작성해 출원하였다. 청구항은 **1단계** 구매자의 제안 가격과 결제정보를 컴퓨터에 입력받음 → **2단계** 제안 가격을 복수의 판매자에게 제공 → **3단계** 판매자들의 수락 의사표시를 입력받음 → **4단계** 최적 조건의 판매자 확정 → **5단계** 결제정보를 이용한 대금지급의 다섯 단계로 구성된다.

설문 사이의 독립성 — 설문 1에서 발명의 성립성을 부정하더라도 설문 2·3은 그대로 답하여야 합니다. 설문 2는 성립성과 별개인 **신규성·진보성**만을 묻고, 설문 3은 「**특허등록되었다고 가정할 경우**」를 명시하고 있기 때문입니다.

설문 1 — 甲의 발명이 특허대상이 되는지 (15점)

I. 발명의 정의와 성립요건

「**발명**」이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(法 2 I). 따라서 특허법상 발명이 되려면 i) 자연법칙을 이용한 것이어야 하고, ii) 기술적 사상 이어야 하며, iii) 창작이어야 하고, iv) 그 창작의 정도가 고도하여야 한다.

인위적인 약속이나 사람의 정신적 판단 그 자체는 자연법칙의 이용이 아니다. 경제법칙·수학 공식·게임 규칙 등은 자연법칙을 이용한 것이 아니므로 발명이 될 수 없다.

II. 전자상거래 관련 발명(BM 발명)의 성립성

1. 의의와 취지

「전자상거래 관련 발명(Business Method: BM)」이란 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의하여 구현된 발명을 말한다. 영업방법 그 자체는 자연법칙을 이용한 것이 아니지만, 인터넷 기술의 발달과 전자상거래의 확대 및 세계 각국의 인정 경향을 반영하여 일정한 요건 아래 특허법상 발명으로 인정하고 있다. 다만 컴퓨터 프로그램 그 자체는 특허법의 보호대상이 아니며 저작권법에 의하여 보호된다.

2. 판단기준

BM 발명은 i) 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형과 ii) 한정이 있는 유형으로 나뉘는데, 순수한 영업방법과 추상적 아이디어와 같이 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형은 발명의 성립성이 부정된다.

대법원은 "비즈니스 방법 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있

더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다"고 판시하였다(대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494; 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265).

이 기준을 구체화한 특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006허8910 판결은 「소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현된다」는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의하여 단순히 읽혀지는 데 그치지 않고 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다고 하면서, 청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 컴퓨터나 인터넷이 단순히 이용되는 것 이상의 새로운 효과를 발휘할 수 있어야 한다고 하였다.

한편 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결은 생활쓰레기 종합관리방법에 관하여 각 단계가 온라인상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인상에서 처리되고 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있지 않다는 이유로 발명의 성립성을 부정하였다.

Ⅲ. 사안의 해결

1. 성립성을 부정하는 방향 (타당)

甲의 청구항은 전제부에서 「컴퓨터를 이용하는 방법」이라 하고 1단계에서 「컴퓨터에 입력받음」이라고 하였을 뿐, 나머지 2단계 내지 5단계는 가격의 제공·수락 의사표시의 입력·최적 조건 판매자의 확정·대금지급이라는 거래행위 그 자체를 순서대로 나열한 것에 지나지 않는다.

- 하드웨어와의 구체적 협동수단이 특정되어 있지 않다. 어떤 정보처리장치가 어떤 연산·가공을 수행하여 어떤 특유의 동작을 구축하는지가 청구항에 나타나 있지 않고, 컴퓨터는 정보를 입력받고 전달하는 범용적 기능으로만 등장한다.
- 4단계의 「최적 조건의 판매자 확정」은 인간의 판단 내지 거래상의 약속에 해당하며, 그것을 어떤 알고리즘으로 컴퓨터가 수행하는지가 한정되어 있지 않다.
- 청구항 전체로 보면 역경매라는 영업방법(추상적 아이디어)에 「컴퓨터를 이용한다」는 표현을 덧붙인 데 그친다.

따라서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있다고 볼 수 없으므로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(法 2 I)에 해당하지 않아 발명의 성립성이 부정되고, 산업상 이용할 수 있는 발명(法 29① 본문)이라 할 수 없어 거절이유(法 62 I)에 해당한다.

2. 성립성을 인정할 여지

반대로 1단계가 「컴퓨터에 입력받음」으로 컴퓨터상 구현을 한정하고 있고 5단계의 결제정보를 이용한 대금지급이 온라인 결제시스템을 전제로 한다는 점을 들어, 각 단계가 온라인상에서 처리되는 이상 성립성을 인정할 수 있다는 구성도 가능하다. 다만 이 경우에도 발명의 설명에 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되게 하는 구현기술의 구체적 내용이 실시가능하도록 기재되어야 하므로(그렇지 않으면 法 42③ 위반), 명세서 기재요건에서 다시 걸리게 된다.

결론적으로 청구항 전체로서 하드웨어와의 구체적 협동수단을 특정하지 못한 이상 발명의 성립성은 부정된다고 봄이 타당하다.

설문 2 — 신규성과 진보성 (30점)

I. 대비의 대상 확정

甲의 출원 전에 실 거래계(off-line)에서 i) 한 구매자가 제안한 가격을 복수의 판매자에게 제공하고 ii) 한 판매자가 이를 수락하면 iii) 구매자가 판매자에게 대금을 지급하면서 판매물을 받는 방식의 경매방법이 실제로 이용되고 있었다. 이는 공연히 실시된 발명(法 29① I 후문)으로서 공지기술의 지위를 가진다.

II. 신규성

1. 판단기준

「신규성」이란 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 것으로서 객관적 창작성이 있는 것을 말한다(法 29①). 판단은 청구범위의 청구항에 기재된 발명을 대상으로, 하나의 공지기술과 대비하여 동일성이 있는지에 의한다. 복수의 공지기술을 조합하여 대비할 수 없다는 점이 진보성과의 결정적 차이이다.

BM 발명의 신규성에 관하여는 영업방법상의 특징과 컴퓨터 기술 구성상의 특징이 결합되어 있으므로, 출원발명과 인용대상이 동일한 영업방법상의 특징을 가지고 있더라도 그 컴퓨터 기술 구성상의 차이가 있으면 신규성이 있는 것으로 판단한다.

2. 사안의 적용

오프라인 경매방법과 甲의 청구항을 대비하면 영업방법상의 특징(한 구매자 대 복수 판매자, 제안 가격의 제시와 수락, 대금지급)은 공통된다. 그러나 다음의 차이가 있다.

	오프라인 경매방법	甲의 청구항
구현 수단	대면·수작업	컴퓨터를 이용
가격·결제정보의 입력	없음	1단계 — 컴퓨터에 입력받음
판매자 확정	개별 합의	4단계 — 최적 조건 판매자 확정
대금지급	대면 지급	5단계 — 입력된 결제정보를 이용한 지급

컴퓨터 기술 구성상의 차이가 존재하고, 특히 결제정보를 미리 입력받아 이를 이용하여 대금을 지급한다는 구성은 대면 거래에는 없던 것이다. 구성요소에 차이가 있고 그 차이가 주지관용기술의 부가·삭제·변경으로 새로운 효과가 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다고 보기도 어려우므로 동일성이 인정되지 않는다.

따라서 신규성은 부정되지 않는다.

Ⅲ. 진보성

1. 판단기준

「진보성」이란 통상의 기술자가 제29조제1항 각 호의 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것을 말한다(法 29②). 판단은 통상의 기술자의 입장에서, 특허출원 시를 기준으로, 국내 또는 국외의 공지기술을 대상으로 하되 둘 이상의 인용대상을 조합할 수 있다.

판단방법은 가장 가까운 인용대상을 선택하여 차이점을 파악한 뒤, 그 차이에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지를 다른 인용대상·기술상식·경험칙에 의하여 판단하는 것으로서, 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작하여 종합한다.

이때 사후적 고찰은 금지된다 — 해당 발명의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 쉽게 이끌어낼 수 있는 경우가 많으므로 출원 전의 상태로 돌아가 판단하여야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

또한 공지기술의 일반적인 응용이나 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경은 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당하고, 차이점이 이러한 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 진보성이 부정된다.

2. BM 발명의 진보성 판단 기준 (★)

BM 발명의 진보성은 다음과 같이 유형화된다.

유형	진보성
종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현	부정
종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현	인정될 수 있음
새로운 영업방법을 새로운 기술로 구현	인정될 수 있음
새로운 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현	개별적으로 달리 판단

3. 사안의 적용

- **영업방법 자체는 새로운 것이 아니다.** 한 구매자가 제시한 가격을 복수의 판매자에게 제공하고 수락한 판매자와 거래를 성립시키는 방식은 **甲의 출원 전에 실 거래계에서 이미 이용되고 있었다.** 따라서 甲의 발명은 「종래의 영업방법」을 구현한 것이다.
- **구현수단이 새로운 기술인가.** 청구항은 정보를 컴퓨터에 입력받아 전달하고 결과를 확정된 뒤 결제 정보로 대금을 지급한다는 것일 뿐, 그 처리를 위한 새로운 기술적 수단(알고리즘·데이터 구조·통신 방식 등)을 아무것도 한정하고 있지 않다. 이는 컴퓨터·인터넷의 범용적 기능을 이용한 통상의 자동화기술에 지나지 않는다.

- **결제정보를 이용한 대금지급(1단계·5단계)**은 신규성 단계에서는 차이점으로 인정되지만, 진보성 단계에서는 전자상거래 분야에서 널리 알려진 신용카드 결제방식을 그대로 적용한 것 으로서 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다.
- **효과의 현저성** — 오프라인 거래를 온라인화함에 따르는 신속성·편의성의 향상은 **자동화에 따라 당연히 예측되는 효과**일 뿐, 출원 시의 기술수준에서 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 이질적이거나 현저하게 우수한 효과라고 할 수 없다.

따라서 甲의 발명은 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 것으로서 진보성이 부정된다.

IV. 결론

신규성은 인정되나 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다(法 29②). 이는 거절이유 (法 62 I)·정보제공사유(法 63의2)·특허무효사유(法 133① I)에 해당한다.

신규성 인정 → 진보성 부정이라는 결론의 배치가 이 30점의 핵심이다. 신규성 단계에서 발견한 차이점(컴퓨터 구현·결제정보)이 진보성 단계에서 통상의 자동화기술·통상의 창작능력 발휘로 평가되어 무너지는 흐름을 그대로 보여 주어야 한다. 두 요건을 한꺼번에 "동일하니까 둘 다 부정"이라고 쓰면 배점의 절반을 잃는다.

설문 3-(1) — 乙과 丙의 분산 실시 (25점)

I. 문제의 소재

甲의 특허발명은 1단계 내지 5단계로 구성된 방법발명이다. 방법발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ나). 그런데 乙은 1단계 내지 4단계를 수행하는 서버를, 丙은 乙과 무관하게 5단계를 수행하는 결제시스템을 각각 운영·실시하고 있다. 두 사람의 행위를 합하면 청구항의 모든 구성요소가 충족되는데, 각자에게 침해책임을 물을 수 있는지가 문제된다. 이것이 복수 주체에 의한 분산 실시 문제로, 전자상거래 관련 발명에서 특히 빈발한다.

Ⅱ. 각자의 단독 직접침해 — 부정

직접침해가 성립하려면 청구항의 모든 구성요소를 단일 주체가 실시하여야 한다 (구성요소완비의 원칙). 乙은 5단계를, 丙은 1단계 내지 4단계를 각각 실시하지 않으므로 어느 쪽도 스스로 특허발명을 실시한 것이 아니다.

Ⅲ. 규범적 관점에서 단독 직접침해로 볼 수 있는지 — 도구이론(지배관리론)

1. 법리

복수 주체가 구성요소를 분담하여 실시하는 경우에도, 어느 한 단일 주체가 다른 주체를 도구나 수족으로 이용하여 구성요소 전체의 실시에 의한 권리침해를 지배·관리하고 그로 인하여 영업상의 이익을 얻었

다면, 다른 주체의 행위를 그 주체의 행위와 법적으로 동일시하여 **단독 직접침해**를 인정할 수 있다(서울고등법원 2017. 8. 21. 선고 2015라20296). 이는 사정을 알지 못하는 제3자를 이용하여 범죄를 실행하게 한 자를 정범으로 보는 형법상 **간접정범**과 유사한 구조다.

교재가 드는 사례로는 i) 음반 제작업체에 2~4단계 공정을 하게 하고 그 결과물을 공급받아 CD를 제조·판매한 사안(서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518), ii) SMS 서비스 운영자가 서비스를 주도적으로 기획·구성하고 이동통신사의 협력 아래 서비스를 제공하면서 경제적 이익을 향유하고 사업의 성패에 따른 위험을 부담한 사안(서울고등법원 2006. 7. 10.자 2005라726)이 있다.

2. 사안의 적용

발문은 「**丙은 乙과 무관하게**」라고 명시하였다. 乙이 丙의 결제시스템 운영을 지배·관리한다는 사정도, 丙의 실시로 乙이 영업상 이익을 얻는다는 사정도 없다. 그 반대도 마찬가지다. **도구이론·지배관리론에 의한 단독 직접침해는 성립하지 않는다.**

IV. 공동 직접침해로 볼 수 있는지

1. 법리

甲과 乙이 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 **공동으로 특허발명을 실시할 의사**를 가지고, i) 계속적 거래관계나 조인트 벤처 등을 형성하여 일체가 되어 결과를 발생시키려는 의사로 각자 구성요소의 일부를 실시하거나, ii) 각자 자신의 행위와 상대방의 행위가 결합하여 침해의 결과가 발생할 것을 예상하는 경우에는 **공동 직접침해**를 인정할 수 있다. 이는 형법상 **공동정범**과 유사하다.

다만 특허법에 근거를 두고 있지 않은 법리이므로 그 인정범위는 제한적으로 해석하여야 하고, 제3자의 예측가능성을 해치지 않도록 명확히 하여야 한다.

2. 사안의 적용

乙과 丙 사이에는 **계속적 거래관계도, 공동으로 실시할 의사도 없다**. 서로의 존재를 인식하고 이를 이용할 의사가 있었다고 볼 사정이 발문에 전혀 나타나지 않는다. **공동 직접침해도 성립하지 않는다.**

V. 간접침해로 규율할 수 있는지

특허가 방법의 발명인 경우 간접침해행위는 **그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위**다(法 127Ⅱ).

- **행위 유형이 맞지 않는다.** 乙과 丙은 물건을 생산하여 타인에게 양도하는 것이 아니라 스스로 서버와 결제시스템을 운영·실시할 뿐이다. 법정된 간접침해행위의 유형에 포섭되지 않는다.
- **전용성 요건도 충족되기 어렵다.** 「...에만」이란 그 물건에 타용도가 없다는 뜻인데, 전자상거래 관련 발명은 그 특성상 범용성이 있는 서버 또는 컴퓨터상에서 구현되는 경우가 대부분이어서 전용품의 조건을 만족하기가 현실적으로 어렵다.

간접침해로도 규율할 수 없다.

VI. 민법상 공동불법행위

발문이 명시적으로 「**공동불법행위에 관한 논의는 제외**」하였으므로 논하지 않는다. 참고로 교재는, 분산 실시의 경우 각자의 행위 자체가 특허권 침해에 해당한다고 보기 어려우므로 공동불법행위책임(민법 제760조)도 물을 수 없다고 본다.

VII. 결론

乙과 丙 어느 쪽도 甲의 특허권을 침해하지 않는다. 각자 청구항의 구성요소 전부를 실시하지 않았고, 지배·관리 관계나 공동 실시의 의사가 없어 단독 직접침해·공동 직접침해가 모두 부정되며, 간접침해의 행위 유형에도 해당하지 않기 때문이다.

다만 이러한 결론은 실시행위의 일부만을 타인에게 하게 함으로써 침해를 회피하는 것을 가능하게 하여 균형을 잃는 측면이 있다. 청구항을 단일 주체가 실시하도록 작성하는 등 출원 단계의 대응이 중요하며, 입법적 보완의 필요성도 지적된다.

설문 3-(2) — 국외 서버를 통한 서비스 (10점)

I. 특허법상 원칙 — 속지주의

특허권의 효력은 속지주의 원칙에 따라 우리나라에만 미친다. 우리나라 내에 있는 자에 대해서는 내·외국인을 불문하고 효력이 미친다. 파리조약 제4조의2는 "동맹국의 국민이 각 동맹국에서 출원한 특허는 동맹국 또는 비동맹국과 관계없이 동일한 발명에 대하여 타국에서 취득한 특허로부터 독립한다"고 하여 특허독립의 원칙을 천명하고 있고, 이에 따라 독립적으로 취득한 특허권은 그 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력을 가진다.

역외적용의 원칙(자국법이 영토 밖의 행위에 효력을 갖는다는 것)은 타국의 자주권과 특허법을 무시할 우려가 있으므로 일반적으로 배제되어야 한다. 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결도 "특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다"는 전제에서, 완성품이 국외에서 생산된 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다.

II. 사안의 적용

- 甲의 특허권은 한국에만 있다. 발문은 타국에 출원·등록하지 아니하였음을 명시하였다.
- 丁의 실시행위는 국외에서 이루어진다. 丁은 미합중국 캘리포니아 주 본사에 서버를 두고 영업하고 있으므로, 방법발명의 실시(그 방법을 사용하는 행위, 法 2Ⅲ나)는 미국 내에서 이루어진다. 국내에 등록된 甲의 특허권의 효력은 그 행위에 미치지 않는다.
- 한국 사용자가 접속·이용할 수 있다는 사정만으로 달리 볼 수 없다. 서비스의 결과가 국내에 미친다는 것과 실시행위 자체가 국내에서 이루어졌다는 것은 구별되어야 하며, 이를 근거로 국내 특허권

의 효력을 국외 행위에 미치게 하는 것은 **역외적용에 해당하여 원칙적으로 허용되지 않는다**. 또한 이용자들의 접속·이용은 개인적 이용에 그쳐 「**업으로서**」의 실시(法 94①)라고 보기도 어렵다.

Ⅲ. 속지주의의 예외를 원용할 수 있는지

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결은 i) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii) 그 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 iv) 부품 전체 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, **예외적으로 국내에서 실시 제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다**고 하여 속지주의의 예외를 인정하였다.

그러나 이는 **물건발명에 관하여 국내에서 반제품이 생산된 사안**에 관한 것이다. 사안은 **방법발명이고 국내에서 이루어진 실시행위 자체가 없으므로** 이 예외를 원용할 수 없다. 이러한 예외에 해당하는지는 속지주의 원칙과 구성요소완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.

IV. 결론

丁의 실시는 甲의 특허권을 침해하지 않는다. 甲이 丁의 영업을 저지하려면 **미국에도 특허를 취득**하여 그 나라에서 권리를 행사하는 수밖에 없다.

출제 포인트 정리

1. 설문 1은 **法 2 I의 네 요건에서 출발**해 BM 발명의 성립성 기준 (**소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현**)으로 내려가야 한다. **청구항 전체로서 판단**한다는 점을 빠뜨리지 말 것.
2. 설문 2의 30점은 **신규성 인정 → 진보성 부정**이라는 배치에서 나온다. BM 발명은 **영업방법의 특징**이 같아도 컴퓨터 기술 구성상 차이가 있으면 신규성이 인정되고, 종래의 영업방법을 통상의 자동화 기술로 구현하면 진보성이 부정된다. 이 두 명제가 축이다.
3. 설문 3-(1)은 **구성요소완비의 원칙 → 도구이론(지배관리론) → 공동 직접침해 → 간접침해**의 4단 검토를 모두 거쳐야 25점이 채워진다. 발문의 「**乙과 무관하게**」가 2·3단계를 차단하고, **서버의 범용성**이 4단계를 차단한다. 결론이 "비침해"라고 해서 짧게 쓰면 안 되는 문제다.
4. 설문 3-(2)는 **속지주의 + 특허독립의 원칙**을 원칙으로 세우고, **실시행위가 어디에서 이루어졌는지**로 포섭한다. "한국에서 접속할 수 있다"는 사정은 **결과의 발생지일 뿐 실시행위지가 아니다**. 2019다222782의 예외는 **물건발명·국내 반제품 생산** 사안이므로 원용할 수 없다는 점까지 짚으면 10점이 완성된다.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 전자상거래 관련 발명 (113~117), 신규성(347~380), 진보성(388~412), 특허권의 지역적 범위와 역외적용 (1427~1431), 복수 주체에 의한 분산 실시(1620~1628), 간접침해(1690~1702). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 03

제3회 변호사시험 · 특허법

2014년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 5개

문 제

1. 甲과 乙은 공동사업을 준비하고 있던 중, 丙과 丁이 그 사업의 기초가 되는 X에 관한 발명을 얼마 전 공동으로 완성하였다는 소식을 들었다. 이에 甲과 乙은 X에 관한 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 丙과 丁으로부터 이전받아 공동출원하기로 약정한 후, 甲은 丙의 지분을, 乙은 丁의 지분을 각각 이전받았다. 그런데 다음날 甲은 乙 몰래 단독으로 X에 관하여 특허출원을 하였다.
이 경우 乙이 자신의 권리를 회복하기 위해 취할 수 있는 법적 조치에 관하여, 특허출원이 계속 중인 경우와 특허 등록이 된 이후의 경우로 나누어 설명하라. (40점)
2. 신규성 상실에 관한 특허법상 법리를 논하고(20점), 아래 각 사례의 경우 신규성이 인정될 수 있는지 여부에 관하여 위 법리를 기초로 판단하시오.
 - (1) 甲은 자신의 발명 A에 대하여 박사학위를 받기 위해 논문 심사위원들에게 발명 A에 대한 상세한 자료를 제출하고 그 내용을 발표하였다. 박사학위논문 심사를 통과한 甲은 학교 근처 인쇄소에서 박사학위논문을 인쇄한 후 도서관에 납본하여 도서관 반입 등록 절차를 마쳤다. (5점)
 - (2) 乙은 B를 발명한 후 친구 丙에게 그에 관한 도면을 주면서 검토를 부탁하며 이를 공개하지 말 것을 요청하였는데, 丙이 자신이 운영하는 웹 사이트에 위 도면을 임의적으로 게시하였다. (8점)
 - (3) 도급업체인 丁이 수급업체에 발명품의 제작을 의뢰하기 위해 발명의 샘플과 제작도면을 수급업체에 교부하였으나 하도급계약의 전후에 발명의 샘플과 제작도면은 공사 실무자나 도급업체 및 수급업체의 관련 직원들이 자유롭게 열람할 수 있는 상태에 있었다. (7점)

해 설

배점 80점 · 설문 5개(40 · 20 · 5 · 8 · 7). 문제 원문은 자료집 참조.

설문 1 — 甲·乙이 공동사업을 준비하던 중 丙·丁이 공동완성한 X 발명에 관하여, 甲은 丙의 지분을, 乙은 丁의 지분을 각각 이전받기로 **약정한 후 실제로 이전받았다**. 그런데 다음날 **甲이 乙 몰래 단독으로 X를 특허출원**하였다. 乙의 권리회복 조치를 **출원 계속 중**과 **등록 후**로 나누어 설명하라.

설문 2 — 신규성 상실에 관한 법리를 논하고, (1) 박사학위논문 (2) 비밀유지 요청을 어긴 친구의 웹 게시 (3) 도급·수급업체 직원들이 자유롭게 열람할 수 있던 샘플·제작도면의 각 신규성 인정 여부를 판단하시오.

배점 표기에 관하여 — 이 회차는 배점이 문장 중간에 붙어 있습니다("…법리를 논하고(20점), 아래 각 사례의 경우…"). 20점은 **법리 서술**에, 5·8·7점은 각 사례 판단에 배분된 것으로 읽어야 하며, 법리 부분을 사례 판단에 녹여 쓰면 20점을 통째로 잃습니다. **법리를 먼저 독립된 항목으로 완결한 뒤** 사례로 내려가야 합니다.

설문 1 — 乙의 권리회복 조치 (40점)

I. 쟁점

이 설문은 **甲이 무권리자가 아니라는 점**에서 출발해야 한다. 甲은 丙으로부터 지분을 적법하게 이전받은 **공유자**이고, 다만 **공유자 전원이 공동으로 출원하여야 한다는 의무 (法 44)**를 위반하였을 뿐이다. 이 구별이 이 설문 전체를 지배한다. 특허법이 정당한 권리자를 보호하는 두 갈래 중 **출원일 소급(法 34·35)**은 「제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유」에만 열려 있고, 특허권의 **이전청구(法 99의2)**는 제44조 위반에도 열려 있기 때문이다.

II. 선결 — 특허를 받을 수 있는 권리가 甲·乙의 공유인지

- 2명 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 된다(法 33②). 丙·丁이 X를 공동으로 완성하였으므로 그 권리는 丙·丁의 공유였다.
- 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 각 공유자는 **다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도**할 수 있다(法 37③). 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력 여하가 다른 공유자의 이해관계에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 사안에서 甲·乙과 丙·丁은 **네 사람이 함께 지분 이전을 약정**하였으므로, 丙의 甲에 대한 양도에는 丁의 동의가, 丁의 乙에 대한 양도에는 丙의 동의가 각각 있었다고 볼 수 있다. 따라서 두 양도는 모두 유효하다.
- 그 결과 X에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리는 **甲·乙의 공유**가 되었다.

III. 甲 단독출원의 하자 — 제44조 위반 (★)

- 하자의 내용** — 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(法 44). 甲의 단독출원은 이를 위반한 것으로서, **거절이유 (法 62 I)·정보제공사유(法 63의2)·특허무효사유(法 133①II)**에 각각 해당한다.
- 무권리자 출원과의 구별** — 甲은 丙의 지분을 승계한 자이므로 「특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자」가 아니다. 따라서 甲의 출원은 **제33조제1항 본문 위반(法 62II)**이 아니라 **제44조 위반(法 62 I)**이다. 이 구별의 실익은 다음 두 가지다.

	제33조제1항 본문 위반	제44조 위반(사안)
거절이유	法 62 제2호	法 62 제1호
무효사유	法 133①Ⅱ	法 133①Ⅱ (동일 조항)
출원일 소급(法 34-35)	○	× — 조문이 제33조제1항 본문 사유로 한정
이전청구(法 99의2)	○	○ — 133①Ⅱ 본문 해당이면 족함

즉 乙에게는 자기 이름으로 다시 출원해 甲의 출원일로 소급받는 길이 처음부터 없다. 제34조·제35조는 그 문언상 "제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로" 거절되거나 무효로 된 경우만을 요건으로 삼고 있기 때문이다. 乙이 지금 별도로 출원하더라도 甲의 출원일로 소급되지 않으므로, 甲의 출원이 공개된 뒤라면 오히려 그 공개에 의하여 신규성을 잃는다. 따라서 乙의 회복수단은 「甲의 출원·특허 자체를 자기 것으로 되찾는 것」에 집중된다.

IV. 특허출원이 계속 중인 경우

1. 출원인변경절차 이행청구 — 실질적 회복수단

특허출원 후에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 그 밖의 일반승계를 제외하고 특허출원인변경 신고를 하여야만 효력이 발생한다(法 38④). 甲이 임의로 신고에 협력할 리 없으므로, 乙은 甲을 상대로 출원인변경절차의 이행을 구하는 소(또는 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 확인의 소)를 제기하고, 그 확정판결을 첨부하여 출원인변경신고를 하면 된다. 교재는 무권리자의 특허출원에 대하여 정당한 권리자가 출원인변경신고를 하면 제33조제1항 본문 위반이 해소된 것으로 보고 출원을 계속 진행하도록 인정할 필요가 있다고 설명하는데, 제44조 위반의 경우에도 같은 취지로 볼 수 있다. 甲의 단독출원이 甲·乙의 공동출원으로 되면 제44조 위반이라는 하자 자체가 치유되고, 심사가 진행 중인 상태를 그대로 살릴 수 있어 별도 출원보다 신속하기 때문이다.

2. 보전조치

본안 판결까지 甲이 출원을 취하·포기하거나 지분을 제3자에게 처분할 위험이 있다. 乙은 특허를 받을 수 있는 권리의 지분에 대한 처분금지가처분 등 민사보전을 함께 구할 실익이 있다.

3. 정보제공 (法 63의2)

누구든지 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있다(法 63의2). 乙은 甲의 출원이 제44조 위반임을 증거와 함께 제공하여 거절결정을 유도할 수 있다.

다만 이는 「甲이 특허를 받지 못하게 하는」 수단일 뿐 「乙이 권리를 취득하는」 수단이 아니다. 앞서 본 것처럼 제44조 위반에는 제34조의 소급효가 없으므로, 거절결정이 확정되어도 乙이 새로 출원해 甲의 출원일을 원용할 수 없다. 따라서 정보제공은 위 1.의 이행청구가 여의치 않을 때의 보충수단으로 자리 매김하여야 한다.

4. 정리

출원 계속 중이라면 **출원인변경절차 이행청구 → 확정판결 → 출원인변경신고(法 38④)**로 공동출원 상태를 만드는 것이 乙에게 가장 유리하다.

V. 특허 등록이 된 이후의 경우

1. 특허권 지분의 이전청구 (法 99의2) — 핵심 수단

(1) **요건** — 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 청구한다(法 99의2①). 사안의 甲 특허는 제44조 위반으로 제133조제1항제2호 본문에 해당하고, 乙은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이므로 요건을 충족한다. 甲이 丙의 지분에 관하여는 정당한 승계인이므로 특허권 전부가 아니라 乙의 지분에 한하여 이전을 청구한다.

(2) 효과

- **소급적 귀속** — 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록되면 해당 특허권과 보상금 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다(法 99의2②). 처음부터 특허권을 취득할 수 있었던 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이기 때문이다. 그 결과 甲이 그 사이 특허권·보상금청구권을 행사하여 얻은 이익은 부당이득으로 乙에게 반환할 대상이 된다.
- **다른 공유자의 동의 불요** — 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에도 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의 없이 지분을 이전할 수 있다(法 99의2③). 甲의 동의가 필요하다면 제도가 무의미해지기 때문이다.
- **무효사유에서 제외** — 이전등록이 있으면 그 특허권은 특허무효심판의 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ 단서). 애초에 정당한 권리자의 출원이 아니었다는 이유로 다시 무효가 되는 것을 막기 위함이다.

(3) **甲의 통상실시권 주장 가부** — 이전등록 전에 그 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당함을 알지 못하고 국내에서 실시사업을 하거나 준비한 원특허권자는 법정통상실시권을 가진다(法 103의2①Ⅰ). 그러나 사안의 甲은 乙 몰래 단독출원한 자로서 공동출원 위반을 스스로 알고 있었으므로 이 요건을 갖추지 못한다.

2. 특허무효심판 (法 133①Ⅱ)

甲의 특허는 제44조 위반으로 무효사유가 있고, 이 경우의 청구인적격은 「특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자」로 한정되므로(法 133① 괄호) 乙이 청구할 수 있다.

그러나 이는 乙의 목적에 부합하지 않는다. 무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 될 뿐(法 133③), 乙이 그 권리를 취득하는 것이 아니다. 그리고 앞서 본 것처럼 제35조의 소급출원은 제33조제1항 본문 사유에 한정되어 제44조 위반에는 적용되지 않으므로, 무효 확정 후 乙이 새로 출원하

더라도 甲의 출원일로 소급받지 못한다. 이미 등록공고로 발명이 공개된 이상 乙의 새 출원은 그 공고에 의하여 신규성을 잃는다.

결국 무효심판은 「甲도 갖지 못하게 하는」 최후수단일 뿐, 권리회복 수단이 아니다.

3. 민사상 청구

이전등록을 받은 뒤 乙은 甲이 특허권 행사로 얻은 이익에 대하여 **부당이득반환**을 구할 수 있고, 무단출원 자체가 불법행위를 구성하는 범위에서 **손해배상**도 가능하다.

4. 정리

등록 후라면 **제99조의2에 따른 지분 이전청구가 유일하게 실효적인 회복수단**이다. 무효심판은 회복이 아니라 소멸을 가져올 뿐이므로, 이전청구가 어려운 사정이 없는 한 선택할 이유가 없다.

VI. 결론

단계	조치	근거	성질
출원 계속 중	출원인변경절차 이행청구 → 변경신고	法 38④	회복
"	처분금지가처분	민사보전	보전
"	정보제공	法 63의2	저지
등록 후	특허권 지분 이전청구	法 99의2	회복(설정등록일로 소급)
"	부당이득반환·손해배상	민법	정산
"	특허무효심판	法 133①Ⅱ	저지(회복 아님)

제44조 위반에는 제34조·제35조의 출원일 소급이 적용되지 않는다는 점이 이 설문의 축이다. 소급출원을 답으로 쓰면 40점의 핵심을 놓친다.

설문 2 — 신규성 상실의 법리 (20점)

I. 의의와 취지

「발명의 신규성」이란 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 것으로서 객관적 창작성이 있는 것을 말한다. 특허법은 i) 신규한 발명을 공개한 자에게만 공개의 대가로 특허권을 부여하고, ii) 공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위하여 신규성을 특허요건으로 규정한다. 다만 **신규성 상실사유를 제한열거적으로 규정**하여, 열거된 사유에 해당하지 아니하면 신규성이 상실되지 않은 것으로 봄으로써 객관성을 확보하고 있다.

Ⅱ. 신규성 상실사유 (法 29①)

1. 공지 (法 29① I 전문)

「공지」란 불특정인이 널리 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 말한다. 여기서 「불특정인」이란 비밀유지의무가 없는 자를 뜻하며 다수의 일반 대중을 의미하지 않는다. 1명에게라도 비밀유지상태가 해제되었으면 공지이고, 반대로 다수인이 알 수 있는 상태라도 그 전원에게 비밀유지의무가 있으면 공지가 아니다.

비밀유지의무가 인정되는 예로는 i) **법령상**(변리사·변호사 등), ii) **관습상**(바이어·운송업자 등), iii) **계약상**(종업원·용역계약자 등) 인정되는 경우가 있다. 샘플용·시험용 제품을 특정인에게 공급한 일이 있다 하여 곧바로 출원 전에 불특정다수인에게 공지된 것이라고 단정할 수 없다(대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1804).

또한 알 수 있는 「상태」에 놓이면 족하고 「인식」을 요구하지 않는다. 반대로 제3자가 발명을 인식하고 있더라도 그것을 **비밀로 유지**하고 있다면 공지가 아니다.

2. 공연실시 (法 29① I 후문)

「공연실시」란 실시에 의하여 발명이 불특정인에게 공연히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 말하며, 「공연」이란 발명의 주요부에 대하여 비밀상태가 해제된 것을 의미한다. 단 1회의 실시라도 공연실시가 될 수 있으나, 주요부의 일부에 대하여 비밀유지상태가 확보된 채 실시된 때에는 공연실시가 아닐 수 있다.

3. 반포된 간행물에 게재 (法 29①II 전문)

「반포」란 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 말한다. 따라서 i) 인쇄·제본되었으나 아직 발행자의 손안에 있는 것, ii) 반포를 위해 발송 중인 간행물, iii) **도서관 사서과에는 도착하였으나 열람실에 비치되지 아니한 경우**는 반포가 아니다. 반면 열람실에 비치되었다면 아무도 읽지 않았더라도 반포된 것으로 본다.

「간행물」이란 인쇄나 그 밖의 기계적·화학적 방법에 의하여 공개할 목적으로 복제된 정보성과 공개성이 있는 문서·도면 등의 정보전달매체를 말한다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377). 공개를 목적으로 하지 않는 회사 내 사문서·비밀문서는 간행물이 아니다. 「게재」는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도여야 한다.

4. 전기통신회선을 통한 공중의 이용가능 (法 29①II 후문)

「전기통신회선」에는 인터넷은 물론 공중게시판·이메일 그룹 등이 포함되며 물리적 회선을 요하지 않는다. 다만 공개된 발명에의 접근이 일반인에게 허용되지 않고 특정인에게만 허용되면 공중이 이용가능하게 된 발명이라 볼 수 없다(암호를 부여한 경우, 일반 검색엔진으로 접근할 수 없는 경우, 과도한 요금을 요구하는 경우 등). 공개시점은 해당 발명을 전기통신회선에 게재한 시점이다.

Ⅲ. 신규성의 판단

- **대상** — 청구범위의 청구항에 기재된 발명을 공지기술과 대비한다.
- **공지기술의 수** — 하나의 공지기술과 대비하여야 하고 복수의 공지기술을 조합할 수 없다. 조합에 의한 판단은 진보성의 문제다.
- **시기** — 「특허출원 전」을 기준으로 한다. 이는 「특허출원일 전」과 달라, 출원일과 공개일이 같은 날인 경우에도 시·분·초를 따져 적용된다(시각주의).
- **지역** — 국내 또는 국외를 기준으로 한다(국제주의).
- **방법** — 청구항의 구성과 공지기술을 대비하여 동일성을 판단하되, 구성요소에 차이가 있더라도 주지관용기술의 부가·삭제·변경으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이라면 동일성이 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472).

Ⅳ. 신규성 상실의 예외 — 공지의예외적용 (法 30)

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 i) 그 자에 의하여(法 30① I 본문) 또는 ii) 그 자의 의사에 반하여(法 30① II) 제29조제1항 각 호에 해당하게 된 경우, 그 날부터 12개월 이내에 출원하면 신규성·진보성을 적용할 때 공지되지 아니한 것으로 본다.

절차 — 제1호(자기 공지)를 적용받으려는 자는 출원서에 그 취지를 적어 출원하고 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(法 30②). 반면 제2호(의사에 반한 공지)는 제30조 제2항의 적용대상이 아니므로 출원 시 취지 기재·증명서류 제출이 요구되지 않는다. 출원인이 출원할 때 의사에 반한 공지가 있었음을 모르는 경우가 대부분이기 때문이며, 심사관이 신규성·진보성 위반의 의견제출 기회를 준 때에 그 공지가 의사에 반한 것임을 증명하면 된다.

한계 — 공지의예외적용은 출원일을 소급시키는 제도가 아니다. 12개월의 유예기간이 있더라도 그 사이에 타인의 출원이 있으면 확대된 선출원(法 29③④) 위반이 문제될 수 있으므로 될 수 있으면 빨리 출원하여야 한다.

Ⅴ. 신규성 상실의 효과

신규성이 없으면 거절이유(法 62 I)·정보제공사유(法 63의2)·특허취소신청이유·특허무효사유(法 133① I)에 해당한다.

설문 2-(1) — 박사학위논문 (5점)

1. 문제되는 두 단계

甲의 행위는 i) 심사위원들에 대한 자료 제출·발표와 ii) 인쇄 후 도서관 납본·반입 등록의 두 단계로 나뉜다. 각각 공지(法 29① I 전문)와 반포(法 29① II 전문)의 문제다.

2. 논문심사 단계

논문 심사위원들은 심사라는 직무에 따라 제출된 자료의 내용을 비밀로 유지할 지위에 있으므로 **비밀 유지의무 없는 「불특정인」에 해당한다고 보기 어렵다**. 발표 역시 심사위원들을 상대로 한 것이고 **공개된 장소에서 이루어진 것이 아니다**. 따라서 이 단계에서는 공지되었다고 할 수 없다.

3. 도서관 납본·등록 단계 (★)

학위논문의 반포시점은 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 최종 심사를 거쳐 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 불특정인에게 배포된 시점으로 인정된다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689; 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19). 여기서 「입고」란 도서관에 등록되어 서가에 진열된 경우를 의미하며, 그 이전 단계인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재 내용이 공지로 되는 것은 아니다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689).

사안에서 甲은 인쇄소에서 논문을 인쇄한 후 도서관에 납본하여 반입 등록 절차를 마쳤을 뿐이고, 서가에 진열되어 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 이르렀다는 사정은 없다. 인쇄만 마친 단계 역시 아직 발행자의 손안에 있는 것이어서 반포가 아니다.

4. 결론

신규성이 인정된다. 다만 서가 진열로 반포에 이르면 그때부터는 신규성이 상실되므로, 甲은 그 전에 출원하거나 늦어도 반포일부터 12개월 이내에 제30조제1항제1호의 공지의예외적용을 주장하여 출원하여야 한다.

설문 2-(2) — 비밀유지 요청을 어긴 웹 게시 (8점)

1. 도면 교부 단계 — 공지가 아니다

乙은 丙에게 도면을 주면서 **공개하지 말 것을 요청**하였다. 이로써 丙은 **계약(신의칙)상 비밀유지의무를 부담하는 자가** 되므로 비밀유지의무 없는 「불특정인」이 아니다. 앞서 본 것처럼 특정인에게 자료를 건넨 것만으로 곧바로 공지라고 단정할 수 없다(대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1804). 따라서 교부 그 자체로는 신규성이 상실되지 않는다.

2. 웹 게시 단계 — 신규성 상실사유에 해당한다

그러나 丙이 자신이 운영하는 웹 사이트에 도면을 게시한 이상, 그 발명은 **전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명(法 29①Ⅱ 후문)**이 된다. 접근에 암호를 요구하거나 특정인에게만 열람을 허용하였다는 사정이 없으므로 공중의 이용가능성이 인정된다. **공개시점은 丙이 도면을 게시한 시점**이다.

丙이 비밀유지의무를 부담한다는 사정은 丙의 책임 문제일 뿐, 이미 공중이 이용할 수 있게 된 발명의 공지 상태를 되돌리지 못한다.

3. 공지에외적용의 가부 (★)

丙의 게시는 乙의 반공개 의사에 반한 공개이므로 제30조제1항제2호의 「의사에 반하여 공지 등이 된 경우」에 해당한다. 따라서 乙은 丙이 게시한 날부터 12개월 이내에 특허출원하면 그 게시는 신규성·진보성을 적용할 때 공지되지 아니한 것으로 본다.

절차상 주의점 — 제30조제2항의 취지 기재·증명서류 제출 의무는 제1호에만 부과되므로, 乙은 출원서에 그 취지를 적지 않았더라도 제2호의 적용을 받을 수 있다. 다만 심사관이 신규성·진보성 위반을 이유로 의견제출 기회를 준 때에는 그 공지가 자신의 의사에 반한 것임을 증명하여야 한다.

4. 결론

丙의 게시로 신규성은 일단 상실되나, 乙이 게시일로부터 12개월 이내에 출원하면 제30조제1항 제2호에 의하여 신규성이 인정된다. 12개월이 지난 뒤의 출원이라면 신규성을 회복할 수 없다.

설문 2-(3) — 도급업체가 교부한 샘플·제작도면 (7점)

1. 수급업체에 대한 교부 자체

도급업체 丁이 제작 의뢰를 위하여 수급업체에 샘플과 제작도면을 교부한 것은, 그 상대방이 계약관계에 기하여 비밀유지의무를 부담하는 범위에서는 불특정인에 대한 공개가 아니다. 비밀유지의무는 계약상으로도 인정될 수 있기 때문이다(종업원·용역계약자 등).

2. 자유롭게 열람할 수 있는 상태 (★)

그러나 사안의 샘플과 제작도면은 하도급계약의 전후를 불문하고 공사 실무자나 도급업체·수급업체의 관련 직원들이 자유롭게 열람할 수 있는 상태에 있었다.

- **인적 범위** — 열람이 가능하였던 자는 계약당사자에 한정되지 않고 양측의 관련 직원과 공사 실무자 일반에까지 미친다. 이들 전원에게 비밀유지의무가 있다고 볼 근거가 없다.
- **시기** — 특히 하도급계약 「전」에도 열람이 가능하였다는 점이 결정적이다. 계약이 체결되기 전에는 계약상 비밀유지의무가 발생할 여지가 없으므로, 그 단계의 열람 가능 상태는 비밀유지의무 없는 자가 발명을 알 수 있는 상태에 다름 아니다.
- **관리의 정도** — 「자유롭게 열람할 수 있는 상태」는 발명의 주요부에 대한 비밀상태가 해제된 것을 뜻한다. 특정인에게 샘플을 공급한 데 그친 경우(대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1804)와 달리, 여기서는 접근 통제가 존재하지 않았다.

공지는 알 수 있는 「상태」에 놓이면 족하고 「인식」을 요하지 않으므로, 실제로 그 직원들이 도면을 보았는지 여부는 묻지 않는다.

3. 결론

신규성이 인정되지 않는다. 샘플·제작도면은 제29조제1항제1호 전문의 **공지된 발명**에 해당한다(도면의 열람 가능 상태를 두고 반포된 간행물로 구성할 것은 아니다. 제작도면은 공개를 목적으로 복제된 정보 전달매체가 아니어서 간행물의 요건인 공개성을 갖추지 못한다).

구제 가능성 — 그러한 열람 가능 상태가 丁 자신의 관리 아래 초래된 것이라면 **제30조제1항제1호의 자기 공지**로서, 그 날부터 12개월 이내에 출원하면서 **출원서에 취지를 적고 30일 이내에 증명서류를 제출**하면(法 30②) 신규성을 유지할 수 있다.

출제 포인트 정리

설문 1 (40점)

1. 甲은 무권리자가 아니라 **공동출원 의무를 위반한 공유자**다. 이 성질결정을 놓치면 답안 전체가 제34조·제35조 쪽으로 잘못 흘러간다.
2. **제34조·제35조는 제33조제1항 본문 사유 전용이고, 제99조의2는 제44조 위반에도 열려 있다.** 조문 문언에서 곧바로 도출되는 결론이며, 여기서 출원 계속 중·등록 후의 답이 갈린다.
3. 출원 계속 중 — **출원인변경절차 이행청구 + 확정판결 첨부 변경신고(法 38④)**. 정보제공은 저지수 단일 뿐이다.
4. 등록 후 — **제99조의2 지분 이전청구**. 설정등록일 소급(②), 다른 공유자 동의 불요(③), 무효심판 대상 제외(133①Ⅱ 단서)까지 써야 배점이 채워진다. 甲은 악의이므로 제103조의2 법정통상실시권을 주장하지 못한다.
5. 무효심판은 **회복수단이 아니다**라는 평가를 명시할 것.

설문 2 (20 + 5 + 8 + 7점)

6. 20점은 **법리 서술에 배분된 독립 항목**이다. 상실사유 4가지 + 판단기준(대상·시기·지역·방법) + 제30조 예외 + 효과까지 구조를 갖추야 한다.
7. (1)은 「반입 등록 ≠ 서가 진열」이 정답의 열쇠다. 납본·등록을 반포로 읽으면 결론이 뒤집힌다.
8. (2)는 **비밀유지의무자 교부(공지 아님) → 게시(29①Ⅱ 후문 상실) → 30①Ⅱ 구제의 3단 구성**이고, **절차요건이 제1호에만 있다**는 점이 8점 중 변별 요소다.
9. (3)은 **비밀유지의무의 인적 범위와 「계약 전」이라는 시점**에서 결론이 난다. 이 사안형에 대응하는 사건번호를 답안에 적을 필요는 없으며, 공지의 정의와 비밀유지의무 법리만으로 충분히 논증된다.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 특허를 받을 수 있는 권리의 공유(573~576), 무권리자 출원과 정당한 권리자의 보호(815~828), 특허권의 이전청구 (829~834), 신규성(347~380), 공지 예외적용(786~806). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 04

제4회 변호사시험 · 특허법

2015년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 6개

문 제

甲은 염료로 사용하기 위하여 신규물질인 X에 대하여 물질특허를 받았다(위 특허는 유효하게 존속하고 있으며, 甲은 X를 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시 중임). 그후 乙은 X와 관련된 연구를 수행하던 중 X가 살충제로서 탁월한 효과가 있음을 발견하고, 청구항을 「X를 뿌려서 해충을 없애는 방법」으로 하여 특허출원을 하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 질문에 답하시오.

1. 乙이 특허출원한 발명이 특허법상 발명의 성립성을 충족하는지 설명하시오. (10점)
2. 乙의 발명이 특허를 받지 못한 것으로 확정된 경우, 乙이 자신의 발명을 실시하기 위해 취할 수 있는 조치에 대해 설명하시오. (10점)
3. 乙의 발명이 특허를 받은 경우,
 - (1) 甲의 특허발명에 대한 乙의 특허발명의 특허법상 관계에 관하여 논하시오. (15점)
 - (2) 乙이 자신의 특허발명을 실시하기 위해 甲에게 허락을 구하였으나 甲이 허락하지 않을 때, 乙이 甲으로부터 실시권을 허락받기 위해 취할 수 있는 조치에 대해 설명하시오. (10점)
 - (3) 甲이 乙의 특허발명을 실시하기 위한 조치에 대해 설명하시오. (15점)
 - (4) 제3자인 丙이 X를 유효성분으로 한 살충스프레이를 제조 · 판매하는 행위가 甲, 乙의 특허권을 침해하는지를 각각 판단하시오. (20점)

해 설

배점 80점 · 설문 6개(10·10·15·10·15·20). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 甲은 염료로 쓰기 위하여 신규물질 X에 대한 물질특허를 받았고 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시 중이다. 乙은 X가 살충제로서 탁월한 효과가 있음을 발견하고 청구항을 「X를 뿌려서 해충을 없애는 방법」으로 하여 출원하였다.

설문 1 — 乙 출원발명의 발명 성립성 (10점)

1. 발명의 정의와 성립요건

「발명」이란 **자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것**을 말한다(法 2 I). 곧 특허법상 발명이 되려면 i) **자연법칙을 이용한 것**이어야 하고, ii) **기술적 사상**이어야 하며, iii) **창작**이어야 하고, iv) 그 창작의 정도가 **고도**하여야 한다. 자연법칙의 이용과 관련하여서는 통상의 기술자의 수준에서 **일정한 확실성을 가지고 동일한 결과를 반복할 가능성**이 있어야 한다.

2. 용도발명의 성립성

「용도발명」이란 물질로부터 새로운 속성을 발견하고 새로운 용도로 이용하는 과정에서 **창작적 요소**가 존재하는 발명을 말한다.

발견은 기존에 존재하는 것을 단순히 찾아내는 것에 불과하여 **창작성이 없으므로 원칙적으로 발명의 정의 규정(法 2 I)에 부합하지 아니한다**. 그러나 특허법은 비록 발견이더라도 산업상 이용가치가 높은 새로운 용도로 이용하고 그 용도로 이용하는 과정에서 발명으로서 보호할 가치가 인정되는 경우에는 용도발명의 성립성을 인정한다.

성립요건 — i) 새로운 속성의 발견에 **상당한 정도의 노력과 수고**가 요구되고, ii) 새로운 속성의 발견과 **새로운 용도로의 이용과정에 창작적 요소**가 존재하여야 한다. 창작적 요소가 없으면 **단순한 발견**에 불과하고, 새로운 용도로 이용할 수 없으면 구체성을 결여한 **미완성발명**이 될 수 있다.

한편 그 용도가 당시까지 알려지지 않았던 새로운 것이면 **충분하고, 그 물질이나 그 물질의 다른 용도가 출원 이전에 공지되어 있어야 하는 것은 아니다**(특허법원 2012. 8. 24. 선고 2012허2166).

청구항 형식 — 용도발명은 별개의 독립된 카테고리가 아니므로 **물건발명 또는 방법발명 중 어느 한쪽으로 특정**할 수 있다. 교재는 공지물질 DDT에 살충효과가 있음을 발견한 경우 「DDT를 성분으로 하는 살충제」(물건) 또는 「DDT를 살포하여 살충하는 방법」(방법)으로 특정할 수 있다고 든다.

3. 사안의 해결

乙은 **X와 관련된 연구를 수행하던 중 X가 살충제로서 탁월한 효과**가 있음을 발견하였다. X의 살충 효과 그 자체는 자연에 존재하던 속성의 **발견**에 지나지 않아 그것만으로는 발명이 될 수 없다. 그러나 乙은 연구 과정에서 그 속성을 알아내는 데 상당한 노력과 수고를 들였고, 이를 「**X를 뿌려서 해충을 없애는 방법**」이라는 **새로운 용도로 이용**하는 형태로 구체화하였다. 이는 새로운 속성의 발견과 새로운 용도로의 이용과정에 **창작적 요소**가 존재하는 경우로서 용도발명의 성립성이 인정된다.

또한 X를 뿌리면 해충이 제거된다는 것은 자연법칙을 이용한 것이고, 통상의 기술자가 반복하여 동일한 결과를 얻을 수 있는 이상 반복가능성도 인정된다. 청구항을 **방법발명 형식**으로 특정한 것도 용도발명의 허용된 기재방식이다. 甲의 X 물질특허가 이미 존재한다는 사정은 성립성 판단과 무관하다(용도가 새로우면 충분하고 물질이 공지일 것을 요하지 않는다).

결론 — 乙의 출원발명은 **발명의 성립성을 충족한다**.

설문 2 — 특허를 받지 못한 乙이 실시하기 위한 조치 (10점)

1. 문제의 소재

乙의 발명이 특허를 받지 못한 것으로 확정되면 乙은 **특허권자가 아니다**. 그런데 乙이 자신의 방법(X를 뿌려 해충을 없애는 것)을 실시하려면 **X를 사용**하여야 하고, X는 甲의 물질특허의 대상이다. 물질특허의 효력은 그 물질에 미치므로 **어떤 용도로 쓰든** 정당한 권원 없이 X를 생산·사용·양도 등을 하면 甲의 특허권 침해가 된다. 따라서 乙은 甲의 권원 없이는 실시할 수 없다.

2. 취할 수 있는 조치

(1) **甲과의 협의에 의한 실시권 취득** 가장 기본적인 방법은 甲으로부터 **통상실시권을 허락** 받는 것이다(法 102①). 계약으로 정하면 되고, 등록하면 그 등록 후에 특허권을 취득한 자에 대해서도 효력이 발생한다(法 118①).

(2) **통상실시권 허락의 심판(法 138)은 청구할 수 없다** 法 138①은 청구권자를 「**특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자**」로 한정하고, 그 요건도 「해당 특허발명이 法 98에 해당하여」 실시의 허락을 받으려는 경우일 것을 요구한다. 乙은 특허를 받지 못하여 특허권자가 아니므로 이 심판을 청구할 수 없다. 이 점이 설문 3-(2)와 결정적으로 다르다.

(3) **통상실시권 설정의 재정(法 107) — 이 사안에서는 어렵다** 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 法 107①각호의 사유에 해당하고 특허권자와 합리적인 조건으로 협의하였으나 합의가 이루어지지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에 지식재산처장에게 재정을 청구할 수 있다. 각호의 사유는 i) 불가항력 등 정당한 이유 없이 계속하여 **3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우**, ii) 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 **상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나** 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우, iii) 실시가 **공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우**, iv) 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우 등이다.

사안에서 甲은 X를 국내에서 **상당한 영업적 규모로 실시 중**이므로 i)·ii)의 불실시 사유에 해당하지 않는다. 살충제 용도가 공공의 이익을 위하여 특히 필요하다는 등의 특별한 사정이 없는 한 iii)에도 해당하기 어렵다. 따라서 재정에 의한 실시도 기대하기 어렵다.

(4) **그 밖에** 甲의 특허권 **존속기간이 만료**되면 X는 공중의 영역에 놓이므로 그 후에는 자유롭게 실시할 수 있다.

결론 — 乙이 현실적으로 취할 수 있는 조치는 **甲과 협의하여 통상실시권을 허락받는 것이** 사실상 유일하다.

설문 3-(1) — 甲의 특허발명과 乙의 특허발명의 관계 (15점)

1. 이용관계(法 98)

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그와 유사한 디자인을 이용하는 경우에는 그 권리자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(法 98).

이용관계는 후출원 발명을 실시하면 필연적으로 선출원 발명을 실시하게 되는 관계를 말한다. 전형적인 모습이 구성요소의 부가이지만, **선출원 물질발명을 후출원 방법발명이 이용하는 경우도** 이에 해당한다. 이용관계는 특허발명 상호 간은 물론 특허발명과 등록실용신안, 특허발명과 등록디자인 사이에서도 발생한다.

2. 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단은 별개다

발명을 출원하였을 때 특허를 받을 수 있는지(특허요건)와 그 실시가 타인의 특허를 침해하는지(침해 성립요건)는 **전혀 별개의 문제**이다. 특허요건은 선행기술과의 관계에서 동일성·용이성을 보는 것이고, 침해는 선행특허와의 관계에서 그 보호범위에 속하는지를 보는 것이기 때문이다. 따라서 乙이 자기 발명으로 특허를 받았다는 사정만으로 甲의 특허권을 침해하지 않게 되는 것은 아니다.

3. 사안의 해결

甲의 특허는 **신규물질 X에 관한 물질특허**이고, 乙의 특허는 「X를 뿌려서 해충을 없애는 방법」이라는 방법발명(용도발명)이다.

乙이 자신의 방법을 실시하려면 반드시 **X를 사용**하여야 하므로, 乙의 특허발명의 실시는 필연적으로 甲의 물질특허의 실시를 수반한다. 甲의 출원이 앞서므로 乙의 특허발명은 甲의 특허발명을 **이용하는 관계**에 있다(法 98).

그 결과 i) **乙은 甲의 허락 없이는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없고**, 무단으로 실시하면 甲의 특허권 침해가 되어 민·형사상 제재를 받는다. ii) 반대로 **甲도 乙의 허락 없이는 乙의 방법발명을 실시할 수 없다**. 甲의 물질특허는 X 자체에 미칠 뿐이고, 「X를 뿌려서 해충을 없애는 방법」은 乙의 특허발명이기 때문이다. 곧 양자는 서로 상대방의 허락 없이는 각자의 특허발명을 온전히 실시할 수 없는 관계에 놓인다.

설문 3-(2) — 甲이 허락하지 않을 때 乙이 취할 수 있는 조치 (10점)

통상실시권 허락의 심판(法 138)

乙은 이제 **특허권자**이므로 法 138①의 청구권자에 해당한다. 甲이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 허락을 받을 수 없을 때에는, 乙은 **자기의 특허발명의 실시**에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

인용요건

- ① 해당 특허발명이 **法 98에 해당**하여 실시의 허락을 받으려는 경우일 것. 설문 3-(1)에서 본 대로 乙의 방법발명은 甲의 물질특허를 이용하는 관계에 있다.
- ② 그 타인이 **정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없을 것**(法 138①). 「정당한 이유」란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다. 후출원 권리자는 **심판청구 전에 협의를 통해 실시허락을 받으려는 노력**을 하여야 하고, 그러하지 아니하면 부적법한 심판청구로서 심결각하된다(法 142). 사안에서 乙은 이미 甲에게 허락을 구하였으므로 이 요건은 충족된다.
- ③ **자기의 특허발명의 실시**에 필요한 범위일 것(法 138①). 乙은 「X를 뿌려서 해충을 없애는 방법」의 실시

효과 — 허락받은 乙은 甲에게 **대가를 지급**하여야 하고, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없으면 **공탁**하여야 한다(法 138④). 대가를 지급하지도 공탁하지도 아니하면 그 특허발명을 실시할 수 없다(法 138⑤).

설문 3-(3) — 甲이 乙의 특허발명을 실시하기 위한 조치 (15점)

1. 甲도 乙의 허락 없이는 실시할 수 없다

乙의 특허발명은 「X를 뿌려서 해충을 없애는 방법」이다. 甲의 물질특허는 X 자체에 관한 것이므로, 甲이 X를 살충 목적으로 뿌리는 행위를 하면 그것은 **乙의 방법발명의 실시**가 되어 乙의 특허권을 침해하게 된다.

2. 취할 수 있는 조치

(1) **乙과의 협의에 의한 실시권 취득** 甲은 乙로부터 통상실시권을 허락받을 수 있다(法 102①).

(2) **크로스 라이선스** — **法 138③의 통상실시권 허락 심판** 특허법은 이용관계에서 선출원 권리자를 위한 별도의 길을 두고 있다. 곧 **法 138①의 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우**, 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는, **통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다**(法 138③).

곧 설문 3-(2)에서 乙이 法 138①의 심판으로 甲의 물질특허에 대한 통상실시권을 허락받은 상황을 전제로, 이번에는 **甲이 乙의 방법특허에 대하여 法 138③의 심판을 청구**할 수 있다. 이때에도 甲은 乙에게 **대가를 지급**하여야 한다(法 138④).

(3) 유의 — 法 138③은 「허락한 자」에게 열린 길이다. 조문상 이 심판은 法 138①에 따라 통상실시권을 «허락한 자»를 청구권자로 한다. 따라서 乙이 아직 法 138①의 심판을 청구하지 않았거나 甲이 임의로 실시허락을 해 준 것에 그친 단계에서는 이 규정을 그대로 원용하기 어렵고, 그 경우 甲으로서는 乙과의 협의에 의한 실시권 취득을 구하는 수밖에 없다.

(4) 재정(法 107) 乙이 자신의 방법발명을 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시하지 아니하는 등 法 107①각호의 사유가 있고 협의가 이루어지지 않으면, 甲은 지식재산처장에게 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수도 있다.

설문 3-(4) — 丙의 살충스프레이 제조·판매가 甲·乙의 특허권을 침해하는지 (20점)

1. 甲의 물질특허(X)에 대하여 — 침해한다

물건(물질)의 발명에서 「실시」란 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ가목).

물질특허의 효력은 그 물질 자체에 미치므로 어떤 용도로 쓰이는지를 묻지 않는다. 甲이 X를 염료 용도로 특허받았다고 하여 그 효력이 염료 용도에 한정되는 것이 아니다.

丙은 X를 유효성분으로 한 살충스프레이를 제조·판매하고 있으므로, 그 제조 과정에서 X를 생산하거나 사용하고 이를 포함한 제품을 양도하는 것이어서 甲의 물질특허를 업으로 실시하는 것이 된다. 丙에게 정당한 권원이 있다는 사정이 없으므로 丙의 행위는 甲의 특허권을 침해한다.

2. 乙의 방법특허(X를 뿌려서 해충을 없애는 방법)에 대하여

(1) 직접침해는 성립하지 않는다. 방법의 발명에서 「실시」란 그 방법을 사용하는 행위 등을 말한다(法 2Ⅲ나목). 丙은 살충스프레이를 제조·판매할 뿐이고 스스로 X를 뿌려 해충을 없애는 방법을 사용하는 것이 아니다. 따라서 丙의 행위는 乙 방법발명의 직접적인 실시에 해당하지 않는다.

(2) 간접침해가 문제 된다. 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하면 특허권을 침해한 것으로 본다(法 127Ⅱ).

「에만」이라는 문언은 그 물건에 다른 용도(타용도)가 없을 것을 요구한다. 카트리지 사건은 소모부품이라도 i) 특허발명의 본질적 구성요소이고, ii) 타용도로는 사용되지 아니하며, iii) 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수 없고, iv) 교체가 예정되어 있으며, v) 특허권자가 따로 제조·판매하고 있다면 「생산에만 사용하는 물건」에 해당한다고 하였다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580). 또한 타용도가 없는 물건인 이상 그 자체에 특허성이 있더라도 간접침해이고, 타용도의 존부를 판단하는 기준시점은 침해금지청구를 소송상 행사할 때에는 사실심 변론종결 시이다.

(3) 사안의 검토. 丙이 제조·판매하는 것은 **살충스프레이**로서, 이를 사용하는 방법은 곧 X를 뿌려 해충을 없애는 것이다. 그 스프레이에 살충 외의 다른 용도가 나타나 있지 않다면 **乙 방법발명의 「실시에만 사용하는 물건」**에 해당하여 그 제조·판매는 **간접침해**가 된다. 반대로 그 스프레이가 살충 외의 용도로도 사용될 수 있다면 「에만」 요건이 깨져 간접침해는 부정된다.

(4) 부수 논점 — **직접침해와의 관계**. 스프레이를 사서 실제로 뿌리는 최종 소비자가 이를 **개인적·가정적으로** 사용한다면 「업으로서」의 실시가 아니어서 직접침해가 성립하지 않는다. 이때에도 丙에게 간접침해를 인정할 것인지에 관하여는, 직접침해가 있어야 간접침해가 성립한다는 **종속설**과 간접침해의 요건만 갖추면 된다는 **독립설**이 대립한다. 다만 이 유형에 관하여는 간접침해를 인정하지 않으면 간접침해 규정의 실질적 실효성이 없어진다는 입장이 다소 우위에 있는 것으로 보인다.

3. 결론

丙의 살충스프레이 제조·판매는 **甲의 물질특허를 직접 침해**하고, 그 스프레이에 살충 외의 타용도가 없는 한 **乙의 방법특허에 대하여는 간접침해**에 해당한다. 곧 丙은 甲과 乙 모두에 대하여 책임을 질 수 있다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2012허2166	2012-08-24	설문1 용도발명의 성립성·용도의 신규성
98후2580	2001-01-30	3-(4) 「실시에만 사용하는 물건」

교재: 리담특허법 제25판 — 발명의 정의와 성립요건(58~62), 용도발명(93~94), 이용·저촉발명(1592, 1607~1613), 통상실시권 허락의 심판(1897~1898), 간접침해(1642~1643, 1699~1702), 침해 구제수단(50, 1645~1646).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제2·98·102·107·118·127·138·142조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 발명의 정의와 성립요건(58~62), 용도발명(93~94), 이용·저촉발명(1592, 1607~1613), 통상실시권 허락의 심판(1897~1898), 간접침해(1642~1643, 1699~1702), 침해 구제수단(50, 1645~1646). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 05

제5회 변호사시험 · 특허법

2016년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 7개

문 제

청색LED는 발광을 위한 전력효율이나 그 수명 등 여러 가지 면에서 매우 탁월한 조명이어서 최근 여러 산업분야에서 이용가치가 매우 높지만 아직 발명이 완성되지 않았다. 뿐만 아니라 다수의 전문 기술자들이 기술개발을 시도하였으나 난관이 많아 기술진척이 안 된 분야이다. 이에 甲은 청색LED 발명을 완성한 후 특허권을 취득하면 상업적으로 성공하여 많은 돈을 벌 수 있을 것으로 생각하였다. 특히 청색LED 기술은 아직 선행연구가 성공적으로 진행되지 않아 선행문헌이나 선행기술이 매우 부족하였다. 甲은 여러 기술적인 난관은 있었지만 자신이 평생의 노력으로 연구개발하고 있던 분야여서 종국적으로는 발명을 완성할 것이라고 생각하고 있었다. 그러나 甲은 자금이나 연구시설 등의 부족으로 인해 곤란을 겪고 있었다. 그러던 중 甲의 친구인 乙이 자신과 협력하여 발명을 완성해 보자고 제의하였고, 이에 甲은 흔쾌히 동의하였다. 이후 乙은 자금과 연구시설 등을 지원하였을 뿐만 아니라 甲의 기술개발 과정에서도 연구방향이나 기술적 조언 등을 해주어 결국 청색LED 기술에 대한 발명(이하 ‘청색LED 발명’이라 한다)이 완성되었다. (단, 甲과 乙 사이에 아래 질문사항에 대하여 아무런 계약내용은 없다.)

1. 甲(또는 乙이 공동으로)이 발명한 청색LED 발명이 특허를 받기 위한 ‘특허요건’을 충족하는지 설명하시오. (30점)
2. 甲이 청색LED 발명에 대해 단독으로 특허출원을 하려고 하자, 乙은 자신이 공동발명자라고 하면서 공동출원할 것을 주장하였다.
 - 가. 청색LED 발명이 甲과 乙의 공동발명에 해당하기 위한 요건을 설명하시오. (10점)
 - 나. 공동발명이라고 할 경우에 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 乙의 동의 없이 제3자에게 양도할 수 있는지 설명하시오. (5점)
3. 청색LED 발명이 甲의 단독발명이라고 할 때, 다음 각 사례에서 乙이 乙 명의로 특허를 적법하게 취득하기 위하여 취하여야 하는 조치를 설명하시오.
 - 가. 甲이 청색LED 발명에 대하여 특허출원하기 전에 乙이 특허를 받을 수 있는 甲의 권리를 승계한 경우 (5점)
 - 나. 甲이 청색LED 발명에 대하여 특허출원한 후에 乙이 특허를 받을 수 있는 甲의 권리를 승계한 경우 (5점)
 - 다. 甲이 청색LED 발명에 대하여 특허등록을 받은 후에 乙이 甲의 특허권을 승계한 경우 (5점)

4. 甲과 乙이 청색LED 발명에 대하여 공동발명으로 특허를 등록한 경우, 공동권리자가 된 甲과 乙은 청색LED 발명에 대한 자신들의 지분권에 기초하여 자유롭게 권리를 실시하여 수익을 확보하고자 한다. 甲은 청색LED 발명에 관하여 자신이 가지고 있는 권리에 대하여 변호사인 丙에게 자문을 구하였다. 丙은 甲에게 특허권의 공유관계의 특징을 설명하고자 한다. 그 내용을 기술하시오. (20점)

해 설

배점 80점 · 설문 7개(30·10·5·5·5·5·20). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 청색LED는 이용가치가 높으나 **선행문헌·선행기술이 매우 부족**하고 다수의 전문 기술자가 시도했으나 **기술진척이 없던** 분야. 甲은 평생 연구해 왔으나 자금·연구시설이 부족했고, 친구 **乙이 자금과 연구시설을 지원하면서 연구방향이나 기술적 조언도** 해주어 발명이 완성되었다. 甲·乙 사이에 계약은 없다.

설문 1 — 청색LED 발명의 특허요건 (30점)

1. 발명의 성립과 특허요건의 체계

특허를 받으려면 i) **산업상 이용할 수 있는 발명**으로서(法 29①본문), ii) 특허출원 전에 공지·공연 실시되거나 반포된 간행물에 게재되는 등의 사유가 없어야 하고(**신규성**, 法 29①각호), iii) 통상의 기술자가 그 공지기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니어야 한다(**진보성**, 法 29②).

2. 산업상 이용가능성(法 29①본문)

산업상 이용가능성은 그 발명이 산업에서 반복하여 실시될 수 있는 것을 뜻한다. 청색LED는 발광을 위한 전력효율이나 수명 등에서 탁월한 **조명**으로서 여러 산업분야에서 이용가치가 높으므로 산업상 이용가능성이 인정됨에 의문이 없다. 인체를 구성요소로 하는 의료행위와 같이 산업상 이용가능성이 부정되는 유형에도 해당하지 않는다.

3. 신규성(法 29①각호)

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(法 29① I), 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명(法 29① II)은 특허를 받을 수 없다. 「신규성」이란 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 것, 곧 객관적 창작성이 있는 것을 말한다.

사안에서 청색LED 발명은 **아직 발명이 완성되지 않은** 분야로서 다수의 전문 기술자가 시도 하였으나 기술진척이 없었고 **선행문헌이나 선행기술이 매우 부족**하였다. 甲(또는 甲·乙)이 완성한 발명과 동일한 발명이 출원 전에 공지·공연실시되거나 간행물에 게재되었다고 볼 사정이 없으므로 **신규성이 인정된다**.

4. 진보성(法 29②)

(1) 판단의 전제 진보성 판단의 대상은 산업상 이용가능성과 신규성을 만족하는 발명이어야 한다(法 29② 「제1항에도 불구하고」의 해석). 신규성이 없으면 그 사유만으로 특허를 받을 수 없으므로 진보성을 판단할 필요가 없다.

(2) 자의적 판단의 배제 진보성 판단은 객관적 타당성에 따라야 하고 판단기준의 고정화를 지양하여야 하며, 출원인의 입장과 기술분야의 특수성을 고려하여야 한다. 특히 **사후적 고찰을 하여서는 안 된다**. 통상의 기술자가 해당 발명의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 극히 많으므로, 출원 전의 상태로 돌아가 그 지식을 알지 못한다는 전제에서 진보성을 따져야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

(3) 사안 청색LED 분야는 i) 다수의 전문 기술자들이 기술개발을 시도하였으나 **난관이 많아 기술진척이 안 된** 분야이고, ii) **선행문헌이나 선행기술이 매우 부족**하며, iii) 甲도 여러 기술적 난관을 겪었다. 이는 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이 아님을 뒷받침하는 사정이다. 나아가 특허를 취득하면 **상업적으로 성공**할 것으로 예상되는 발명이라는 점도 진보성을 뒷받침하는 자료가 될 수 있다. 따라서 **진보성이 인정된다**.

이때 완성된 청색LED 발명의 구성을 알고 난 뒤 그것이 자명해 보인다는 이유로 쉽게 발명할 수 있었다고 판단하는 것은 금지되는 사후적 고찰에 해당한다.

5. 결론

청색LED 발명은 산업상 이용가능성·신규성·진보성을 모두 충족하므로, 명세서 기재요건 등 다른 거절 이유가 없는 한 **특허를 받을 수 있다**.

설문 2-가 — 공동발명의 요건 (10점)

1. 공동발명의 의의와 요건

「공동발명」이란 **2명 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 함께 완성한 발명**을 말한다. 공동발명자가 되기 위해서는 **기술적 사상의 창작에 실질적으로 협력하였다는 객관적 요건**과 **상호 협력하여 발명행위를 수행한다는 주관적 요건**이 필요하다.

2. 판단기준

판례는 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 보아, 다음과 같이 나눈다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178).

공동발명자에 해당하지 않는 경우

- 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 경우
- 연구자를 일반적으로 관리한 경우

- 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우
- 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 경우

공동발명자에 해당하는 경우

- 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 **구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완**한 경우
- 실험 등을 통하여 새로운 착상을 **구체화**한 경우
- 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 **구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한** 경우

「실질적 협력」이란 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미하므로, 단순한 보조자·관리자·위탁자·자본주는 공동발명자가 되지 못한다.

3. 사안의 검토

乙의 관여는 두 부분으로 나누어 보아야 한다.

- **자금과 연구시설의 지원** — 이는 「자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁한」 것에 그 치므로, 그 자체만으로는 공동발명자가 되는 근거가 되지 못한다.
- **연구방향이나 기술적 조언** — 이 부분이 「발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 **구체적인** 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한」 정도에 이르렀다면 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 것이어서 공동발명자에 해당한다. 반대로 일반적인 지식의 조언이나 제시를 주기만 한 정도에 그친다면 공동발명자가 아니다.

곧 乙이 공동발명자인지는 **그 조언·지도가 구체적이어서 발명을 가능하게 한 정도인지**에 따라 갈리며, 자금·시설 지원 부분은 그 판단에 보태어지지 않는다.

설문 2-나 — 공동발명일 때 乙의 동의 없는 지분 양도 가부 (5점)

2명 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 **공유**한다(法 33②).

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 **각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다**(法 37③). 이는 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력 여하가 다른 공유자의 이해관계에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 다만 지분의 상속은 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는다.

사안 — 청색LED 발명이 甲과 乙의 공동발명이라면 특허를 받을 수 있는 권리는 甲·乙의 공유 이므로, 甲은 **乙의 동의 없이**는 자신의 지분을 제3자에게 양도할 수 없다. 甲·乙 사이에 아무런 계약이 없더라도 이는 법률의 규정에 따른 제한이므로 마찬가지이다.

설문 3 — 乙이 자기 명의로 적법하게 특허를 취득하기 위한 조치 (15점)

甲의 단독발명임을 전제로, 승계 시점에 따라 알아야 할 절차가 달라진다.

가. 특허출원 전에 승계한 경우 (5점)

특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(法 37①) 乙은 甲으로부터 이를 승계할 수 있다. 다만 **특허출원 전에 이루어진 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다**(法 38①). 출원 전의 이 권리는 공시수단이 없고 무체재화여서 점유도 있을 수 없기 때문이다.

따라서 乙은 **자기 명의로 특허출원을 하여야 한다**. 여기서 「제3자」란 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말하며, 권리를 양도한 甲은 제3자에 포함되지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087).

나. 특허출원 후에 승계한 경우 (5점)

특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 **특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다**(法 38④). 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정하여 심사의 편의성과 신속성을 도모하기 위함이다.

따라서 乙은 **특허출원인변경신고**를 하여야 하며, 그 신고서에는 변경의 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 그 특허출원의 **등록 전까지** 제출하여야 한다. 신고를 하지 않은 상태에서는 양수의 효력이 발생하지 않는다(대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321).

다. 특허등록 후에 특허권을 승계한 경우 (5점)

특허권은 이전할 수 있다(法 99①). 다만 **특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)은 등록하여야만 효력이 발생한다**(法 101① I).

따라서 乙은 甲으로부터 특허권을 양수한 뒤 **이전등록**을 마쳐야 비로소 특허권자가 된다. 이전등록 신청은 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청함이 원칙이나, 등록의무자의 승낙서를 첨부하거나 판결이 있는 경우 등에는 등록권리자가 단독으로 신청할 수 있다.

설문 4 — 특허권 공유관계의 특징 (20점)

1. 의의와 특수성

「특허권의 공유」란 **하나의 특허권을 2명 이상이 지분에 의하여 공동으로 소유하는 것**을 말한다. 특허권의 객체인 발명은 무형인 기술적 사상의 창작으로서 **점유를 수반하지 않으므로 수인이 동시에 실시할 수 있는** 등 유체재산권과는 다른 특수성을 지닌다. 그래서 특허법은 민법의 공유 규정을 준용하면서도 이러한 특수성을 고려한 특별규정(法 99②③④)을 두고 있다.

2. 법적 성질

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 있고 전용실시권 설정·통상실시권 허락을 할 수 있어 그 범위에서 **합유와 유사한 성질**을 가진다. 그러나 이러한 제약은 특허권이 무체재산권이라는 특수성에서 유래한 것일 뿐이고, 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성한다고 볼 수 없으며 특허법에 공유를 합유로 본다는 명문 규정도 없으므로, **특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법상 공유 규정이 적용된다**(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567).

중전 판례는 특허의 공유관계를 민법 제273조의 합유에 준하는 것이라고 하였으나(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111), 이는 공유관계 전체가 아니라 **法 99②·④의 내용만이 합유에 준한다**는 취지로 해석된다.

3. 구체적 내용

(1) 지분의 양도·질권 설정 — 전원의 동의를 요한다. 각 공유자는 **다른 공유자 모두의 동의를 받아야만** 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(法 99②). 등록 전 단계에서도 같다(法 37③).

(2) 자기 실시 — 동의를 요하지 않는다. 각 공유자는 **계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다**(法 99③). 발명은 점유를 수반하지 않아 수인이 동시에 실시할 수 있기 때문이며, 이 점이 민법상 공유가 지분 비율로 사용하는 것과 다르다.

(3) 전용실시권 설정·통상실시권 허락 — 전원의 동의를 요한다. 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 99④). 타인이 실시하게 되면 다른 공유자의 이익에 직접 영향을 미치기 때문이다.

(4) 공동출원·공동심판 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이면 공유자 **모두가 공동으로** 특허출원을 하여야 하고(法 44), 이를 위반하면 거절이유·무효사유가 된다. 특허권의 공유자가 그 특허권에 관하여 심판을 청구할 때에도 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③).

(5) 분할청구 민법상 합유는 분할청구가 불가능하지만, 특허권의 공유에서는 **분할청구가 가능하다**.

4. 사안에 대한 조언

丙은 甲에게 다음과 같이 설명하면 된다. 甲과 乙은 **각자 상대방의 동의 없이 청색LED 발명을 스스로 실시하여 수익을 얻을 수 있다**(法 99③). 그러나 i) 자기 지분을 제3자에게 양도하거나 그 지분에 질권을 설정하는 것(法 99②), ii) 제3자에게 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 것(法 99④)은 **상대방 전원의 동의가 있어야** 한다. 甲·乙 사이에 아무런 계약이 없으므로 法 99③의 「계약으로 특별히 약정한 경우」에도 해당하지 않아 자기 실시는 자유롭다.

곧 스스로 실시하여 수익을 얻는 것은 자유롭지만, 지분을 팔거나 남에게 실시하게 하려면 서로의 동의가 필요하다는 것이 공유관계의 핵심이다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2006후138	2007-08-24	설문1 사후적 고찰 금지
2007후3660	2009-11-12	설문1 사후적 고찰 금지
2009다75178	2011-07-28	설문2-가 공동발명자 판단기준
2020후10087	2020-05-14	설문3-가 法 38①의 제3자
2015후321	2017-11-23	설문3-나 출원인변경신고의 효력
2002후567	2004-12-09	설문4 공유의 법적 성질
87후111	1987-12-08	설문4 종전 판례(합유에 준함)

교재: 리담특허법 제25판 — 산업상 이용가능성(335), 신규성(346~348), 진보성 판단방법(403~404), 공동발명(157~158), 권리의 이전·승계(564~569), 특허권의 공유(1749~1750).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·33·37·38·44·99·101·139조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 산업상 이용가능성(335), 신규성(346~348), 진보성 판단방법(403~404), 공동발명(157~158), 특허를 받을 수 있는 권리의 이전·승계(564~569), 특허권의 공유(1749~1750). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 06

제6회 변호사시험 · 특허법

2017년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 7개

문 제

甲은 2012. 12. 3.부터 구성요소 A+B가 특징부로 되어 있는 전기밥솥 X를 생산하고 있다.

乙은 구성요소 A가 특징부로 되어 있는 전기밥솥 Y를 발명하여 그에 관하여 2013. 2. 1. 특허출원을 하였는데, 위 출원은 2014. 8. 1. 무렵 출원공개되었고, 2015. 3. 23. 특허권이 설정등록되었다(이 때, 구성요소 A와 A'는 전기밥솥 분야에서 통상의 기술자라면 단순한 설계변경을 통하여 상호 치환할 수 있는 정도의 것이라 가정한다).

그 후 乙은 위 특허권을 기초로 2016. 3. 24. 무렵 丙에게 실시권을 허락하였다.

1. 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 법적 조치(승소 가능성 불문)

가. 출원공개가 있는 후 특허권 설정등록 이전의 甲의 실시행위로 인한 乙의 경제적 손실을 전보하기 위하여 「특허법」상 乙에게 인정되는 실체적 권리, 그 권리행사의 방법 및 시기에 관하여 설명하시오. (10점)

나. 특허권 설정등록 이후의 甲의 실시행위에 대하여 乙이 취할 수 있는 민·형사적 구제수단을 약술하시오. (10점)

2. 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 법적 조치 또는 항변(승소 가능성 불문)

가. 甲이 乙을 상대로 특허무효심판을 청구하는 경우에, 특허무효사유 중 위 사안에서 문제될 수 있는 특허요건(신규성, 진보성)에 대하여 검토하시오. (15점)

나. 乙이 甲을 상대로 제기한 특허권침해금지청구의 소에서 甲이 특허무효를 주장할 수 있는지 여부를 논하시오. (15점)

다. 乙이 甲을 상대로 제기한 특허권침해에 기한 손해배상청구의 소에서, 甲이 乙의 특허출원 이전에 이미 관련 기술을 실시하고 있었다는 점에서 甲이 항변사유로 주장할 수 있는 법정실시권에 대하여 설명하시오. (10점)

3. 丙의 법적 지위와 관련하여 아래의 문제에 답하시오.

가. 다음의 각 경우에 있어서, 丙이 甲에 대하여 특허권침해금지를 청구할 수 있는지를 설명하시오. (10점)

(1) 丙이 전용실시권자인 경우

(2) 丙이 통상실시권자인 경우

나.다음의 각 경우에 있어서, 丙의 실시권이 존속하는 동안 乙이 특허권을 제3자 丁에게 양도하였다면, 丙이 그 실시권의 존재를 丁에게 대항할 수 있는지를 설명하시오. (10점)

- (1) 丙이 전용실시권자인 경우
- (2) 丙이 통상실시권자인 경우

해 설

배점 80점 · 설문 7개(10·10·15·15·10·10·10). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 甲은 2012. 12. 3.부터 구성요소 A+B인 전기밥솥 X를 생산. 乙은 A'를 특징부로 하는 전기밥솥 Y를 2013. 2. 1. 출원, 2014. 8. 1. 출원공개, 2015. 3. 23. 설정등록. A와 A'는 통상의 기술자가 단순한 설계변경으로 상호 치환 가능한 정도. 乙은 2016. 3. 24. 丙에게 실시권을 허락했다.

설문 1-가 — 출원공개 후 설정등록 전 실시에 대한 권리 (10점)

1. 보상금청구권(法 65)

(1) 의의 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고(法 65①), 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(法 65②).

「실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액」으로 정한 것은 아직 등록되지 않았다는 이유로 보상금액이 부당히 낮게 책정되는 것을 막기 위함이다.

(2) 요건

- ① 출원공개가 있을 것. 공개된 취지를 게재한 공개특허공보가 발행되어야 한다.
- ② 출원인이 서면으로 경고하거나, 제3자가 출원공개된 발명임을 알고 있을 것. 경고 후 보정으로 청구범위가 확장·변경되었으면 그 부분에 대하여 다시 경고하여야 하나, 감축·삭제된 경우에는 재경고가 필요 없다.
- ③ 정당한 권원 없는 제3자가 업으로서 출원발명을 실시할 것. 「정당한 권원」이란 출원공개된 발명이 특허되어도 그 특허권에 구속되지 않는 사유로서, 직무발명에 의한 통상실시권, 선사용에 의한 통상실시권 등이 이에 해당한다.

2. 권리행사의 방법과 시기

(1) 방법 출원인은 실시자에게 서면으로 경고한 뒤(法 65①), 경고를 받거나 공개 사실을 안 때부터 설정등록 시까지의 실시에 대하여 보상금의 지급을 청구한다(法 65②). 이 청구권을 행사할 때에는 法

127·129·132 및 민법 제760조·제766조가 준용되며, 이때 민법 제766조 제1항의 「피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날」은 **해당 특허권의 설정등록일**로 본다(法 65⑤).

(2) 시기 — 설정등록 후에만 행사할 수 있다. 보상금청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(法 65③). 보상금청구권은 경고받거나 안 때부터 발생하지만 특허권의 설정등록이 되지 않으면 소멸하므로(法 65⑥) 등록 전에는 불확정 상태이고, 등록 전 행사를 허용하면 산업계의 혼란과 불필요한 분쟁을 낳기 때문이다.

(3) 특허권과의 독립성 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다(法 65④). 곧 **시기를 기준으로**, 출원공개 후 경고받거나 안 때부터 설정등록 시까지의 실시에 대해서는 보상금청구권을, 설정등록 후의 실시에 대해서는 특허권에 기한 민·형사상 조치를 각각 행사할 수 있다.

3. 사안의 해결

乙의 출원은 **2014. 8. 1. 출원공개**되고 **2015. 3. 23. 설정등록**되었으므로, 그 사이 기간의 甲의 실시에 대하여 乙에게 인정되는 실체적 권리는 **보상금청구권**이다.

乙은 甲에게 특허출원된 발명임을 **서면으로 경고**하고, 甲이 그 경고를 받거나 출원공개 사실을 안 때부터 2015. 3. 23.까지의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액 상당의 보상금을 청구할 수 있다. 다만 그 **행사는 설정등록일인 2015. 3. 23. 이후**에야 가능하다.

한편 甲이 뒤에서 볼 **선사용에 의한 통상실시권**(法 103)을 가진다면 甲은 「정당한 권원」 있는 자이므로 보상금청구권은 성립하지 않는다.

설문 1-나 — 설정등록 이후 실시에 대한 민·형사적 구제수단 (10점)

(1) 침해금지 및 예방청구권(法 126①) 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 특허권은 물권에 준하는 권리이므로 그 지배상태가 침해된 때 물권적 청구권과 같은 권리가 인정되며, 현재 또는 장래의 침해에 대한 것이라는 점에서 과거의 침해에 대한 손해배상·부당이득반환 청구와 구별된다.

(2) 폐기·제거 등 청구(法 126②) 위 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 함께 청구할 수 있다. 乙은 전기밥솥 X의 폐기와 그 생산설비의 제거를 청구할 수 있다.

(3) 손해배상청구권(法 128) 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있고(法 128①), 침해자의 과실은 法 130에 의하여 추정된다. 손해액에 관하여는 양도수량에 따른 산정(法 128②), 침해자 이익액의 손해액 추정(法 128④), 실시료 상당액(法 128⑤) 등의 규정이 있다.

(4) 신용회복청구권(法 131) 법원은 고의나 과실로 특허권을 침해하여 특허권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대하여 특허권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 신용회복에 필요한 조치를 명할 수 있다.

(5) **형사상 조치** 특허권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하고 (法 225①), 이 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(法 225②).

다만 甲에게 선사용권 등 정당한 권원이 인정되면 침해가 성립하지 않으므로 위 구제수단은 모두 배제된다.

설문 2-가 — 특허무효사유로서 신규성·진보성 (15점)

1. 신규성(法 29①)

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 **공연히 실시된 발명**은 특허를 받을 수 없다 (法 29① I). 「공연실시」란 실시에 의하여 발명이 불특정인에게 공연히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 말한다.

이때 대비되는 두 발명이 문언상 완전히 같지 않더라도, **구성의 차이가 주지·관용기술의 부가·삭제·변경에 불과하고 새로운 효과도 발생하지 아니한다면 실질적으로 동일**하여 신규성이 부정된다.

2. 진보성(法 29②)

특허출원 전에 통상의 기술자가 法 29①각호의 발명에 의하여 **쉽게 발명할 수 있으면** 특허를 받을 수 없다. 진보성 판단의 대상은 산업상 이용가능성과 신규성을 만족하는 발명이어야 하며, 판단은 객관적 타당성에 따르되 **사후적 고찰을 해서는 안 된다**(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138).

3. 사안의 해결

甲은 2012. 12. 3.부터 구성요소 A+B인 전기밥솥 X를 **생산**하고 있었고, 乙의 출원일은 2013. 2. 1.이다. 따라서 甲의 X는 乙의 특허출원 전에 국내에서 **공연히 실시된 발명**에 해당할 수 있다(다만 그 실시로 발명의 주요부에 대한 비밀상태가 해제되었는지는 별도로 확인을 요한다).

- **신규성** — A와 A'는 통상의 기술자라면 **단순한 설계변경을 통하여 상호 치환할 수 있는** 정도의 것이다. 이는 구성의 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그로 인하여 새로운 효과가 생겼다고 볼 사정도 없는 경우이므로, 乙의 A'는 甲이 공연히 실시한 A와 **실질적으로 동일**하다고 볼 수 있다. 그렇다면 乙의 특허발명은 **신규성이 부정된다**.
- **진보성** — 설령 실질적 동일성이 인정되지 않아 신규성이 부정되지 않는다고 보더라도, A'는 공연히 실시된 A로부터 **단순한 설계변경**으로 도출되는 것이므로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것에 해당하여 **진보성이 부정된다**.

결론: 乙의 특허는 法 29① i 또는 적어도 法 29②에 위반되어 특허무효사유(法 133① I)에 해당하므로, 甲의 특허무효심판 청구는 이유가 있다.

설문 2-나 — 침해소송에서 甲이 특허무효를 주장할 수 있는지 (15점)

1. 원칙

등록주의를 관철하여 법적 안정성을 도모하기 위하여, 특허에 무효사유가 있더라도 **무효심결이 확정되기 전에는** 그 특허권이 유효한 것으로 다루어지는 것이 원칙이다.

2. 신규성이 없는 경우

특허발명이 공지기술과 동일하여 신규성이 없음에도 착오로 등록되었으면, **무효심결이 확정되어 특허권이 소멸하기 전이라도 그 보호범위를 인정할 수 없다**는 것이 종래부터의 판례이다 (대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 등). 이를 강학상 **특허권 하자의 항변(무효의 항변)**이라 한다.

3. 진보성이 없는 경우 — 판례의 변천

침해소송을 담당하는 법원이 진보성 결여를 심리·판단할 수 있는지에 관하여 종래 판결이 나뉘어 있었으나(부정: 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 / 긍정: 대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225; 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699; 대법원 1997. 8. 22. 선고 97후68), **대법원 1998. 10. 27. 선고 97후 2095 판결 이래로는** 진보성 결여를 심리·판단할 수 없다는 입장이 유지되어 왔다.

그러나 **대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결**은, 진보성이 없어 본래 공중에 개방되어야 할 기술에 잘못 등록이 이루어졌음에도 제한 없이 독점시키면 공공의 이익을 훼손하고 특허법의 입법목적에 배치되며 실질적 정의와 형평에도 어긋난다는 점을 들어, **진보성이 부정되어 무효로 될 것이 임의 명백한 경우 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고** 하였고, 법원은 그 권리남용 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다고 하였다.

	종전 판례(97후2095 등)	2010다95390 전합
진보성 결여로 권리범위를 부정하는지	×	×
침해소송에서 진보성을 심리할 수 있는지	×	○
권리행사가 가능한지	○	무효 명백 + 특별한 사정 없으면 권리남용으로 불가

4. 자유기술의 항변

이와 별도로 甲은 **자유기술의 항변**을 할 수 있다. 무효의 항변이 「공지기술 vs 특허발명」을 대비하는 것인 데 비하여, 자유기술의 항변은 「공지기술 vs 확인대상발명」을 대비하여 자신이 실시하는 기술이 공지기술과 동일하거나 그로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 특허발명과 대비할 필요 없이 침해가 아

니라고 주장하는 것이다. 무효의 항변은 동일성의 경우에만 권리범위를 부정하지만, 자유기술의 항변은 **용이성의 경우에도 인정**된다는 점에서 차이가 있다.

5. 사안의 해결

甲은 침해소송에서 무효심판 절차를 거치지 않고도 다음을 주장할 수 있다.

- **신규성 부분** — A가 공연실시된 A와 실질적으로 동일하다면 무효심결 확정 전이라도 乙 특허의 보호범위를 인정할 수 없으므로, 법원은 이를 심리·판단할 수 있다.
- **진보성 부분** — A가 A로부터 단순 설계변경으로 도출되어 **무효로 될 것임이 명백**하다면, 乙의 침해금지청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하고, 법원은 그 전제로서 진보성을 직접 심리·판단할 수 있다.
- **자유기술의 항변** — 甲이 실시하는 A+B가 공지기술과 동일하거나 그로부터 쉽게 도출할 수 있다면 특허발명과 대비할 필요 없이 침해가 아니라고 주장할 수 있다.

설문 2-다 — 선사용에 의한 통상실시권(法 103) (10점)

1. 의의와 요건

특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는, 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 **통상실시권을 가진다**(法 103). 요건을 나누면 다음과 같다.

- ① **주관적 요건** — 특허출원 시에 그 출원된 발명의 내용을 **알지 못하였을 것**. 곧 모인(冒認)이 아니어야 한다.
- ② **발명의 유래** — 스스로 그 발명을 하였거나, 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되었을 것.
- ③ **객관적 요건** — 특허출원 시에 **국내에서** 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 이를 준비하고 있을 것.

2. 성질과 효력

선사용권은 **법정실시권**으로서 법률이 정한 성립요건을 만족한 때 효력이 발생하며, 그 요건의 충족은 **실시권자가 증명**하여야 한다. 법정실시권은 **설정등록을 하지 않더라도 제3자에 대한 대항요건을 구비한다**(法 118②). 그 범위는 法 102②에 따라 법률이 정한 범위, 곧 **실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위**이다.

선사용권은 특허권자와 선사용자 사이의 형평을 도모하기 위하여 인정되는 것으로서, 선사용자는 그 범위에서 특허권에 구속되지 않고 무상으로 실시할 수 있다.

3. 사안의 해결

甲은 乙의 출원일인 **2013. 2. 1. 이전인 2012. 12. 3.부터** 국내에서 전기밥솥 X를 **생산** 하고 있었으므로, 출원 시에 이미 그 발명의 **실시사업을 하고 있었다**(③ 충족). 甲이 乙의 출원발명의 내용을 알지 못한 채 스스로 A+B를 발명하여 실시한 것이라면 ①·②도 충족된다.

따라서 甲은 法 103의 **선사용에 의한 통상실시권**을 가지며, 이를 항변사유로 주장할 수 있다. 이 실시권은 등록 없이도 대항할 수 있고(法 118②), 그 범위는 甲이 실시하거나 준비하고 있던 발명 및 사업 목적의 범위에 한정된다. 甲이 선사용권을 가지는 이상 그 범위에서의 실시는 침해가 되지 않으므로 **손해배상책임을 지지 않으며**, 앞서 본 보상금청구권도 「정당한 권원」이 있는 자에 대한 것이어서 성립하지 않는다.

설문 3-가 — 丙이 甲에 대하여 침해금지를 청구할 수 있는지 (10점)

1. 침해금지청구권의 주체

침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자는 **특허권자 또는 전용실시권자**이다(法 126①).

(1) 丙이 전용실시권자인 경우 — 청구할 수 있다

전용실시권자는 **설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다**(法 100②). 이처럼 전용실시권은 물권적 성질을 가지므로 法 126①은 전용실시권자를 명문으로 청구권자에 포함시키고 있다. 따라서 丙은 자기의 전용실시권이 침해된 때 甲에 대하여 침해금지를 청구할 수 있다.

다만 전용실시권의 **설정은 등록하여야만 효력이 발생하므로**(法 101①Ⅱ), 丙이 설정등록을 마치지 않았다면 애초에 전용실시권자가 아니어서 청구권자가 될 수 없다.

(2) 丙이 통상실시권자인 경우 — 청구할 수 없다

통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 **업으로서 실시할 수 있는 권리**를 가질 뿐이고(法 102②), 실시를 독점하는 권리가 아니다. 곧 통상실시권은 특허권자에 대하여 실시를 용인하여 줄 것을 구하는 채권적 권리에 그쳐 독점배타성이 없다. 法 126①도 통상실시권자를 청구권자로 들고 있지 않다. 따라서 丙은 甲에 대하여 스스로 침해금지를 청구할 수 없다.

설문 3-나 — 특허권이 丁에게 양도된 경우 실시권의 대항 (10점)

(1) 丙이 전용실시권자인 경우 — 대항할 수 있다

전용실시권의 설정은 **등록하여야만 효력이 발생한다**(法 101①Ⅱ). 곧 丙이 전용실시권자라는 것은 이미 특허원부에 설정등록이 되어 있음을 전제로 한다. 등록된 전용실시권은 특허원부에 공시되어 있고

물권적 성질을 가지므로, 그 뒤에 특허권을 양수한 丁은 전용실시권의 부담이 있는 특허권을 취득하게 된다. 따라서 丙은 丁에게 자신의 전용실시권을 **대항할 수 있다**.

반대로 丙이 설정등록을 마치지 아니하였다면 전용실시권 자체가 발생하지 않았으므로 대항의 문제가 생기지 않고, 丙은 乙에 대하여 계약에 기한 등록청구권을 행사할 수 있을 뿐이다.

(2) 丙이 통상실시권자인 경우 — 등록한 경우에만 대항할 수 있다

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 118①). 곧 통상실시권은 **등록이 제3자에 대한 대항요건**이다. 이 점에서 등록이 효력발생요건인 전용실시권과 구별된다.

따라서 丙이 통상실시권을 **등록하였다면** 그 등록 후에 특허권을 취득한 丁에게 실시권의 존재를 대항할 수 있고, **등록하지 아니하였다면** 丁에게 대항할 수 없어 丁의 청구에 응하여 실시를 중지하여야 한다(이 경우 丙은 乙에 대하여 계약상 책임을 물을 수 있을 뿐이다).

다만 法 81의3⑤, 法 103부터 105까지, 法 122, 法 182, 法 183 및 발명진흥법 제10조제1항에 따른 **법정실시권은 등록이 없더라도 法 118①의 효력이 발생한다**(法 118②). 사안의 丙은 乙로부터 허락받은 실시권자이므로 이에 해당하지 않는다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2006후138	2007-08-24	2-가 사후적 고찰 금지
81후56	1983-07-26	2-나 신규성 없는 특허의 권리범위
91마540	1992-06-02	2-나 진보성 심리 부정설
90후2225	1991-10-25	2-나 진보성 심리 긍정설
96후1699	1997-07-22	2-나 진보성 심리 긍정설
97후68	1997-08-22	2-나 진보성 심리 긍정설
97후2095	1998-10-27	2-나 종전 판례의 확립
2010다95390	2012-01-19	2-나 전원합의체 — 권리남용

교재: 리담특허법 제25판 — 보상금청구권(1198~1202), 특허요건과 침해 판단의 구별(1591), 무효의 항변과 자유기술의 항변(1505), 권리행사의 제한과 판례 변천(1494~1496), 법정실시권의 발생·효력(1797), 등록의 효력(1378~1379, 1786), 침해 구제수단(50, 1645~1646).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·65·100·101·102·103·118·126·128·130·131·133·225조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 보상금청구권 (1198~1202), 특허요건과 침해 판단의 구별(1591), 무효의 항변과 자유기술의 항변(1505), 권리행사의 제한과 판례 변천(1494~1496), 법정실시권의 발생·효력(1797), 등록의 효력 (1378~1379, 1786), 침해 구제수단(50, 1645~1646). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 07

제7회 변호사시험 · 특허법

2018년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 8개

문 제

甲은 마모방지 타이어에 관한 발명을 완성한 후 그 발명에 대하여 특허출원을 하여 특허등록을 받았고, 乙은 甲의 위 특허발명과 동일한 형상을 갖춘 타이어에 대해 甲의 특허출원일에 앞서 디자인등록출원을 하여 甲의 특허등록보다 먼저 디자인등록을 받았다. 丙은 甲의 타이어와 유사한 기술적 특징을 가진 타이어에 관한 발명에 대하여 甲의 특허출원일 후에 특허출원을 하여 甲의 특허등록 후 특허등록을 받고 위 타이어를 제조·판매하였다.

1. 甲이 乙과의 관계에서 자신의 특허발명을 적법하게 실시하기 위해 취해야 할 조치에 대해 설명하시오. (15점)
2. 甲, 乙과 무관한 타이어 제조·판매업자인 丁은 甲의 특허발명과 동일한 타이어를 제조·판매하기 시작하였고, 이에 甲은 丁에 대해 특허권침해금지를 요구하였다. 甲의 위 주장에 대해 丁은 乙이 아닌 甲이 그러한 주장을 할 수 없다고 반박하고자 하는 경우, 丁의 그러한 반박 내용의 타당성을 검토하시오. (10점)
3. 甲은 丙이 제조·판매하는 타이어가 자신의 특허발명과 유사한 기술적 특징을 가지고 있다는 이유로 丙에 대하여 일정한 법적 조치를 취하고자 한다.
 - 가. 甲이 丙을 상대로 소송상 주장할 수 있는 청구권에는 어떠한 것이 있는지 설명하시오. (20점)
 - 나. 甲이 소송절차 이외에 丙을 상대로 청구할 수 있는 특허심판원 심판절차에는 어떠한 것이 있는지 설명하시오. (15점)
4. 만일 甲과 丙이 각자 등록받은 특허권을 공유하기로 약정하고 그 내용을 특허원부에 등록할 경우, 甲이 다음의 각 사안에서 제시된 행위를 하는 것이 적법한지를 검토하시오.
 - 가. 丙의 동의 없이 甲의 공유 지분을 제3자에게 이전하는 행위 (5점)
 - 나. 丙의 동의 없이 甲의 공유 지분에 대하여 제3자에게 질권을 설정하는 행위 (5점)
 - 다. 丙의 동의 없이 甲의 공유 특허권에 관한 특허발명을 실시하는 행위 (5점)
 - 라. 丙의 동의 없이 甲의 공유 특허권에 대하여 제3자에게 통상실시권을 허락하는 행위 (5점)

해 설

배점 80점 · 설문 8개(15·10·20·15·5·5·5·5). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — **甲**: 마모방지 타이어 발명으로 특허등록. **乙**: 甲의 특허발명과 동일한 형상의 타이어에 대해 **甲의 특허출원일에 앞서 디자인등록출원**하여 먼저 디자인등록. **丙**: 甲의 타이어와 유사한 기술적 특징의 발명을 **甲의 출원일 후에 출원**하여 甲의 특허등록 후 등록받고 타이어를 제조·판매.

설문 1 — 甲이 乙과의 관계에서 적법하게 실시하기 위한 조치 (15점)

1. 특허권과 디자인권의 저촉관계

특허권과 디자인권은 **보호의 객체가 상이하므로 상호 권리 간에 저촉관계가 발생**할 수 있다. 예컨대 선출원 디자인권의 창작대상이 일정한 형상·모양을 갖는 물품인데 후출원된 발명이 동일한 구성요소를 갖는 물품이면 양자는 저촉관계에 있다.

특허법은 이를 규율하여, 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허권이 **그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는** 그 디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다고 정한다(法 98).

사안 — 乙의 디자인등록출원은 **甲의 특허출원일에 앞서** 이루어졌고, 그 디자인은 甲의 특허발명과 **동일한 형상**의 타이어에 관한 것이다. 따라서 甲의 특허권은 선출원 디자인권과 저촉관계에 있고, 甲은 乙의 허락 없이는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

2. 甲이 취할 수 있는 조치

(1) **乙의 허락(실시권 취득)** 가장 직접적인 방법은 乙로부터 실시허락을 받는 것이다. 저촉관계에 있는 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 받거나 통상실시권 허락의 심판에 의하지 아니한 채 자기의 특허발명을 업으로 실시하면 **선출원 권리의 침해**가 되어 민·형사상 제재를 받는다.

(2) **통상실시권 허락의 심판(法 138)** 乙이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 허락을 받을 수 없을 때에는, 甲은 **자기의 특허발명의 실시**에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法 138①). 인용요건은 다음과 같다.

- ① 해당 특허발명이 **法 98에 해당**하여 실시의 허락을 받으려는 경우일 것
- ② 그 타인이 **정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없을 것**. 「정당한 이유」란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말하며, 심판청구 전에 협의를 통해 실시허락을 받으려는 노력을 하여야 하고 그러하지 아니하면 심결각하된다(法 142).
- ③ **자기의 특허발명의 실시**에 필요한 범위일 것
- ④ 선출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 **상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보**를 가져올 것(法 138②)

허락받은 자는 **대가를 지급**하여야 하고, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없으면 **공탁**하여야 한다(法 138④).

★유의 — 法 138②의 「중요한 기술적 진보」는 문언상 **타인의 특허발명 또는 등록실용신안**과 비교하도록 되어 있다. 사안은 선출원 권리가 **디자인권**이므로, 이 요건을 그대로 적용할 수 있는지는 문언상 논의의 여지가 있다.

(3) **디자인권 존속기간 만료 후 — 기다리는 방법** 특허출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 특허권과 저촉되는 경우, **디자인권의 존속기간이 만료되면** 그 디자인권자 및 실시권자는 그 디자인권의 범위 또는 원권리의 범위에서 **법정의 통상실시권**을 갖는다(法 105①②). 이때 디자인권자는 무상으로 실시할 수 있으나 실시권자는 특허권자 등에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 105③). 곧 디자인권 존속기간이 만료되면 저촉관계에 따른 실시 제한은 해소되고, 다만 乙 측에 법정실시권이 남는다.

결론 — 甲은 i) 乙로부터 실시허락을 받거나, ii) 乙이 정당한 이유 없이 거절하면 法 138의 통상실시권 허락의 심판을 청구하는 방법으로 자기 특허발명을 적법하게 실시할 수 있다.

설문 2 — 丁의 반박("乙이 아닌 甲은 침해금지를 주장할 수 없다")의 타당성 (10점)

1. 특허권의 적극적 효력과 소극적 효력

특허권의 효력은 **적극적 효력**과 **소극적 효력**으로 나뉜다. **적극적 효력**이란 독점성에 기인한 효력으로서 **특허권자만이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리**(전용권·독점권)를 말한다. 특허법은 "특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다"고 규정한다(法 94①). **소극적 효력**이란 정당한 권원 없는 제3자의 실시를 **배제할 수 있는 배타적 효력**을 말한다.

2. 法 98이 제한하는 것은 적극적 효력뿐이다

法 98은 저촉관계에 있는 후출원 권리자가 **"자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다"**고 정할 뿐이다. 곧 이 규정이 제한하는 것은 특허권의 **적극적 효력(스스로 실시할 권리)**이고, 정당한 권원 없는 제3자를 배제하는 **소극적 효력까지 잃게 하는 것은 아니다**.

甲의 특허권은 적법하게 등록되어 존속하고 있으므로, 甲은 여전히 특허권자로서 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(法 126①).

3. 사안의 해결

丁은 甲·乙과 무관한 제3자로서 **甲의 특허발명과 동일한 타이어**를 제조·판매하고 있으므로, 정당한 권원 없이 업으로서 甲 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 것이어서 甲의 특허권을 침해한다.

甲이 乙의 선출원 디자인권과의 저촉으로 인하여 스스로는 실시할 수 없는 처지에 있다는 사정은 甲과 乙 사이의 관계일 뿐이고, 그로 인하여 甲이 제3자에 대한 배타권까지 잃는 것은 아니다. 따라서 丁의 반박은 타당하지 않다.

다만 丁의 실시가 乙의 디자인권도 침해하는 것이라면 乙 역시 별도로 丁에게 권리를 행사할 수 있을 뿐이며, 이는 甲의 청구를 배척할 근거가 되지 못한다.

설문 3-가 — 甲이 丙을 상대로 소송상 주장할 수 있는 청구권 (20점)

1. 침해의 성립

丙은 甲의 출원일 후에 출원하여 甲의 특허등록 후 특허등록을 받은 자로서, 甲의 타이어와 유사한 기술적 특징을 가진 타이어를 제조·판매하고 있다.

특허요건 판단과 침해 성립요건 판단은 별개이므로, 丙이 자기 발명으로 특허를 받았다는 사정만 으로 甲의 특허권을 침해하지 않게 되는 것은 아니다. 丙의 타이어가 구성요소완비의 원칙(부가의 원칙 포함) 또는 균등론에 따라 甲 특허발명의 보호범위에 속한다면 침해가 성립한다. 특히 丙이 甲의 구성요소를 모두 포함하면서 다른 구성을 부가하여 특허를 받은 것이라면 이는 **이용관계**(法 98)에 해당하여, 丙은 甲의 허락이나 통상실시권 허락의 심판 없이도 자기 특허발명을 실시할 수 없다.

2. 甲이 주장할 수 있는 청구권

(1) **침해금지 및 예방청구권(法 126①)** 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 특허권은 물권에 준하는 권리이므로 그 지배상태가 침해된 때 물권적 청구권과 같은 권리가 인정되며, **현재 또는 장래의 침해**에 대한 것이라는 점에서 과거의 침해에 대한 손해배상·부당이득반환 청구와 구별된다. 침해에 대한 가장 유효하고 직접적인 구제수단이다.

(2) **폐기·제거 등 청구(法 126②)** 위 청구를 할 때에는 **침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위**를 함께 청구할 수 있다. 甲은 丙이 제조한 타이어의 폐기와 그 생산설비의 제거를 청구할 수 있다.

(3) **손해배상청구권(法 128)** 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있고(法 128①), 침해자의 **과실은 추정**된다(法 130). 손해액에 관하여는 양도수량에 따른 산정(法 128②), 침해자 이익액의 손해액 추정(法 128④), 실시료 상당액(法 128⑤) 등이 있으며, 침해가 **고의적인 것으로 인정되는 경우에는** 손해로 인정된 금액의 **5배**를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(法 128⑧).

(4) **신용회복청구권(法 131)** 법원은 고의나 과실로 특허권을 침해하여 특허권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대하여 특허권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 신용회복에 필요한 조치를 명할 수 있다.

(5) **부당이득반환청구권** 침해자에게 고의·과실이 없는 경우에도 **부당이득은 반환하여야** 한다. 이는 과거의 침해에 대한 청구라는 점에서 손해배상과 같다.

설문 3-나 — 甲이 청구할 수 있는 특허심판원 심판절차 (15점)

1. 적극적 권리범위확인심판(法 135)

(1) **의의** 권리범위확인심판은 **확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적**을 가진 절차이다. 특허권자 또는 전용실시권자가 상대방의 실시발명이 자기 권리범위에 **속한다**는 확인을 구하는 것을 **적극적 권리범위확인심판**이라 한다.

(2) **청구 방식** 심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하고 (法 140①), **특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부**하여야 한다(法 140③). 확인대상발명은 청구취지의 일부를 구성하므로 보정은 요지변경이 되지 않는 범위에서만 가능하나(法 140②), 특허권자가 청구한 권리범위확인심판에서 피청구인이 자신의 실시발명과 다르다고 다투는 경우 청구인이 이를 실시발명과 동일하게 하기 위하여 하는 보정은 요지변경이 되더라도 허용된다(法 140②Ⅲ).

(3) **심리 범위와 항변** 권리범위확인심판은 침해의 성립요건 중 **보호범위에 속하는지 여부만**을 심리범위로 하는 데 비하여, 침해소송은 침해의 성립요건 전체와 권리행사 가능 여부까지 심리한다. 그 결과 제3자가 할 수 있는 항변에 차이가 있다.

제3자의 항변	침해소송	권리범위확인심판
특허권 당연무효의 항변	×	×
실시권의 항변	○	×
권리소진의 항변	○	×
업이 아니라는 항변	○	×
특허권 하자(무효)의 항변	○	○
자유기술의 항변	○	○
효력 제한(法 81의3④, 96, 181)의 항변	○	○
권리남용의 항변	○	×

특히 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정할 수 없다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체). 진보성 판단은 특허무효심판의 기능에 속하고, 대세적 효력을 갖는 권리범위확인심판에서 이를 판단하면 특허법의 기본 구조와 상충되기 때문이다. 다만 특허의 전부 또는 일부가 출원 당시 **공지공용**이었다면 권리범위확인심판에서도 무효심결 유무와 관계없이 권리범위를 부정할 수 있다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체).

(4) 한계 권리범위확인심판의 심결은 침해소송에서 **유력한 증거로 활용될 수 있으나 법원을 기속하지 못한다.**

2. 특허무효심판(法 133)

甲의 입장에서 丙의 후출원 특허를 제거하고자 한다면 **丙의 특허에 대한 특허무효심판**을 청구할 수 있다. 丙의 발명이 甲의 선출원 발명과 동일하다면 선출원주의 위반(法 36) 또는 확대된 선출원(法 29③) 위반이, 甲의 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라면 진보성 위반(法 29②)이 각각 무효사유가 된다.

3. 정리

甲이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판은 i) **丙의 실시발명이 자기 특허권의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판**과, ii) **丙의 특허를 무효로 하는 특허무효심판**이다. 반면 통상실시권 허락의 심판(法 138)은 이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자인 丙이 청구하는 것이므로 甲의 조치가 아니다.

설문 4 — 甲·丙이 특허권을 공유하기로 약정하고 등록한 경우 (20점)

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 있고 전용실시권 설정·통상실시권 허락을 할 수 있어 그 범위에서 **합유와 유사한 성질**을 가지지만, 이는 특허권이 무체재산권이라는 특수성에서 유래한 것일 뿐이고 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위에서는 **민법상 공유 규정이 적용**된다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567).

가. 丙의 동의 없이 공유 지분을 제3자에게 이전하는 행위 — 위법하다 (5점)

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 **다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도**할 수 있다(法 99②). 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력 여하가 다른 공유자의 이해관계에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 따라서 丙의 동의 없는 지분 이전은 적법하지 않다.

다만 **상속이나 그 밖의 일반승계**에 의한 지분 이전은 다른 공유자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 없으므로 동의를 요하지 않으며, **공유자 사이의 지분 양도**도 단지 공유자 간의 지분변동에 불과 하여 다른 공유자의 이익을 해하지 않으므로 동의를 요하지 않는다.

나. 丙의 동의 없이 공유 지분에 질권을 설정하는 행위 — 위법하다 (5점)

각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 **그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정**할 수 있다(法 99②). 질권이 실행되면 결국 지분이 제3자에게 이전되는 결과가 되어 지분 양도와 같은 문제가 생기기 때문이다. 따라서 丙의 동의 없는 질권 설정은 적법하지 않다.

다. 丙의 동의 없이 공유 특허발명을 실시하는 행위 — 적법하다 (5점)

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 **계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다**(法 99③). 특허권의 객체인 발명은 무형의 기술적 사상의 창작으로서 **점유를 수반하지 않아 수인이 동시에 실시할 수 있기** 때문이며, 이 점이 지분 비율로 사용하는 민법상 공유와 다르다.

사안에서 甲과 丙은 특허권을 공유하기로 약정하였을 뿐 실시에 관하여 특별한 약정을 하였다는 사정이 없으므로, 甲은 丙의 동의 없이 스스로 특허발명을 실시할 수 있다.

라. 丙의 동의 없이 제3자에게 통상실시권을 허락하는 행위 — 위법하다 (5점)

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 **다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다**(法 99④). 제3자가 실시하게 되면 다른 공유자의 이익에 직접 영향을 미치기 때문이다. 따라서 丙의 동의 없는 통상실시권 허락은 적법하지 않다.

정리 — 스스로 실시하는 것은 자유(다), 지분을 처분하거나(가·나) 남에게 실시하게 하는 것(라)은 전원의 동의가 필요하다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2012후4162	2014-03-20	3-나 권리범위확인심판에서 진보성 판단 불가(전합)
81후56	1983-07-26	3-나 공지공용인 경우 권리범위 부정(전합)
2002후567	2004-12-09	설문4 특허권 공유의 법적 성질

교재: 리담특허법 제25판 — 특허권의 적극적·소극적 효력(1439~1442), 이용·저촉발명 (1592, 1607~1613), 통상실시권 허락의 심판(1897~1898), 특허권의 공유(1749~1750, 1758~1759), 침해 구제수단(50, 1645~1646), 권리범위확인심판의 절차·심리·항변(2163~2164).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·36·94·98·99·105·126·128·130·131·133·135·138·140·142조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 특허권의 적극적·소극적 효력(1439~1442), 이용·저촉발명(1592, 1607~1613), 통상실시권 허락의 심판(1897~1898), 특허권의 공유(1749~1750, 1758~1759), 침해 구제수단(50, 1645~1646), 권리범위확인심판 (2163~2164). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 08

제8회 변호사시험 · 특허법

2019년 시행 · 제1문의 1 · 제1문의 2 · 배점 80점 · 설문 6개

문 제

제1문의 1 50점

甲은 발명 A를 완성한 후 시제품을 제작한 다음, 일부 집단의 시험을 거쳐 문제점을 개선하여 특허를 출원하려고 한다.

1. 발명의 신규성 상실의 사유에 대하여 설명하시오. (10점)
2. 다음 각 사안에서 甲이 발명 A를 특허출원하는 경우, 특허등록을 받을 수 있는 방법을 검토하시오.
 - 가. 甲은 위 시험을 진행하면서 시험참가자들에게 시제품을 배포하였다. 시험참가자들은 비밀서약을 쓰지 않았지만, 시험참가가 특정인으로 제한되어 있다는 점과 시험이 비공개라는 점을 알고 있었다. 그러나 시험에 참가한 乙이 이후에 무단으로 시제품을 공개하여 사람들이 그 기술을 알게 되었다. (15점)
 - 나. 甲은 홍보를 위해 언론사들을 초청하여 위 시험을 진행하면서 시제품을 기자들에게 나누어 주었다. 이후 참가한 기자들에 의해 발명 A의 시제품이 뉴스에 소개되었다. (15점)
3. 시험에 참가한 丙이 시제품을 받아 발명 A를 무단으로 직접 특허출원한 경우, 丙이 특허등록을 받을 수 있는지와 만일 특허등록을 받았다면 그 특허가 유효한지를 검토하시오. (10점)

제1문의 2 30점

대법원은 프린터와 그 소모부품인 프린터 카트리지에 관한 사건(이하 ‘카트리지 사건’이라 함)에서 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다.”라고 판시하고 있다.

1. 특허권에 대한 간접침해의 성립요건을 설명하고, ‘카트리지 사건’에서 프린터 카트리지에 특허발명이 아닌 다른 모델의 프린터에도 장착하여 사용할 수 있는 것이라면, 특허권자 아닌 자가 위 프린터 카트리지를 제조·판매하는 행위가 특허권에 대한 간접침해에 해당하는지를 검토하시오. (20점)

2. 甲은 A, B, C를 구성요소로 하는 선풍기(A+B+C)를 발명하여 특허권을 취득했다. 乙은 어린이의 손가락 끼임 방지를 위하여 D, E를 구성요소로 하는 선풍기용 동작감지 센서(D+E)를 개발하고, 甲의 특허출원일 후에 출원하여 특허권을 취득했다. 乙이 특허받은 선풍기용 동작감지 센서(D+E)는 甲의 발명에만 사용된다고 한다. ‘카트리지 사건’에서 특허발명인 프린터의 본질적 구성요소는 X, Y, Z이며, 프린터 카트리지는 구성요소 X에 해당하는 것으로 본다면, 위 판결에 비추어 乙이 선풍기용 동작감지 센서(D+E)를 제조·판매하는 행위가 甲의 특허권에 대한 간접침해에 해당하는지를 검토하시오. (10점)

해설

배점 80점 · 제1문의 1(50점) + 제1문의 2(30점). 문제 원문은 자료집 참조.

제1문의 1 — 甲은 발명 A를 완성해 시제품을 만들고 **일부 집단의 시험**을 거쳐 문제점을 개선한 뒤 출원하려 한다. 가) 참가자는 비밀서약서를 쓰지 않았으나 **참가가 특정인으로 제한되고 비공개임을 알고 있었는** 데 乙이 무단 공개했다. 나) **언론사를 초청**해 시험하고 기자들에게 시제품을 나눠 주어 뉴스에 소개되었다. 3) 丙이 시제품을 받아 **무단 출원**했다.

제1문의 2 — 카트리지 사건(간접침해) 법리의 적용.

제1문의 1 (50점)

설문 1 — 신규성 상실의 사유 (10점)

1. 신규성의 의의

「신규성」이란 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 발명으로서 **객관적 창작성**이 있는 것을 말한다. 특허법은 i) 신규한 발명을 공개한 자에게만 공개의 대가로 특허권을 부여하고, ii) 공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위하여 신규성을 특허요건으로 정하고 있다. 특허법은 신규성 상실사유를 **제한열거적으로 규정**하여, 이에 해당하지 아니하면 신규성이 인정되도록 하고 있다.

2. 상실사유(法 29④각호)

(1) 공지(法 29④ I 전단) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **공지**된 발명. 발명의 내용이 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 말한다.

(2) 공연실시(法 29④ I 후단) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **공연히 실시**된 발명. 「공연실시」란 실시에 의하여 발명이 불특정인에게 공연히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 말하고, 「공연」이란 **발명의 주요부에 대하여 비밀상태가 해제된 것**을 의미한다. 단 **1회의 실시라도 공연 실시**에 해당하나, **발명의 주요부 중 일부분에 비밀유지상태가 확보되면서 실시할 때에는 공연실시에 해당하지 않을 수 있다**. 또한 공연히 실시된 발명이란 통상의 기술자가 그 발명의 내용을 쉽게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 곧 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다(대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688).

(3) **반포된 간행물에 게재(法 29①Ⅱ 전단)** 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재**된 발명. 「반포」란 **불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것**을 의미하므로, 도서관 사서과에 도착하였으나 열람실에 비치되지 아니한 경우 등은 반포되었다고 할 수 없다.

(4) **전기통신회선을 통한 공개(法 29①Ⅱ 후단)** 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **전기통신 회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된** 발명. 다만 공개된 발명에의 접근이 일반인에게 허용 되지 않고 특정인에게만 허용된다면 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 볼 수 없다.

(5) **효과** 신규성 위반은 등록 전에는 거절이유(法 62)·정보제공사유(法 63의2)이고, 등록 후에는 특허 취소사유(法 132의2①)·특허무효사유(法 133①)이다.

설문 2-가 — 비공개 시험 참가자의 무단 공개 (15점)

1. 시제품 배포가 공연실시인지

「공연」이란 발명의 주요부에 대하여 **비밀상태가 해제된 것**을 의미하고, 발명의 주요부에 비밀유지상태가 확보되면서 실시된 때에는 공연실시에 해당하지 않을 수 있다.

사안 — 시험참가자들이 비밀서약서를 쓰지는 않았으나, **참가가 특정인으로 제한되어 있다는 점과 시험이 비공개라는 점을 알고 있었다**. 그렇다면 참가자들은 불특정인이 아니라 특정인이고 그들에 대하여 발명의 주요부에 관한 비밀상태가 전면적으로 해제되었다고 보기 어렵다. 따라서 甲의 시제품 배포 자체는 **공연실시에 해당하지 않는다**.

2. 乙의 무단 공개 — 의사에 반한 공지

그러나 시험에 참가한 **乙이 이후에 무단으로 시제품을 공개하여 사람들이 그 기술을 알게 되었으므로**, 이로써 발명 A는 불특정인에게 알려져 **法 29① I의 공지**에 해당하게 되었다.

이때 적용되는 것이 **法 30①Ⅱ의 「의사에 반한 공지」**이다. 이는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 法 29①각호의 공지 등이 된 경우를 말한다. 곧 공지시점을 기준으로 특허를 받을 수 있는 자가 **공개시키지 않겠다는 의사(반공개 의사)**를 가지고 있었음에도 이에 반하여 공지된 경우이다.

3. 甲이 특허등록을 받는 방법

甲은 **공지일부터 12개월 이내에 특허출원**을 하면, 法 29①·②를 적용할 때 그 공지는 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다(法 30①). 자기 의사에 반하여 공지된 경우에도 시기적 요건은 같다.

절차 — 자기 의사에 **반하여** 공지된 경우에는 자기 의사에 의한 공지(法 30① I)와 달리 출원서에 취지를 적고 증명서류를 30일 이내에 제출하여야 하는 法 30②의 절차가 요구되지 않는다. 다만 실무상 甲은 그 공개가 자신의 의사에 반한 것임을 심사·심판 단계에서 주장·증명할 수 있어야 하므로, 乙의 무단 공개 경위를 밝힐 자료(시험 참가 조건, 비공개 고지 사실 등)를 갖추어 두어야 한다.

결론 — 甲은 乙의 무단 공개일부터 **12개월 이내에 출원**하고 그 공개가 자신의 의사에 반한 것임을 밝히면, 그 공지에 의하여 신규성이 부정되지 않아 **특허등록을 받을 수 있다**.

설문 2-나 — 언론에 공개한 경우 (15점)

1. 공연실시·공지에 해당한다

甲은 **홍보**를 위해 **언론사들을 초청**하여 시험을 진행하면서 기자들에게 시제품을 나누어 주었고, 이후 기자들에 의해 시제품이 **뉴스에 소개**되었다.

기자들은 취재·보도를 위하여 초청된 자들로서 비밀유지가 전제되어 있지 않고, 오히려 甲은 **홍보 목적**으로 공개한 것이므로 발명의 주요부에 대한 비밀상태가 해제되었다고 보아야 한다. 따라서 시제품 배포 자체가 **法 29① I의 공연실시**에 해당하고, 뉴스 보도로 발명이 알려진 것은 그 보도의 형태에 따라 **法 29①Ⅱ의 반포된 간행물 게재 또는 전기통신회선을 통한 공개**에도 해당한다. 결국 발명 A는 신규성을 상실한다.

2. 甲이 특허등록을 받는 방법 — 자기 의사에 의한 공지

이 경우는 설문 2-가와 달리 **甲 자신의 의사에 의한 공지**이므로 **法 30① I** 본문이 적용된다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 발명이 공지된 경우로서, 권리자가 직접 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니므로 기자들의 보도를 통하여 공지된 것도 이에 포함된다. 다만 조약이나 법률에 따라 국내외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외된다(法 30① I 단서).

절차 — 이 경우에는 절차를 반드시 밟아야 한다. 자기 의사에 의하여 공지된 경우 공지에외를 적용받으려는 자는 i) 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, ii) 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 **30일 이내**에 제출하여야 한다(法 30②). 다만 보완수수료를 납부하면 法 30③이 정한 기간(法 47①의 보정할 수 있는 기간 등)에도 그 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출할 수 있다.

시기 — **최선의 공지일**부터 **12개월 이내**에 출원하여야 한다. 언론 공개와 뉴스 보도가 여러 차례 있었다면 그중 **가장 먼저** 공지된 날이 기산점이 된다.

결론 — 甲은 최선의 공지일로부터 12개월 이내에 출원하면서 **출원서에 공지에외적용을 받으려는 취지를 적고 증명서류를 30일 이내에 제출**하면(또는 보완수수료를 납부하고 法 30③의 기간에 제출하면) 특허등록을 받을 수 있다. 이 절차를 밟지 않으면 자신의 홍보 공개로 인하여 신규성이 부정된다.

두 설문의 차이 — 가)는 **의사에 반한 공지**(法 30①Ⅱ)로서 法 30②의 취지 기재·증명서류 제출 절차가 요구되지 않는 반면, 나)는 **자기 의사에 의한 공지**(法 30① I)로서 그 절차가 필수이다. 12개월의 시기적 요건은 양쪽 모두 같다.

설문 3 — 丙의 무단 출원 (10점)

1. 丙은 무권리자이다

특허를 받을 수 있는 권리는 **발명자 또는 그 승계인**이 가진다(法 33① 본문). 발명자가 아니고 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인도 아닌 자를 **무권리자**라 하며, 진정한 발명자의 의사에 반하여 발명을 모인 자는 **악의의 무권리자(冒認者)**에 해당한다.

사안 — 丙은 시험에 참가하여 시제품을 받았을 뿐 발명 A를 한 자가 아니고 甲으로부터 권리를 승계받지도 않았다. 따라서 丙은 무권리자이다.

2. 丙이 특허등록을 받을 수 있는지 — 받을 수 없다

무권리자의 출원은 法 33①본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 출원이므로 **거절이유(法 62)**에 해당하고, 정보제공사유(法 63의2)도 된다. 따라서 심사 과정에서 이 사유가 드러나면 丙은 특허등록을 받을 수 없다.

3. 등록되었다면 그 특허가 유효한지 — 무효사유가 있다

착오로 등록되었더라도 法 33①본문 위반은 **특허무효사유(法 133①Ⅱ)**에 해당한다. 다만 등록주의 아래서 무효심결이 확정되기 전까지는 특허권이 유효한 것으로 다루어지므로, **무효심판에 의하여 무효로 확정되어야 비로소 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.**

4. 정당한 권리자 甲의 구제

甲의 구제수단은 둘이다.

- **별도 출원(法 34, 35)** — 무권리자의 출원·특허가 배척된 경우 정당한 권리자가 출원하면 무권리자의 출원 시에 출원한 것으로 출원일이 소급된다.
- **특허권의 이전청구(法 99의2)** — 특허가 法 33①본문 위반으로 무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 **법원에 그 특허권의 이전을 청구**할 수 있다(法 99의2①). 이전등록을 받으면 그 특허권은 **설정등록된 날부터** 이전받은 자에게 있었던 것으로 본다(法 99의2②).

권리범위를 다시 설계할 필요가 있으면 별도 출원을, 절차의 신속성과 편의성을 고려하면 이전청구를 선택하면 된다.

또한 무권리자 丙의 공개는 甲의 입장에서 자기 의사에 반한 공지에 해당하므로, 甲은 그 공개일 부터 12개월 이내에 출원하면 法 30①Ⅱ에 따라 공지예외를 적용받을 수 있다.

제1문의 2 (30점)

설문 1 — 간접침해의 성립요건과 타용도가 있는 카트리지 (20점)

1. 간접침해의 의의와 요건

「간접침해」란 직접침해의 전단계로서 그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대하여 특허권을 침해하는 것으로 의제하는 것을 말한다. 확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니더라도 법률의 확장에 해당하는 간접침해인 경우에는 특허발명의 보호범위에 속하게 된다.

특허법은 다음 행위를 **업으로서** 하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다(法 127).

- **특허가 물건의 발명인 경우:** 그 물건의 **생산에만 사용하는 물건**을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(法 127 I)
- **특허가 방법의 발명인 경우:** 그 방법의 **실시에만 사용하는 물건**을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(法 127 II)

정리하면 간접침해가 성립하려면 i) **특허권의 존속기간 중일 것**, ii) **정당한 권원 없는 자가**, iii) **업으로서**, iv) 그 물건의 **생산에만(또는 방법의 실시에만) 사용하는 물건**에 대하여 위 행위를 할 것이 필요하다. 침해자의 **고의·과실은 불문**한다는 것이 통설이다.

2. 「생산에만 사용하는 물건」 — 타용도가 없을 것

「**에만**」이라는 문언은 그 물건에 **다른 용도(타용도)가 없을 것**을 요구한다. 특허권이 부당하게 확장되지 않도록 하기 위한 제한이다.

카트리지 사건(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580)은 레이저 프린터의 소모부품인 감광드럼 카트리지에 관하여, i) **특허발명의 본질적 구성요소**이고, ii) **타용도로는 사용되지 아니하며**, iii) **일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품**일 뿐만 아니라, iv) 프린터 **구입 시에 그 교체가 예정되어** 있었고, v) **특허권자가 그러한 카트리지를 따로 제조·판매**하고 있다는 점을 들어 「**생산에만 사용하는 물건**」에 해당한다고 하였다. 곧 소모부품이라도 위 요소를 갖추면 간접침해의 대상이 된다는 것이다.

한편 **타용도의 존부를 판단하는 기준시점**은, 침해금지청구권을 소송상 행사할 때에는 간접침해 시가 아니라 **사실심 변론종결 시**이다. 변론종결 시에 타용도가 있음에도 침해금지청구를 인정하면 특허발명과 무관한 타용도로 이용할 수 있는 물건에까지 특허권의 효력이 미치게 되기 때문이다.

3. 사안의 해결

문제는 그 프린터 카트리지가 **특허발명이 아닌 다른 모델의 프린터에도 장착하여 사용할 수 있는 것**이라고 가정한다. 그렇다면 그 카트리지에는 특허발명인 프린터의 생산 외에 **다른 용도가 존재**한다.

카트리지 사건이 간접침해를 인정한 근거 중 핵심은 「**타용도로는 사용되지 아니하며**」라는 점이었는데, 이 사안에서는 바로 그 요소가 부정된다. 따라서 그 카트리는 法 127 I의 「그 물건의 **생산에만 사용하는 물건**」에 해당하지 아니한다.

결론 — 특허권자 아닌 자가 그 프린터 카트리지를 제조·판매하는 행위는 **간접침해에 해당하지 않는다**. 다만 침해금지청구와의 관계에서 타용도의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 하므로, 그 시점에 타용도가 실제로 존재하는지가 확인되어야 한다.

설문 2 — 乙의 동작감지 센서(D+E) 제조·판매 (10점)

1. 문제의 소재

甲의 특허발명은 선풍기 **A+B+C**이고, 乙은 **D+E**를 구성요소로 하는 선풍기용 동작감지 센서를 개발하여 甲의 출원일 후에 출원해 특허권을 취득하였다. **D+E는 甲의 발명에만 사용된다**.

카트리지 사건에서 프린터의 본질적 구성요소는 X, Y, Z이고 카트리지는 그중 **구성요소 X에 해당**한다. 반면 D+E는 甲의 특허발명 A+B+C의 **구성요소가 아니라 이에 추가되는 별개의 물건**이다. 이 차이를 어떻게 볼 것인가가 문제 된다.

2. 검토

(1) 타용도가 없다. D+E는 甲의 발명에만 사용되므로 「에만」 요건, 곧 타용도가 없을 것이라는 요건은 충족된다.

(2) 乙이 특허를 받았다는 점은 결론을 바꾸지 않는다. 판례는 타용도가 없는 물건인 이상 기술구성 일부가 종래기술을 개량한 것으로서 그 자체에 특허성이 있더라도 **간접침해**라고 한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580). 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단은 별개이기 때문이다. 이 경우에는 **선·후 특허권자 사이에 실시권 허락의 문제**가 나타난다. 또한 타용도가 없는 물건에 다른 구성요소를 추가하여 그 구성요소로 타용도를 창출한 경우라도 간접침해임에는 변함이 없다. 그렇게 보지 않으면 다른 구성요소를 임의로 추가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있게 되어 부당하기 때문이다.

(3) D+E가 A+B+C의 「생산에」 사용되는가. D+E를 장착한 선풍기는 **A+B+C+D+E**로서 甲의 특허발명 A+B+C의 구성요소를 모두 포함하므로, 구성요소완비의 원칙 중 **부가의 원칙**에 따라 甲 특허발명의 보호범위에 속한다. 따라서 D+E는 甲의 특허발명을 포함하는 물건의 생산에 사용되는 것이어서 「그 물건의 생산에만 사용하는 물건」으로 볼 여지가 있다.

(4) 다만 신중히 볼 지점 — 카트리지 사건은 「**특허발명의 본질적 구성요소에 해당하고**」를 간접침해 인정의 요소 중 하나로 들었다. D+E는 甲 특허발명의 구성요소가 아니라 부가물이라는 점에서 카트리지와 지위가 다르므로, 그 법리를 그대로 옮겨 적용할 수 있는지는 이 요소를 어떻게 평가하는지에 달려 있다.

3. 결론

D+E는 甲의 발명에만 사용되어 타용도가 없고, 乙이 그에 관하여 특허권을 취득하였다는 사정은 간접침해의 성립을 방해하지 않는다. 따라서 乙이 D+E를 업으로 제조·판매하는 행위는 甲의 특허권에 대한 **간접침해에 해당한다고 볼 수 있다**(法 127 I).

乙로서는 자신의 특허발명을 적법하게 실시하기 위하여 甲으로부터 실시허락을 받거나, 甲이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하는 때에는 **통상실시권 허락의 심판**(法 138)을 청구하는 방법을 고려할 수 있다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
94후1688	1996-01-23	1-1 공연실시의 의미
98후2580	2001-01-30	2-1·2-2 카트리지 사건 — 「생산에만 사용하는 물건」

교재: 리담특허법 제25판 — 신규성 상실사유(346~348), 공연실시(353~356), 반포(357~358), 공지예외(788~799), 무권리자(536~537), 정당한 권리자의 보호(815), 특허권의 이전청구(831~832), 간접침해(1642~1643, 1699~1702).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·30·33·34·35·62·63의2·99의2·127·132의2·133·138조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 신규성 상실사유와 공연실시·반포(346~348, 353~358), 공지예외(788~799), 무권리자와 정당한 권리자의 보호 (536~537, 815, 831~832), 간접침해(1642~1643, 1699~1702). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 09

제9회 변호사시험 · 특허법

2020년 시행 · 제1문의 1 · 제1문의 2 · 배점 80점 · 설문 6개

문 제

제1문의 1 40점

甲은 영상 암호화 기술 A의 특허권자이다. 甲의 기술 A는 시장에서 호평을 받아 상업적 성공을 거두었다. 한편, 乙은 암호화 기술 B의 특허권자로 甲의 기술 A가 자신의 기술 B와 유사하다고 판단하였다. 乙의 특허 기술 B는 甲의 특허 기술 A의 출원일보다 앞서 출원·공개되어 등록되었다. 통상의 기술자는 기술 B를 인용하여 기술 A를 쉽게 발명할 수 있다.

1. 기술 A의 ‘진보성’과 관련하여 다음을 답하시오. (20점)

가. 진보성의 의미를 설명하시오. (5점)

나. 기술 A의 특허에 대해서 발명이 속하는 기술 분야, 과제해결원리, 사후적 고찰, 상업적 성공을 종합적으로 고려하여 진보성을 판단하시오. (15점)

2. 甲은 乙을 상대로 특허권에 기초하여 특허침해금지, 특허침해제품의 폐기 및 손해배상을 청구하였다. 甲의 기술 A의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우, 위 청구에 대하여 乙이 특허무효의 항변과 권리남용의 항변을 할 수 있는지 각각 판단하시오. (20점)

제1문의 2 40점

甲은 여름용 의류를 위한 신소재를 개발하고 있다. 甲은 인력과 개발설비가 부족하여 친구인 乙과 丙에게 도움을 요청하였다. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호협력하는 관계가 있어야 한다. 乙은 자신의 연구시설과 각종 설비를 제공하여 甲의 발명 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도이다. 丙은 甲과 함께 실질적으로 협력 연구하여 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하여 구체화하였고, 결국 A 원단을 성공적으로 개발하였다.

1. 甲·乙·丙 중 A 원단에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자는 누구인지 답하시오(「특허법」 제33조를 중심으로). (20점)

2. 甲이 2018. 5. 20.에 A 원단 제조에 관한 논문을 발표하고 2019. 3. 20.에 A 원단에 관한 특허출원을 한 경우, ‘신규성’을 고려하여 A 원단에 대한 특허를 받을 수 있는지 답하시오(「특허법」 제29조와 제30조를 중심으로). (20점)

해설

배점 80점 · 제1문의 1(40점) + 제1문의 2(40점). 문제 원문은 자료집 참조.

제1문의 1 — 甲은 영상 암호화 기술 A의 특허권자로 **상업적 성공**을 거두었다. 乙의 기술 B는 **A의 출원일보다 앞서 출원·공개되어** 등록되었고, **통상의 기술자는 B를 인용하여 A를 쉽게 발명할 수 있다**.

제1문의 2 — 甲의 신소재 개발에서 乙은 연구시설·설비를 제공해 후원·위탁하였을 뿐이고, 丙은 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하여 구체화해 A 원단을 개발했다.

제1문의 1 (40점)

설문 1-가 — 진보성의 의의 (5점)

「발명의 진보성」이란 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 **法 29①각호의 어느 하나에 해당하는 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것**을 말하며, 이를 **주관적 창작성**이라 한다. 신규성이 발명의 내용이 아직 알려지지 않았다는 **객관적 창작성**을 뜻하는 것과 구별된다.

특허법은 **法 29②**에서 "특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 ... 특허를 받을 수 없다"고 규정한다.

취지 — 진보성이 없는 발명에 특허를 부여하면 i) 특허권의 난립으로 특허분쟁을 유발할 우려가 있고, ii) 창의적인 발명보다 남의 발명을 모방하는 경향이 짙어져 발명의 질을 저하시켜 오히려 산업발전을 저해한다. 그래서 공지기술보다 비약적이고 누진적인 발명에만 특허를 부여하기 위하여 진보성을 특허요건으로 정하고 있다.

설문 1-나 — 네 요소를 종합한 기술 A의 진보성 판단 (15점)

1. 발명이 속하는 기술분야

진보성은 **그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)의 입장에서** 판단한다. 진보성 판단의 인용대상은 공지발명보다 넓은 **공지기술**로 해석되며, 신규성 판단과 달리 **둘 이상의 인용대상을 상호 조합**하여 판단할 수 있다. 다만 인용대상의 수가 많을수록 사후적 고찰에 해당할 가능성이 커지므로 유의하여야 한다.

사안 — 甲의 기술 A는 **영상 암호화 기술**이고 乙의 기술 B는 **암호화 기술**로서 서로 같은 기술분야에 속한다. 따라서 B는 A의 진보성 판단에서 인용대상이 되기에 적합하고, 다른 기술분야의 기술을 끌어와야 하는 부담도 없다.

2. 과제해결원리 — 목적·구성·효과의 종합 검토

심사 실무는 출원 당시 통상의 기술자가 직면한 기술수준 전체를 고려하면서 발명의 **목적(해결 하고자 하는 과제)·기술적 구성(해결수단)·작용효과**를 **종합적으로 검토**하되, 구성의 곤란성을 중심으로 목적의

특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 판단하도록 하고 있다.

판례도 "선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준을 파악한 다음, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 **그 차이를 극복하고 선행 기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를** 살펴보아야 한다"고 하고 (대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660), 창작의 난이도는 **구성의 차이와 작용효과**를 고려하여 판단하여야 한다고 한다(대법원 1997. 12. 9. 선고 97후44; 대법원 1999. 4. 9. 선고 97후2033).

사안 — 사실관계는 **통상의 기술자가 기술 B를 인용하여 기술 A를 쉽게 발명할 수 있다**고 명시하고 있다. 곧 A와 B 사이에 구성의 차이가 있더라도 그 차이를 극복하는 데 곤란성이 없고, 그로 인한 작용효과가 B에 비하여 현저하게 향상되었다고 볼 사정도 나타나 있지 않다. 따라서 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 모두 인정되지 않는다.

3. 사후적 고찰의 금지

진보성 판단은 객관적 타당성에 따라야 하고 판단기준의 고정화를 지양하여야 하며, **사후적 고찰을 하여서는 안 된다**. 통상의 기술자가 해당 발명의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 극히 많으므로, 심사관·심판관은 **출원 전의 상태로 돌아가 그 발명의 지식을 알지 못한다는 전제**에서 진보성을 따져야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

사안 — 사후적 고찰의 금지는 통상 진보성을 **부정하는 쪽으로 기울지 말라**는 요청이다. 그런데 사안에서 "통상의 기술자가 B를 인용하여 A를 쉽게 발명할 수 있다"는 것은 A의 내용을 알고 난 뒤의 사후적 판단이 아니라 **문제가 전제로 제시한 사실**이다. 따라서 이 사건에서는 사후적 고찰의 금지가 진보성을 긍정하는 근거가 되지 못한다.

4. 상업적 성공

구성의 곤란성과 효과의 현저성으로 판단하는 것이 원칙이고, 진보성이 있는지 모호한 경우에 한하여 참고자료가 될 수 있는 사정이 있다. 상업적 성공도 그중 하나이다.

다만 상업적 성공을 참작하려면 **그 성공이 청구항에 기재된 발명의 기술적인 특징에 의한 성공**으로서 **판매기술·선전·광고기술 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장·증명**하여야 한다(대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302; 대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817).

나아가 **이러한 참고적 판단방법 자체만으로 진보성을 판단해서는 안 된다**. 상업적 성공은 발명품의 우수성과 무관하게 시장의 판매여건, 적극적인 광고 전략, 판매자의 독점적 지위, 제조설비나 작업자의 우수성 등으로도 달성될 수 있기 때문이다. 판례도 발명품이 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터 호평을 받은 것은 **일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수는 있어도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없고**, 진보성은 우선적으로 명세서에 기재된 발명의 목적·구성·효과를 토대로 판단하여야 한다고 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546; 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052).

사안 — 기술 A가 시장에서 호평을 받아 상업적 성공을 거둔 것은 사실이나, 그 성공이 A의 기술적 특징에서 비롯되었고 판매·광고 등 다른 요인에 의한 것이 아니라는 점을 **甲이 주장·증명** 하지 못하는 한

참작할 수 없다. 설령 참작하더라도 이는 진보성이 모호한 경우의 참고자료일 뿐, **구성의 곤란성이 부정되는 이상 상업적 성공만으로 진보성을 인정할 수는 없다.**

5. 결론

기술 B는 기술 A의 **출원일보다 앞서 출원·공개되어 등록**되었으므로 A의 출원 전 공지기술로서 인용대상이 된다. A와 B는 같은 기술분야에 속하고, 통상의 기술자가 B로부터 A를 쉽게 발명할 수 있어 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되지 않으며, 상업적 성공은 그것만으로 진보성을 인정할 근거가 되지 못한다. 따라서 **기술 A의 진보성은 부정된다**(法 29② 위반).

설문 2 — 무효의 항변과 권리남용의 항변 (20점)

1. 두 항변의 구별

침해소송에서 실시자가 할 수 있는 항변으로 강학상 **특허권 하자의 항변(무효의 항변)**과 **자유기술의 항변**이 있고, 이와 별도로 **권리남용의 항변**이 문제 된다.

무효의 항변은 「**공지기술 vs 특허발명**」을 대비하여 특허발명이 공지기술과 같으므로 특허권의 권리범위를 인정할 수 없다고 주장하는 것이다. 이때 **동일성(신규성)의 경우에는 인정되지만, 용이성(진보성)의 경우에는 인정되지 아니한다**(다만 일정한 경우 권리행사가 제한된다).

2. 무효의 항변 — 이 사건에서는 인정되지 않는다

특허발명이 공지기술과 **동일하여 신규성이 없음**에도 착오로 등록되었으면, 무효심결이 확정되어 특허권이 소멸하기 전이라도 그 보호범위를 인정할 수 없다는 것이 종래부터의 관례이다 (대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 등).

그러나 **진보성이 없다는 이유로는 권리범위를 부정할 수 없다**는 것이 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후 2095 판결 이래의 확립된 입장이고, 이 점은 뒤에 볼 전원합의체 판결로도 바뀌지 않았다.

사안 — 乙이 주장하는 것은 A의 **진보성이 부정된다**는 것이지 A가 B와 동일하여 신규성이 없다는 것이 아니다(사실관계도 "쉽게 발명할 수 있다"고 하여 용이성을 문제 삼는다). 따라서 乙은 **무효의 항변으로 甲 특허의 권리범위를 부정할 수는 없다.**

3. 권리남용의 항변 — 이 사건에서는 인정된다

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은, 진보성이 없어 본래 공중에 개방 되어야 할 기술에 잘못 등록이 이루어졌음에도 제한 없이 독점시키면 공공의 이익을 부당하게 훼손하고 특허법의 입법목적에 배치되며, 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 등록되어 있음을 기화로 실시자를 상대로 청구할 수 있게 하는 것은 실질적 정의와 형평에 어긋난다는 점을 들어, **특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시**하였다. 나아가 법원은 **그 권리남용 항변의 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다**고 하였다.

여기서 「특별한 사정」이란 무효사유가 존재하더라도 정정심판이나 정정청구에 의하여 그 무효사유를 극복할 수 있는 사정을 말한다.

	종전 판례(97후2095 등)	2010다95390 전합
진보성 결여로 권리범위를 부정하는지	×	×
침해소송에서 진보성을 심리할 수 있는지	×	○
권리행사가 가능한지	○	무효 명백 + 특별한 사정 없으면 권리남용으로 불가

사안 — 설문은 "甲의 기술 A의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우"를 전제하고 있다. 이는 전합 판결이 든 요건에 그대로 들어맞는다. 따라서 정정으로 무효사유를 극복할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 **乙의 권리남용 항변은 인정된다**.

4. 청구별 결론

甲의 청구는 i) 특허침해금지(法 126①), ii) 특허침해제품의 폐기(法 126②), iii) 손해배상(法 128①)이다. 전합 판결은 "**침해금지 또는 손해배상 등의 청구**"가 권리남용에 해당한다고 하였고, 폐기 청구는 침해금지청구에 부수하여 함께 하는 것이므로(法 126②), **세 청구 모두** 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다.

정리하면, 乙은 **무효의 항변으로는 다룰 수 없으나 권리남용의 항변으로는 甲의 청구 전부를 배척시킬 수 있고**, 법원은 그 판단의 전제로서 기술 A의 진보성을 직접 심리·판단할 수 있다.

제1문의 2 (40점)

설문 1 — 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자 (20점)

1. 권리의 귀속(法 33)

특허를 받을 수 있는 권리는 **발명의 완성에 의하여 발생하고 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리**로서, **발명자 또는 그 승계인**이 가진다(法 33①본문). 다만 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다(法 33①단서). **2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며**(法 33②), 그 권리가 공유인 경우에는 **공유자 모두가 특허출원을 하여야 한다**(法 44).

2. 공동발명자의 판단기준

「공동발명」이란 2명 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 함께 완성한 발명을 말하고, 공동발명자가 되려면 **기술적 사상의 창작에 실질적으로 협력하였다는 객관적 요건**과 **상호 협력하여 발명행위를 수**

행한다는 주관적 요건이 필요하다. 판례는 다음과 같이 나눈다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다 75178).

공동발명자가 아닌 경우 — i) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자, ii) 연구자를 일반적으로 관리한 자, iii) 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자, iv) **자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 자.**

공동발명자인 경우 — i) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, ii) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, iii) 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자.

「실질적 협력」이란 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미하므로, 단순한 보조자·관리자·위탁자·자본주는 공동발명자가 되지 못한다.

3. 사안의 해결

(1) **甲 — 발명자이다.** 甲은 여름용 의류를 위한 신소재를 스스로 개발하고 있던 자로서 발명의 주체이다.

(2) **乙 — 발명자가 아니다.** 乙은 자신의 연구시설과 각종 설비를 제공하여 甲의 발명 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도에 그친다. 이는 판례가 공동발명자가 아닌 경우로 든 「자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 자」에 정확히 해당한다. 곧 乙은 자본주·위탁자에 지나지 않아 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없다.

(3) **丙 — 공동발명자이다.** 丙은 甲과 함께 **실질적으로 협력 연구하여 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하여 구체화**하였고 그 결과 A 원단이 개발되었다. 이는 판례가 공동발명자로 인정하는 유형에 그대로 해당하며, 객관적 요건(창작에 실질적 협력)과 주관적 요건(상호 협력하여 발명행위 수행)이 모두 충족된다.

(4) **결론** — A 원단에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 **甲과 丙이 공유**한다(法 33①본문, 33②). 따라서 甲과 丙은 **공동으로 특허출원을 하여야 하고**(法 44), 이를 위반하여 어느 한 사람이 단독으로 출원하면 거절이유가 되며 착오로 등록되면 무효사유가 된다. 또한 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法 37③). 乙은 권리자가 아니므로 출원인이 될 수 없고, 乙을 포함시켜 출원하면 무권리자를 포함한 출원이 되어 法 33①본문 위반이 된다.

설문 2 — 논문 발표와 신규성 (20점)

1. 신규성 상실(法 29①)

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재**되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명은 특허를 받을 수 없다(法 29①Ⅱ). 「반포」란 **불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것**을 의미한다.

사안 — 甲은 2018. 5. 20. A 원단 제조에 관한 **논문을 발표**하였다. 그 논문이 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓였다면 法 29①Ⅱ의 반포된 간행물에 게재된 발명에 해당하고(발표의 형태에 따라서는 法

29① I 의 공지에도 해당한다), 그대로라면 A 원단 발명은 **신규성이 상실된다**.

2. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)

(1) 내용 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 法 30①각호에 해당하게 된 경우 **그 날부터 12개월 이내에 특허출원**을 하면, 法 29①·②를 적용할 때 그 발명은 **공지 등이 되지 아니한 것으로 본다**. 자기 발명의 공개로 출원이 특허를 받지 못하게 되는 것은 가혹하다는 데에 취지가 있다.

(2) 요건

- **주체적 요건** — 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지 등이 되었을 것. 권리자가 직접 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.
- **객체적 요건** — 法 29①각호의 공지 등에 해당하고 法 30①각호의 사유일 것. 자기 의사에 의한 공지가 이에 해당한다(法 30① I 본문). 다만 조약이나 법률에 따라 국내외에서 출원공개되거나 등록 공고된 경우는 제외된다(法 30① I 단서).
- **시기적 요건** — **최선의 공지일로부터 12개월 이내에** 특허출원할 것.

(3) 절차 자기 의사에 의하여 공지된 경우 적용받으려는 자는 **특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에** 제출하여야 한다(法 30②). 다만 보완수수료를 납부하면 法 30③이 정한 기간에도 제출할 수 있다.

3. 사안의 해결

(1) 시기적 요건 — **충족된다**. 공지일은 **2018. 5. 20.**, 출원일은 **2019. 3. 20.**로서 그 사이는 **약 10개월**이므로 **12개월 이내**이다.

(2) 주체적·객체적 요건 — **충족된다**. 논문을 발표한 자는 발명자인 甲 자신으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이고, 논문 발표는 조약이나 법률에 따른 출원공개·등록공고가 아니라 **자기 의사에 의한 공지**이므로 法 30① I 본문의 사유에 해당한다.

(3) 절차 요건 — **갖추어야 한다**. 甲이 출원서에 공지에외적용을 받으려는 취지를 적고 증명서류를 출원일로부터 **30일 이내에 제출**하면(또는 보완수수료를 납부하고 法 30③의 기간에 제출하면) 공지에외가 적용된다.

(4) 결론 — 甲이 위 절차를 밟으면 2018. 5. 20.의 논문 발표는 法 29①을 적용할 때 공지된 것으로 보지 않으므로 **신규성이 부정되지 않아 특허를 받을 수 있다**. 반대로 그 절차를 밟지 않으면 공지에외를 적용받지 못하여 자신의 논문에 의하여 **신규성이 부정된다**.

한편 A 원단은 甲과 丙의 공동발명이므로(설문 1), 출원은 甲과 丙이 **공동으로** 하여야 한다(法 44).

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
97후44	1997-12-09	1-나 구성의 곤란성·효과의 현저성
97후2033	1999-04-09	1-나 구성의 곤란성·효과의 현저성
2006후138	2007-08-24	1-나 사후적 고찰 금지
2007후3660	2009-11-12	1-나 진보성 판단의 순서·사후적 고찰 금지
95후1302	1996-10-29	1-나 상업적 성공의 참작 요건
94후1817	1995-11-28	1-나 상업적 성공의 참작 요건
2004후3546	2005-11-10	1-나 상업적 성공만으로 단정 불가
2006후3052	2008-05-29	1-나 상업적 성공만으로 단정 불가
81후56	1983-07-26	설문2 신규성 없는 특허의 권리범위
97후2095	1998-10-27	설문2 진보성 결여로는 권리범위 부정 불가
2010다95390	2012-01-19	설문2 전원합의체 — 권리남용
2009다75178	2011-07-28	제1문의2 설문1 공동발명자 판단기준

교재: 리담특허법 제25판 — 진보성의 의의·취지(388), 인용대상과 조합(396~397), 판단방법(403~407), 참고적 판단방법·상업적 성공(412~413), 무효의 항변과 자유기술의 항변(1505), 권리행사의 제한과 판례 변천(1494~1496), 공동발명(157~158), 권리의 귀속(555~556), 공지의예외(788~799), 반포의 의미(357).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·30·33·37·44·126·128조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따라왔습니다 — 진보성의 의의와 취지 (388), 판단기준과 인용대상(396~397), 판단방법(403~407), 참고적 판단방법과 상업적 성공 (412~413), 무효의 항변과 자유기술의 항변(1505), 권리행사의 제한과 판례 변천(1494~1496), 공동발명(157~158), 권리의 귀속(555~556), 공지의예외(788~799). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 10

제10회 변호사시험 · 특허법

2021년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 4개

문 제

甲은 의대 졸업 후 수련의와 전공의를 거쳐 성형외과 전문의 자격을 획득하였다. 이후 甲은 성형외과의원을 개원하였는데 왼손과 오른손 모두를 사용할 수 있는 양손잡이의 특징을 살려 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 성형방법을 사용해 고객들 사이에 널리 알려지게 되었다.

성형의료업계에서 甲의 쌍꺼풀 수술방법이 저명성을 획득하자 甲은 본격적으로 성형외과 분야를 학문적으로 연구하고 싶다는 생각을 가지게 되었다. 박사과정에 진학한 甲은 자신의 임상경험을 바탕으로 노화로 상안검(윗눈꺼풀)이 처지는 질환을 효과적인 눈 성형을 통하여 개선하는 방법을 밝혀내기 위하여 박사학위논문 주제를 ‘효과적인 상안검 수술방법’으로 정하였다.

甲이 연구 중인 눈 성형 수술방법은 기존의 방법과 전혀 다른 새로운 방법으로 수술 부위가 작아 피부에 흉터가 거의 남지 않을 뿐만 아니라 회복시간도 단축되는 현저한 효과를 가진다.

甲은 성형을 위한 눈의 수술 시에 특히 자신이 새롭게 만든 고리형 수술바늘을 사용하는데 이 바늘은 기존의 일자형 수술바늘과 비교할 때 길이가 1/3 가량 짧고 특수한 고리모양을 하고 있어 수술을 쉽고 빠르게 하고 수술자국을 작게 하는 현저한 효과를 가져 왔다.

1. 성형외과의원을 개원한 甲이 박사과정 입학 전에 시술하였던 미용을 위한 성형방법으로서 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 방법은 甲의 성형외과의원에서 공개적으로 시연되었다. 그와 같이 수술방법이 공개되고 1년이 지난 뒤에 甲은 그 수술방법을 특허출원하였다.

치료방법이 아닌 ‘미용을 위한 수술방법’은 「특허법」 제29조의 신규성을 충족하는지 설명하시오.

만약, 위 수술방법이 공개된 지 1년이 넘지 않았다면 甲의 출원발명은 신규성을 충족하는지 「특허법」 제30조 제1항 제1호의 공지되지 않은 발명과 관련하여 설명하시오. (20점)

2. 甲은 자신이 박사학위논문에서 기술한 상안검 수술방법을 의료행위로 한정하여 ‘인간의 치료를 위한 상안검 수술방법’ 발명으로 출원하였다. 甲의 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대하여 「특허법」 제29조의 산업상 이용가능성과 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명과 관련하여 설명하시오. (20점)

3. 甲이 박사과정으로 등록한 대학원은 비공개로 甲의 박사학위논문에 대한 심사를 마치고, 논문 통과를 승인하였다. 이에 甲은 도서관에 박사학위论문을 제출하였고, 甲의 논문은 분류작업을 위하여 공중에 공개되지 않은 채 방치되어 도서관 창고에 보관되어 있다. (PDF 논문 파일 등 그 밖의 다른 저장매체가 도서관에서 열람 가능한지는 고려하지 아니함) 이와 같이 甲의 논문이 도서관 창고에 보관되어 있는 도중에 甲은 질문 2.의 상안검 수술방법특허(질문 4.의 물건발명에 대한 특허가 아님)에 대하여 특허 출원하였는바, 甲의 출원발명이 신규성 요건을 충족하는지 설명하시오. (10점)

4. 甲은 자신이 개발한 수술용 바늘에 대해서 ‘물건발명’으로 특허출원을 하였다. 甲의 수술용 바늘이 「특허법」 제29조의 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)을 충족하는지 설명하시오. (30점)

해설

배점 80점 · 설문 4개(20·20·10·30). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 성형외과 전문의 甲. ① 박사과정 전 **미용 목적 쌍꺼풀 수술방법**을 의원에서 공개 시연, ② 박사논문 주제인 **치료 목적 상안검 수술방법**, ③ 그 **박사학위논문**은 도서관 창고에 분류 대기 중, ④ 새로 만든 **고리형 수술바늘**(물건발명).

설문 1 — 미용을 위한 수술방법의 신규성과 공지의외 (20점)

1. 신규성 상실사유(法 29①)

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **공지되었거나 공연히 실시된 발명**은 특허를 받을 수 없다 (法 29① I). 「공연실시」란 실시에 의하여 발명이 불특정인에게 공연히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 말하며, 「공연」이란 **발명의 주요부에 대하여 비밀상태가 해제된 것**을 의미한다. 단 1회의 실시라도 공연실시에 해당한다.

2. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 法 30①각호에 해당하게 된 경우 **그 날부터 12개월 이내에** 특허출원을 하면, 法 29①·②를 적용할 때 그 발명은 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다. 자기 의사에 의하여 공지된 경우(法 30① I 본문)에 적용받으려는 자는 **특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 증명서류를 특허출원일로부터 30일 이내에** 제출하여야 한다(法 30②). 다만 보완수수료를 납부하면 法 30③이 정한 기간에도 제출할 수 있다.

3. 사안의 해결

(1) 공개 후 1년이 지난 뒤 출원한 경우 — **신규성을 충족하지 못한다**. 甲의 쌍꺼풀 수술방법은 성형외과 의원에서 **공개적으로 시연**되어 그 주요부의 비밀상태가 해제되었으므로 法 29① I의 **공연실시**에 해당한다. 따라서 신규성이 상실된다.

나아가 공지예외를 주장하려면 공지일부터 12개월 이내에 출원하여야 하는데, 사안은 **1년이 지난 뒤** 출원하였으므로 시기적 요건을 갖추지 못한다. 결국 공지예외의 적용을 받을 수 없고 신규성은 부정된다.

(2) 공개 후 1년이 넘지 않은 경우 — **신규성을 충족할 수 있다**. 공개는 甲 자신의 시연에 의한 것이므로 **자기 의사에 의한 공지**로서 法 30① I 본문의 사유에 해당하고, 공개 당시 특허를 받을 수 있는 권리를

가진 자는 甲 본인이므로 주체적 요건도 충족한다. 따라서 甲이 **공지일부터 12개월 이내에 출원하면서 法 30②의 취지 기재와 증명서류 제출 절차를 밟으면**(또는 보완수수료를 납부하고 法 30③의 기간에 제출하면) 그 공개는 法 29①을 적용할 때 공지된 것으로 보지 않으므로 **신규성이 부정되지 않는다**.

(3) 부기 — 신규성을 충족하더라도 등록은 별개의 문제다. 설문은 신규성만을 묻고 있으나, 미용을 위한 것이라도 **수술방법**인 이상 산업상 이용가능성이 문제 된다. 심사 실무는 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과를 함께 가지면서 이를 구별·분리할 수 없으면 치료방법으로 보아 산업상 이용가능성을 인정하지 않고, 특히 **수술방법의 경우에는 미용 목적 및 용도로 한정하더라도 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 아니한다**. 따라서 공지예외로 신규성이 회복되더라도 甲의 쌍꺼풀 수술방법은 法 29①본문의 산업상 이용가능성 흠결로 등록을 받기 어렵다.

설문 2 — 치료 목적 상안검 수술방법의 산업상 이용가능성과 法 32 (20점)

1. 산업상 이용가능성과 의료행위

특허를 받으려면 **산업상 이용할 수 있는 발명**이어야 한다(法 29①본문).

의료행위는 의사들의 양심과 윤리에 관한 문제로서, 치료방법을 특허로 보호하여 특정인의 재산적 이익을 도모하기보다 인류의 생명과 건강에 기여하여야 한다는 점에서 **원칙적으로 특허의 대상이 되지 아니한다**. 그 근거로 i) 의료행위가 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있다는 점, ii) 누구나 질병의 진단·치료·경감·예방을 위한 의료방법을 선택하고 접근할 권리가 보호되어야 한다는 점, iii) 의료행위에 관한 발명을 특허 대상으로 하면 의사가 의료행위를 할 때 침해 여부를 신경 쓰게 되어 자유로운 접근이 어려워진다는 점이 제시된다.

구체적 판단기준은 **인체를 직접적인 구성요소로 하는지**이다. 인간을 대상으로 하는 수술방법·치료방법·진단방법은 인체를 필수 구성요소로 하므로 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다. 온구기로 사람의 경혈을 자극하는 방법에 관한 발명은 질병을 치료·경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위로서 인체를 필수 구성요소로 하므로 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936).

2. 法 32와의 관계

法 32는 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 특허를 받을 수 없도록 한다. 인체를 필수구성요소로 하는 발명이라도 **의료행위에 해당하지 아니하는 경우**(예: 모발의 웨이브방법에 관한 발명)에는, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 때에 비로소 法 32가 문제 된다.

곧 의료행위에 해당하면 **산업상 이용가능성 단계에서 이미 걸러지므로 法 32까지 나아갈 필요가 없고**, 法 32는 의료행위가 아니면서 인체를 구성요소로 하는 발명에 대한 규정으로 기능한다. 다만 의료행위에 특허를 부여하지 않는 근거를 산업상 이용가능성이 아니라 法 32의 불특허사유에서 찾아야 한다는 견해도 제시되고 있다.

3. 사안의 해결

甲의 출원발명은 ‘인간의 치료를 위한 상안검 수술방법’으로 **의료행위에 한정하여** 출원된 것이다. 이는 인간을 대상으로 하는 수술방법이자 치료방법으로서 인체를 직접적인 구성요소로 하므로, **法 29①본문의 산업상 이용가능성이 부정되어 특허등록을 받을 수 없다.**

法 32와 관련하여서는, 상안검 수술방법이 노화로 처진 윗눈꺼풀을 개선하여 질병을 치료하는 것으로서 그 실행이 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속한다고 볼 사정이 없으므로, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 보기 어렵다. 곧 **등록을 받을 수 없는 근거는 法 32가 아니라 산업상 이용가능성의 흠결이다.**

수술 부위가 작아 흉터가 거의 남지 않고 회복시간이 단축되는 현저한 효과가 있더라도, 그러한 효과는 진보성 판단의 자료일 뿐 산업상 이용가능성의 흠결을 치유하지 못한다.

설문 3 — 도서관 창고에 보관된 박사학위논문과 신규성 (10점)

1. 반포된 간행물(法 29①Ⅱ)

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재된 발명**은 특허를 받을 수 없다 (法 29①Ⅱ). 여기서 「반포」란 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 의미한다 (대법원 1968. 8. 30. 선고 68후10; 대법원 1970. 12. 29. 선고 70후64; 대법원 1971. 11. 23. 선고 71후18).

따라서 i) 반포할 목적으로 인쇄·제본되었으나 아직 발행자의 손안에 있어 반포에 이르지 못한 것, ii) 반포를 위해 발송 중인 간행물, iii) **도서관 사서과에는 간행물이 도착하였으나 열람실에 비치되지 아니한 경우는** 반포되었다고 할 수 없다. 반대로 도서관의 열람실에 비치되었으면 아무도 이를 읽지 아니하였더라도 반포된 것으로 본다.

2. 사안의 해결

(1) **비공개 논문심사** — 대학원은 **비공개로** 박사학위논문 심사를 마치고 통과를 승인하였다. 심사위원은 특정인에 불과하고 발명의 주요부에 대한 비밀상태가 불특정인에 대하여 해제되었다고 볼 수 없으므로, 이로써 法 29①Ⅰ의 공지가 되었다고 할 수 없다.

(2) **도서관 창고 보관** — 甲은 도서관에 논문을 제출하였으나, 그 논문은 **분류작업을 위하여 공중에 공개되지 않은 채 도서관 창고에 보관되어 있다.** 이는 도서관에 도착하기는 하였으나 **열람실에 비치되지 아니한 경우에** 해당하여 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓였다고 볼 수 없다. 따라서 **반포되었다고 할 수 없고**, 法 29①Ⅱ의 반포된 간행물에 게재된 발명에 해당하지 않는다.

(3) **결론** — 甲의 상안검 수술방법 출원발명은 **신규성 요건을 충족한다.**

다만 설문 2에서 본 바와 같이 그 출원발명은 인간의 치료를 위한 수술방법으로서 산업상 이용가능성이 부정되므로, 신규성을 충족하더라도 등록을 받을 수는 없다.

설문 4 — 수술용 바늘(물건발명)의 특허요건 (30점)

1. 산업상 이용가능성(法 29①본문)

인체를 **간접적인 구성요소로 하거나 구성요소로 하지 아니한 경우에는** 의료업이라도 산업상 이용가능성이 인정된다. 의료행위를 돕는 장비 등의 발명에까지 특허를 부여하지 않으면 의료장비의 개발과 첨단화를 기대할 수 없어 결과적으로 의료수준의 퇴보를 낳기 때문이다. 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니한 **의료행위에 사용하는 의료기기·장치 또는 의약품**은 산업상 이용가능성이 인정된다. 앞서 본 온구기 사건에서도 경혈 자극 **방법**은 산업상 이용가능성이 없지만 **온구기 자체는 인체를 구성요소로 하지 아니하므로 산업상 이용할 수 있는 발명에** 해당한다고 하였다.

사안 — 甲의 고리형 수술바늘은 수술에 사용되는 **기구, 곧 물건발명**으로서 인체를 직접적인 구성요소로 하지 않는다. 따라서 산업상 이용가능성이 인정된다. 수술방법 자체는 특허를 받을 수 없더라도 그 수술에 쓰이는 바늘은 별개로 특허의 대상이 된다.

2. 신규성(法 29①)

甲의 수술바늘은 기존의 일자형 수술바늘과 달리 **甲이 새롭게 만든** 것으로서, 그 구조가 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통해 공개되었다는 사정은 나타나 있지 않다.

다만 검토를 요하는 것은 **공연 실시** 여부이다. 甲은 성형을 위한 눈 수술 시에 이 바늘을 사용하고 있는데, 「공연」이란 발명의 주요부에 대하여 비밀상태가 해제된 것을 의미하므로, 그 사용으로 **바늘의 주요부(길이와 고리모양의 구조)가 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 놓였는지**를 살펴야 한다. 수술실에서 의료진과 환자에게만 사용된 것에 그치고 그 구조가 불특정인이 알 수 있는 상태에 이르지 않았다면 공연실시라고 할 수 없어 신규성이 인정된다. 반대로 그 구조가 공연히 알려질 수 있는 상태에 놓였다면 신규성이 부정되며, 이 경우에도 甲은 공지일부터 12개월 이내에 출원하면서 法 30②의 절차를 밟아 공지예외를 주장할 수 있다.

3. 진보성(法 29②)

특허출원 전에 통상의 기술자가 法 29①각호의 발명에 의하여 **쉽게 발명할 수 있으면** 특허를 받을 수 없다. 진보성 판단의 대상은 산업상 이용가능성과 신규성을 만족하는 발명이어야 하고, 판단은 객관적 타당성에 따라야 하며 **사후적 고찰을 해서는 안 된다**. 발명의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 많으므로, 출원 전의 상태로 돌아가 그 지식을 알지 못한다는 전제에서 판단하여야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138).

사안 — 甲의 수술바늘은 기존의 일자형 수술바늘과 비교할 때 i) **길이가 1/3 가량 짧고**, ii) **특수한 고리모양**을 하고 있어 구성에 차이가 있다. 나아가 그 결과 iii) **수술을 쉽고 빠르게 하고 수술자국을 작게 하는 현저한 효과**를 가져왔다. 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 모두 인정되므로 통상의 기술자가 기존 일자형 바늘로부터 쉽게 발명할 수 있었다고 보기 어렵다. 따라서 **진보성이 인정된다**.

이때 甲이 완성한 바늘의 구조를 알고 난 뒤 그것이 간단해 보인다는 이유로 쉽게 발명할 수 있었다고 판단하는 것은 금지되는 사후적 고찰에 해당한다.

4. 결론

甲의 수술용 바늘은 산업상 이용가능성과 진보성을 충족하며, 그 구조가 공연히 알려질 수 있는 상태에 놓이지 않았다면 신규성도 충족하므로, 다른 거절이유가 없는 한 **특허를 받을 수 있다**.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2005후1936	2006-08-25	설문2·4 온구기 — 방법은 부정, 기구는 인정
68후10	1968-08-30	설문3 「반포」의 의미
70후64	1970-12-29	설문3 「반포」의 의미
71후18	1971-11-23	설문3 「반포」의 의미
2006후138	2007-08-24	설문4 사후적 고찰 금지

교재: 리담특허법 제25판 — 산업상 이용가능성과 의료행위(335~339), 신규성·공연실시·반포(346~348, 353~358), 공지예외(788~799), 진보성 판단방법(403~404).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·30·32조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 산업상 이용가능성과 의료행위(335~339), 신규성과 공연실시·반포(346~348, 353~358), 공지예외(788~799), 진보성 판단방법(403~404). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 11

제11회 변호사시험 · 특허법

2022년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 7개

문 제

甲은 $a+b+c$ 로 구성된 특허발명 X를 이용한 제품 A를 제조, 판매하고 있었다. 이를 눈여겨보아 온 乙은 연구개발을 통해 특허발명 X에 새로운 구성요소 d를 추가한 발명 Y[($a+b+c$)+d]를 완성하여 특허출원한 후 이를 이용하여 제작한 제품 A'를 신상품으로 출시하며 대대적인 광고를 하였다. 乙의 발명 Y는 각광을 받아 관련 제품시장에서 시장점유율이 절반에 이르는 성과를 얻었다. 한편 乙은 甲의 특허권침해금지 소송 제기에 대비해 특허조사를 해 본 결과 甲의 특허발명 X가 관련업계의 공지기술인 ($a+b$)에 공지기술 c를 단순히 추가한 것으로 통상의 기술자(당업자)가 쉽게 개발할 수 있는 것인데도 심사 착오로 특허권이 등록되었다고 보아 甲의 특허권은 무효라고 확신하게 되었다.

1. 乙이 출원한 발명 Y가 특허를 받을 수 있는지를 신규성과 진보성 요건의 충족 여부를 중심으로 논하시오. (25점)
2. 甲이 乙을 상대로 법원에 특허권침해금지청구의 소를 제기하였다. 그 심리 과정에서 乙은 甲의 특허발명 X에 대한 특허무효심판 절차를 거치지 않고 특허발명 X가 신규성, 진보성이 없어 무효라고 주장하였다. 법원이 乙의 주장을 직접 심리·판단할 수 있는지를 판례의 변천 과정을 중심으로 논하시오. (20점)
3. 甲은 乙이 발명 Y를 실시하는 것이 甲의 특허권을 침해한다고 판단하여 그로 인한 손해를 배상받자 한다. (위 사례의 사실관계와는 독립적인 것으로 본다)
가. 특허권침해로 인한 손해배상청구권의 성립요건을 설명하시오. (5점)
나. 「특허법」 제128조 제1항의 “고의”와 「특허법」 제128조 제8항의 “고의적인 것으로 인정되는 경우”의 차이점을 설명하시오. (5점)
다. 甲이 「특허법」 제128조 제8항에 따른 배상액을 최대로 인정받기 위해 주장·입증해야 할 사항들을 설명하시오. (10점)
4. 乙이 발명 Y에 관하여 특허권을 취득한 후 甲의 특허권이 유효한 동안 특허발명 X와 이용관계(「특허법」 제98조)에 있는 자신의 특허발명을 합법적으로 실시하기 위해 통상실시권 허락의 심판(「특허법」 제138조)을 청구하려고 한다.
가. 「특허법」상 이용관계에 대해 설명하시오. (5점)
나. 乙의 심판청구가 인용되기 위한 요건을 논하시오. (10점)

해설

배점 80점 · 설문 7개(25·20·5·5·10·5·10). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 甲의 특허발명 $X = a+b+c$. 乙은 여기에 구성요소 d를 더한 $Y = (a+b+c)+d$ 를 완성해 출원하고 제품 A'를 출시, 시장점유율 절반에 이르렀다. 한편 乙은 X가 공지기술 (a+b)에 공지기술 c를 단순 추가한 것이어서 무효라고 본다.

★**현행법 기준 주의** — 法 128⑧의 증액배상 한도는 2024. 2. 20. 개정으로 **5배**가 되었습니다(출제 당시는 3배). 기출이라도 현행법으로 푸는 원칙에 따라 5배로 씁니다.

설문 1 — 발명 Y의 신규성·진보성 (25점)

1. 특허요건 판단과 침해 판단은 별개다

발명을 출원하였을 때 특허를 받을 수 있는지(특허요건)와 그 실시가 타인의 특허를 침해하는지 (침해성립요건)는 **전혀 별개의 문제**이다. 특허요건은 선행기술과의 관계에서 동일성·용이성을 보는 것이고, 침해는 선행특허와의 관계에서 구성요소완비의 원칙과 균등론에 따라 보호범위에 속하는지를 보는 것이기 때문이다. 설문 1은 이 중 **특허요건**만을 묻는다.

2. 신규성(法 29①)

「a+b+c」인 특허발명에 대하여 「a+b+c+d」를 출원한 경우, **다기재 협범위의 원칙**에 따라 a+b+c+d는 a+b+c보다 **하위개념 발명**이므로 a+b+c와 **동일성이 없다**. 따라서 신규성 (法 29①각호)이나 확대된 선출원(法 29③④), 선출원주의(法 36) 위반의 문제는 생기지 않는다.

3. 진보성(法 29②)

문제는 진보성이다. X가 공개된 뒤에 Y를 출원하였다면 X는 선행기술이 되므로, 통상의 기술자가 X로부터 Y를 쉽게 발명할 수 있는지를 본다. **구성요소 d의 결합에 곤란성이 있거나 효과의 현저성이 있으면 진보성이 인정되어** 다른 거절이유가 없는 한 특허를 받을 수 있다.

진보성 판단에서는 **사후적 고찰이 금지된다**. 발명의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 많으므로, 출원 전의 상태로 돌아가 그 지식을 알지 못한다는 전제에서 판단하여야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138).

4. 사안의 해결

(1) **신규성 — 인정된다**. Y는 X에 구성요소 d를 부가한 하위개념 발명으로서 X와 동일성이 없으므로 신규성이 부정되지 않는다.

(2) **진보성** — 인정될 여지가 크다. 乙은 연구개발을 통해 d를 추가하여 Y를 완성하였고, Y를 이용한 제품 A'는 각광을 받아 관련 제품시장에서 **시장점유율이 절반에 이르는 성과**를 얻었다. 이는 d의 결합으로 효과의 현저성이 있음을 뒷받침하는 사정이다. 다만 상업적 성공은 진보성을 뒷받침하는 하나의 자료일 뿐이므로, 궁극적으로는 d의 결합에 곤란성이 있는지와 그로써 현저한 효과가 생겼는지를 기술적으로 판단하여야 한다.

(3) **유의할 점** — 乙은 X 자체가 공지기술 (a+b)에 c를 단순 추가한 것이어서 진보성이 없다고 보고 있으나, 그것은 **X의 특허요건에 관한 문제**이지 Y의 특허요건 판단과는 구별된다. 다만 X가 진보성이 없어 공중의 영역에 속한다면 그 내용은 Y의 진보성 판단에서 선행기술로 참작될 수 있다.

설문 2 — 법원이 무효 주장을 직접 심리·판단할 수 있는지 (20점)

1. 원칙 — 등록주의와 권리범위

등록주의를 관철하여 법적 안정성을 도모하기 위하여, 특허에 무효사유가 있더라도 **특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전에는** 그 특허권이 유효한 것으로 다루어지는 것이 원칙이다.

2. 신규성이 없는 경우 — 종래부터 권리범위가 부정된다

특허발명이 공지기술과 동일하여 신규성이 없음에도 착오로 등록되었으면, **특허취소결정이나 무효심결이 확정되어 특허권이 소멸하기 전이라도 그 보호범위를 인정할 수 없다**는 것이 종래부터의 판례이다 (대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 등).

3. 진보성이 없는 경우 — 판례의 변천

(1) **종전의 태도** 침해소송을 담당하는 법원이 진보성 결여라는 무효사유를 심리·판단할 수 있는지에 관하여, 당초 이를 부정하는 판결(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 등)과 긍정하는 판결 (대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225; 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699; 대법원 1997. 8. 22. 선고 97후68 등)이 나뉘어 있었으나, **대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 이래로는 진보성 결여에 대해서는 심리·판단할 수 없고 그 결과 진보성 결여를 이유로 보호범위를 부정할 수 없다**는 입장을 유지하여 왔다.

(2) **대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결** 대법원은 태도를 바꾸어, 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 잘못 특허등록이 이루어졌음에도 별다른 제한 없이 이를 독점시키면 공공의 이익을 부당하게 훼손하고 특허법의 입법목적에도 배치되며, 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 등록되어 있음을 기화로 실시자를 상대로 청구할 수 있게 하는 것은 실질적 정의와 형평에 어긋난다는 점을 들어, **특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고** 판시하였다. 나아가 법원은 그러한 권리남용 항변의 당부를 살피기 위한 전제로서 진보성 여부를 심리·판단 할 수 있다고 하였다.

(3) 종전 판례와의 비교

	중전 판례(97후2095 등)	2010다95390 전합
진보성 결여로 권리범위를 부정하는지	×	×
침해소송에서 진보성을 심리할 수 있는지	×	○
권리행사가 가능한지	○	무효로 될 것임이 명백하고 특별한 사정이 없으면 권리남용으로 불가

전합 판결은 **권리범위 자체는 여전히 부정하지 않으면서도**, 법원이 진보성을 심리할 수 있고 그 결과 권리행사를 권리남용으로 막을 수 있다고 한 점에 특색이 있다. 여기서 「특별한 사정」이란 무효사유가 있더라도 정정심판이나 정정청구로 이를 극복할 수 있는 사정을 말한다.

4. 사안의 해결

乙은 X가 **신규성과 진보성이 모두 없어** 무효라고 주장한다.

- **신규성 부분:** X가 공지기술과 동일하여 신규성이 없다면 종래 법리에 따라 무효심결 확정 전이라도 X의 보호범위를 인정할 수 없으므로, 법원은 이를 심리·판단할 수 있다.
- **진보성 부분:** 사안에서 X는 공지기술 (a+b)에 공지기술 c를 단순히 추가한 것으로 통상의 기술자가 쉽게 개발할 수 있는 것이라고 한다. 이것이 인정되어 **무효로 될 것임이 명백**하다면, 甲의 침해금지 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 해당한다. 법원은 그 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 **진보성 여부를 직접 심리·판단할 수 있다.**

결론: 법원은 乙의 주장을 무효심판 절차를 거치지 않고도 직접 심리·판단할 수 있다.

설문 3 — 손해배상 (20점)

가. 손해배상청구권의 성립요건 (5점)

특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 민법상 불법행위(民 750)의 특칙이므로 그 성립요건도 이에 준한다. 곧 i) **특허권 또는 전용실시권의 침해**가 있을 것, ii) 침해자에게 **고의 또는 과실**이 있을 것, iii) **손해가 발생**하였을 것, iv) 침해와 손해 사이에 **인과관계**가 있을 것이다(法 128①).

이 중 과실은 法 130에 의하여 추정되므로 특허권자가 따로 증명할 필요가 없고, 손해액에 관하여도 法 128②부터 ⑦까지의 산정·추정 규정이 증명의 부담을 덜어 준다.

나. 法 128④의 「고의」와 法 128⑧의 「고의적인 것으로 인정되는 경우」의 차이 (5점)

	法 128④의 「고의」	法 128⑧의 「고의적인 것으로 인정되는 경우」
기능	손해배상책임의 성립요건	배상액의 가중요건(증액배상)
주관적 요건의 정도	고의 또는 과실이면 족하다	고의여야 하고 과실로는 부족하다
증명	과실은 法 130으로 추정된다	추정규정이 없고, 法 128⑨의 고려사항을 통해 법원이 판단한다
효과	실제 손해액의 배상	손해로 인정된 금액의 5배 를 넘지 않는 범위에서 배상액 결정

곧 法 128④의 고의는 **책임이 성립하는가**의 문제이고, 法 128⑧의 「고의적」은 책임이 이미 성립한 것을 전제로 **얼마를 물릴 것인가**의 문제이다. 후자는 법원이 法 128⑨ 각호의 사정을 고려하여 인정하는 것이므로, 단순히 침해에 고의가 있었다는 것만으로 곧바로 증액되는 것은 아니다.

다. 法 128⑧에 따라 배상액을 최대로 인정받기 위해 주장·증명할 사항 (10점)

(1) 전제 — 손해로 인정된 금액의 극대화 法 128⑧의 증액은 「제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액」을 기준으로 하므로, 먼저 그 기준액 자체를 최대한 인정받아야 한다. 곧 양도수량에 따른 산정(法 128②), 침해자 이익액의 손해액 추정(法 128④), 실시료 상당액(法 128⑤) 중 자신에게 가장 유리한 산정방법의 요건사실을 주장·증명하여야 한다.

(2) 침해행위가 고의적일 것 丁의 침해가 고의적인 것으로 인정되어야 한다.

(3) 法 128⑨ 각호의 고려사항 법원은 증액 여부와 그 정도를 판단할 때 다음을 고려하여야 하므로, 甲은 각 항목에서 자신에게 유리한 사정을 주장·증명하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 **우월적 지위** 여부
2. **고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도**
3. 침해행위로 인하여 특허권자·전용실시권자가 입은 **피해규모**
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 **경제적 이익**
5. 침해행위의 **기간·횟수** 등
6. 침해행위에 따른 **벌금**
7. 침해행위를 한 자의 **재산상태**
8. 침해행위를 한 자의 **피해구제 노력의 정도**

곧 甲으로서의 침해자가 시장에서 우월적 지위에 있었다는 점, 특허의 존재를 알면서도 침해를 계속하였다는 점, 침해기간이 길고 횟수가 많다는 점, 침해로 얻은 이익이 크고 자신의 피해규모가 크다는 점, 침해자가 피해구제를 위한 노력을 하지 않았다는 점 등을 구체적으로 주장·증명하여야 한다.

설문 4 — 이용관계와 통상실시권 허락의 심판 (15점)

가. 특허법상 이용관계 (5점)

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 자기의 특허발명이 **그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그와 유사한 디자인을 이용하는 경우에는 그 권리자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다**(法 98).

전형적인 모습이 **구성요소의 부가**이다. 선출원 특허발명이 「a+b+c」이고 후출원 발명이 「a+b+c+d」인 경우, 후자를 실시하면 구성요소완비의 원칙상 전자의 보호범위에 속하게 되므로 정당한 권원이 없으면 침해가 된다. 이때 「a+b+c+d」가 등록되면 이를 **이용관계**라 한다.

이용관계는 i) 특허발명 상호 간은 물론 ii) 특허발명과 등록실용신안, iii) 특허발명과 등록디자인 또는 그와 유사한 디자인 사이에서도 발생한다.

후출원 권리자가 선출원 권리자의 허락을 받지 않고, 통상실시권 허락의 심판에 의하지도 않은 채 자기의 특허발명을 업으로 실시하면 **선출원 권리의 침해**가 되어 민·형사상 제재를 받는다.

나. 乙의 심판청구가 인용되기 위한 요건 (10점)

① **이용·저촉관계에 해당할 것** 해당 특허발명이 法 98에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우여야 한다(法 138①).

② **타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 허락을 받을 수 없을 것** (法 138①). 「정당한 이유」란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다. 후출원 권리자는 **심판청구 전에 선출원 권리와 협의하여 실시허락을 받으려는 노력을 하여야 하고**, 그러하지 아니하면 부적법한 심판청구로서 심결각하된다(法 142).

③ **자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위일 것** (法 138①). 선출원 특허발명이 「A+B」이고 후출원 특허발명이 「A+B+C」인 경우, 후출원 특허권자는 **A+B+C의 실시에 필요한 범위에서만** 통상실시권 허락을 구할 수 있고, A+B의 실시에 필요한 범위까지 구할 수는 없다.

④ **상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져올 것** 그 특허발명이 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 **상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다**(法 138②).

효과 — 이렇게 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자 등에게 **대가를 지급**하여야 하며, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 **공탁**하여야 한다(法 138④). 한편 통상실시권을 허락한 선출원 권리자가 후출원 특허발명을 실시할 필요가 있는데 후출원 권리자가 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없으면, 선출원 권리자도 그 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法 138③).

사안 — Y는 X에 d를 부가한 발명으로서 X를 이용하는 관계에 있고, 乙이 Y에 관하여 특허권을 취득하였으므로 이용관계에 해당한다(①). 乙은 甲과 협의하여 실시허락을 구하였으나 甲이 정당한 이유 없이 이를 거절하였어야 하고(②), Y의 실시에 필요한 범위에서 청구하여야 하며(③), Y가 X와 비교하여

상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이어야 한다(④). Y가 시장점유율 절반에 이르는 성과를 거두었다는 사정은 ④의 판단에서 유리한 자료가 될 수 있다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2006후138	2007-08-24	설문1 사후적 고찰 금지
81후56	1983-07-26	설문2 신규성 없는 특허의 권리범위
91마540	1992-06-02	설문2 진보성 심리 부정설
90후2225	1991-10-25	설문2 진보성 심리 긍정설
96후1699	1997-07-22	설문2 진보성 심리 긍정설
97후68	1997-08-22	설문2 진보성 심리 긍정설
97후2095	1998-10-27	설문2 종전 판례의 확립
2010다95390	2012-01-19	설문2 전원합의체 — 권리남용

교재: 리담특허법 제25판 — 특허요건과 침해 판단의 구별(1591), 권리행사의 제한과 판례의 변천(1494~1496), 이용·저촉발명(1592, 1607, 1613), 통상실시권 허락의 심판(1897~1898).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·36·98·128·130·138·142조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조. ★法 128⑧의 배상 한도는 2024. 2. 20. 개정으로 3배 → **5배**.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따라왔습니다 — 특허요건 판단과 침해 성립요건 판단의 구별(1591), 권리행사의 제한과 판례의 변천(1494~1496), 이용·저촉발명(1592, 1607, 1613), 통상실시권 허락의 심판 요건(1897~1898). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 12

제12회 변호사시험 · 특허법

2023년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 6개

문 제

‘네오 코로나(Neo-Corona)’라고 명명된 새로운 바이러스가 몇몇 국가의 일부 지역에서 발견되었고, 인간과 동물이 이 바이러스에 감염되어 전 세계적으로 유행이 되자, 의료인 甲은 이 바이러스에 대한 항체형성에 효과를 가진 예방백신을 개발하기 위하여 기존 연구 성과를 뛰어넘는 새로운 연구 프로젝트를 시작했다. 이에 甲은 乙회사로부터 연구비를 지원받음과 동시에 乙회사의 사무직원 丙의 보조를 받아 이 바이러스 감염에 효과적으로 대처할 수 있는 새로운 A 예방백신을 개발하였다. 이뿐만 아니라 甲은 네오 코로나에 감염된 환자에 대하여 기존의 방식과는 완전히 다르게 패치를 이용한 B 치료방법을 개발하였다.

이 백신은 인간뿐만 아니라 동물에 대해서도 매우 효과적인 성과를 내어, 세계 각국이 네오 코로나에 대응할 수 있었다. 세계보건기구(WHO)에서도 A 예방백신과 패치를 이용한 B 치료방법의 효과성을 인정하여, 전 세계 국가들에 이 백신을 접종하여 네오 코로나 바이러스 감염과 부작용을 방지할 것을 권고했다.

甲, 乙, 丙은 이 예방백신 등에 대하여 한국 특허청(KIPO)에 특허출원을 하려고 한다.

- 1-1. 위 바이러스 백신 발명이 네오 코로나 감염에 효과적인 A 예방백신으로 특허를 받기 위하여 「특허법」 제29조에 규정한 신규성과 진보성의 특허요건을 충족하는지 설명하시오. (20점)
- 1-2. 패치를 이용한 甲의 B 치료방법에 대한 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대하여 「특허법」 제29조에 규정한 산업상 이용가능성 및 제32조와 관련하여 설명하시오. (10점)
2. 연구비를 지원한 乙회사가 특허를 받을 수 있는지 여부를 「특허법」 제33조를 중심으로 설명하시오. (10점)
3. 甲의 A 예방백신에 대하여 상세히 알고 있던 丙이 자신의 이름으로 특허출원을 하여 등록을 하였을 경우, 이를 알게 된 甲이 무효심판청구 등에 갈음하여 「특허법」 제99조의2에 따른 특허권의 이전청구가 가능한지에 대하여 설명하시오. (15점)
4. 甲이 A 예방백신에 대하여 출원하여 특허등록을 받은 후에, 경쟁자인 丁은 甲의 백신을 복제하여 시판하였다.
 - 1) 甲이 丁에 대하여 어떠한 조치를 취할 수 있는지 설명하시오. (20점)
 - 2) 甲이 丁에 대하여 손해배상청구를 하는 경우에 과실의 입증에 관하여 설명하시오. (5점)

해설

배점 80점 · 설문 6개(20·10·10·15·20·5). 문제 원문은 자료집(../변호사시험-지적재산권법-기출자료집.md) 참조.

사실관계 요지 — 의료인 甲이 乙회사의 연구비 지원과 乙회사 사무직원 丙의 보조를 받아 A 예방백신을 개발하고, 별도로 패치를 이용한 B 치료방법을 개발했다. WHO가 효과성을 인정해 각국에 접종을 권고했고, 그 뒤 甲·乙·丙이 특허출원을 하려 한다.

설문 1-1 — A 예방백신의 신규성·진보성 (20점)

1. 신규성(法 29①)

산업상 이용할 수 있는 발명이라도 i) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **공지되었거나 공연히 실시된 발명**(法 29① I), ii) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명**(法 29① II)은 특허를 받을 수 없다. 「신규성」이란 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 것, 곧 객관적 창작성이 있는 것을 말한다. 특허법은 신규한 발명을 공개한 자에게만 공개의 대가로 특허권을 부여하고, 공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하도록 하기 위하여 신규성을 요구한다.

2. 진보성(法 29②)

특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 法 29①각호의 발명에 의하여 **쉽게 발명할 수 있으면** 특허를 받을 수 없다.

진보성 판단에는 다음이 전제된다. i) **판단의 대상은 산업상 이용가능성과 신규성을 만족하는 발명**이다(法 29② 「제1항에도 불구하고」의 해석). 신규성이 없으면 그 사유만으로 특허를 받을 수 없으므로 진보성을 판단할 필요가 없다. ii) 판단은 객관적 타당성에 따라야 하고 **사후적 고찰을 해서는 안 된다**. 발명의 내용을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 많으므로, 출원 전의 상태로 돌아가 그 지식을 알지 못한다는 전제에서 판단 하여야 한다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

3. 사안의 해결

(1) **신규성 — 출원 전 공개 여부가 관건이다**. A 예방백신은 기존 연구 성과를 뛰어넘는 새로운 것이므로 그 자체로는 공지된 바 없다. 그러나 사실관계에 따르면 **특허출원을 하려는 시점 이전에 이미 WHO가 A 예방백신의 효과성을 인정하여 각국에 접종을 권고하였고 세계 각국이 이에 대응하였다**. 백신이 각국에 접종되어 그 내용이 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓였다면 이는 法 29① I의 **공지 또는 공연실시**에 해당할 수 있고, 관련 내용이 간행물에 게재되었다면 法 29① II에도 해당할 수 있다. 그 경우 신규성은 부정된다.

다만 그 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지된 경우라면, **공지일부터 12개월 이내에 출원하면서 法 30②의 취지 기재와 증명서류 제출 절차를 밟아 공지예외를 주장** 할 수 있고, 이때에는 法 29①·②를 적용할 때 공지되지 아니한 것으로 보므로 신규성이 부정되지 않는다. 결국 **출원 시점과 공지예외 주장 여부에 따라 결론이 갈린다.**

(2) 진보성. 신규성이 인정되거나 공지예외가 적용됨을 전제로 진보성을 본다. A 예방백신은 기존 연구 성과를 뛰어넘는 새로운 연구의 결과물로서, 인간뿐 아니라 동물에 대해서도 매우 효과적인 성과를 내어 WHO가 그 효과성을 인정할 정도에 이르렀다. 통상의 기술자가 기존 기술로부터 쉽게 발명할 수 있었다고 보기 어려우므로 진보성이 인정될 여지가 크다. 이때 백신이 완성된 뒤의 성과를 근거로 그 완성이 쉬웠다고 판단하는 것은 금지되는 사후적 고찰에 해당한다.

설문 1-2 — B 치료방법의 산업상 이용가능성과 法 32 (10점)

1. 산업상 이용가능성과 의료행위

특허를 받으려면 **산업상 이용할 수 있는 발명**이어야 한다(法 29①본문).

의료행위를 하는 의사들의 양심과 윤리에 관한 문제로서, 치료방법을 특허로 보호하여 특정인의 재산적 이익을 도모하기보다 인류의 생명과 건강에 기여하여야 한다는 점에서 **의료행위는 원칙적으로 특허의 대상이 되지 아니한다.** 그 근거로는 i) 의료행위가 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있다는 점, ii) 누구나 질병의 진단·치료·경감·예방을 위한 의료방법을 선택하고 접근할 권리가 보호되어야 한다는 점, iii) 의료행위에 관한 발명을 특허 대상으로 하면 의사가 의료행위를 할 때 침해 여부를 신경쓰게 되어 자유로운 접근이 어려워진다는 점이 제시된다.

구체적 판단기준은 **인체를 직접적인 구성요소로 하는지**이다.

- **산업상 이용가능성이 부정되는 경우:** 인간을 대상으로 하는 수술방법·치료방법·진단방법, 인체로부터 채취한 것을 채취한 자에게 치료를 위해 되돌려 줄 것을 전제로 처리하는 방법 등 인체를 직접적인 구성요소로 하는 발명. 온구기로 사람의 경혈을 자극하는 방법에 관한 발명은 질병을 치료·경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위로서 인체를 필수 구성요소로 하므로 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936).
- **산업상 이용가능성이 인정되는 경우:** 인체를 간접적인 구성요소로 하거나 구성요소로 하지 않는 경우. 의료행위에 사용하는 의료기기·장치 또는 의약품, 의료기기의 작동방법, **인간 이외의 동물에 한정함을 청구범위에 명시하는 경우**(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250) 등이 이에 해당한다. 위 온구기 사건에서도 온구기 자체는 인체를 구성요소로 하지 않으므로 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

2. 法 32와의 관계

法 32는 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대하여 특허를 받을 수 없도록 한다. 인체를 필수구성요소로 하는 발명이라도 **의료행위에 해당하지 아니하는**

경우(예: 모발의 웨이브방법에 관한 발명)에는, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 때에 비로소 法 32의 문제가 된다. 한편 의료행위에 특허를 부여하지 않는 근거를 산업상 이용가능성이 아니라 法 32의 불특허사유에서 찾아야 한다는 견해도 제시되고 있다.

3. 사안의 해결

B 치료방법은 **네오 코로나에 감염된 환자를 대상으로** 패치를 이용하여 치료하는 방법으로서, 인간을 대상으로 하는 치료방법이자 인체를 직접적인 구성요소로 하는 발명이다. 따라서 **산업상 이용가능성이 부정되어(法 29①본문) 특허등록을 받을 수 없다.**

法 32와 관련하여서는, B 치료방법이 그 실행에 있어 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속한다고 볼 사정이 없고 오히려 질병 치료에 기여하는 것이므로, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다. 곧 등록을 받을 수 없는 근거는 法 32가 아니라 **산업상 이용가능성의 흠결**에 있다.

다만 **패치 그 자체**(물건 발명)는 인체를 직접적인 구성요소로 하지 않으므로 산업상 이용가능성이 인정되고, 청구범위를 **인간 이외의 동물에 한정하여 명시**하는 방법으로 출원하는 것도 가능하다.

설문 2 — 乙회사가 특허를 받을 수 있는지 (10점)

1. 특허를 받을 수 있는 자(法 33)

특허를 받을 수 있는 권리는 **발명자 또는 그 승계인**이 가진다(法 33①본문). 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 그 권리를 공유하고(法 33②), 공유인 경우 공유자 모두가 특허출원을 하여야 한다(法 44).

공동발명자가 되기 위해서는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 협력하였다는 객관적 요건과 상호 협력하여 발명행위를 수행한다는 주관적 요건이 필요하다. **자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 자나 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 단순보조자**는 공동발명자가 되지 못한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178).

2. 사안의 해결

(1) 乙회사 — 乙회사는 甲에게 **연구비를 지원**하였을 뿐이다. 이는 자금을 제공하여 발명의 완성을 후원한 것에 지나지 않으므로 乙회사는 발명자가 아니다. 나아가 乙회사는 법인으로서 자연인이 아니므로 발명자가 될 수 없다.

(2) 丙 — 丙은 乙회사의 **사무직원으로서 보조**하였을 뿐 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 제시하거나 실험을 통해 착상을 구체화한 바 없다. 단순보조자에 해당하여 역시 발명자가 아니다.

(3) 결론 — A 예방백신의 발명자는 甲뿐이고, 특허를 받을 수 있는 권리는 甲에게 원시적으로 귀속된다(法 33①본문). 甲·乙·丙이 함께 출원한다면 이는 **무권리자를 포함한 출원**이 되어 法 33①본문 위반

의 거절이유·무효사유가 된다.

乙회사가 특허를 받으려면 **甲으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계**받아야 한다 (法 33① 본문의 「승계인」). 이 권리는 재산권으로서 이전할 수 있고(法 37①), 출원 전 승계이므로 승계인인 乙회사가 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(法 38①). 한편 甲은 乙회사의 종업원이 아니라 연구비를 지원받았을 뿐이므로 **직무발명의 문제는 생기지 않는다**.

설문 3 — 法 99의2에 따른 특허권의 이전청구 (15점)

1. 무권리자의 특허와 정당한 권리자의 구제

발명자가 아니고 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인도 아닌 자를 무권리자라 한다. 무권리자가 한 출원이 등록되면 法 33① 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 것이 되어 **특허무효사유(法 133①Ⅱ)**에 해당한다.

이 경우 정당한 권리자의 구제수단은 둘이다. i) 法 34·35에 따라 **별도로 특허출원**을 하여 무권리자의 출원 시로 출원일을 소급받는 방법과, ii) 法 99의2에 따라 **특허권의 이전을 청구** 하는 방법이다.

2. 특허권의 이전청구(法 99의2)

(1) **요건과 내용** 특허가 法 33① 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 특허 무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우, **특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다**(法 99의2①).

(2) **두 구제수단의 선택** 이전청구를 할지 별도 출원을 할지는 정당한 권리자의 선택 문제이다. 같은 발명이라도 발명의 설명이나 청구범위를 어떻게 기재하느냐에 따라 권리범위가 달라지므로, **권리범위를 다시 설계할 필요가 있으면 별도 출원**을, **절차의 신속성과 편의성을 고려하면 이전청구**를 선택하면 된다. 무권리자의 출원·특허가 배척된 뒤 정당한 권리자가 다시 출원하여 심사를 받는 것은 권리 회복에 장기간이 걸린다는 불편이 있다.

(3) **효과 — 권리의 귀속시기** 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우, 해당 특허권과 보상금청구권은 **그 특허권이 설정등록된 날부터** 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 (法 99의2②). 처음부터 특허권을 취득할 수 있었던 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이고, 그 발명의 공개로 이미 산업발달에 기여하였기 때문이다. 그 결과 종전 특허권자가 특허권이나 보상금청구권의 행사로 얻은 이익은 부당이득으로 반환하여야 하고, 이전등록 전에 종전 특허권자가 한 실시권 허락계약도 효력을 잃게 되나, 일정한 경우 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권 (法 103의2)으로 실시권자가 보호될 수 있다.

3. 사안의 해결

丙은 甲의 A 예방백신 발명을 상세히 알고 있었을 뿐 발명자가 아니고 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인도 아니므로 **무권리자**이다. 丙 명의의 특허는 法 33① 본문 위반으로 法 133①Ⅱ의 무효사유에 해

당한다.

따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 甲은 **무효심판청구에 갈음하여 法 99의2①에 따라 법원에 그 특허권의 이전을 청구할 수 있다**. 이전등록을 받으면 그 특허권은 설정등록된 날부터 甲에게 있었던 것으로 보므로(法 99의2②), 무효심판을 거쳐 다시 출원·심사를 받는 것보다 신속하게 권리를 회복할 수 있다.

설문 4-1 — 甲이 丁에 대하여 취할 수 있는 조치 (20점)

丁은 甲의 백신을 **복제하여 시판**하였으므로 정당한 권원 없이 업으로 특허발명을 실시한 것이어서 침해가 성립한다.

(1) 침해금지 및 예방청구권(法 126①) 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 특허권은 물권에 준하는 권리이므로 그 지배상태가 침해된 때 물권적 청구권과 같은 권리가 인정된다. 이는 현재 또는 장래의 침해에 대한 것이라는 점에서 과거의 침해에 대한 손해배상·부당이득반환 청구와 구별되며, 가장 유효하고 직접적인 구제 수단이다.

(2) 폐기·제거 등 청구(法 126②) 위 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 함께 청구할 수 있다. 甲은 복제된 백신 제품의 폐기와 그 생산설비의 제거를 청구할 수 있다.

(3) 손해배상청구권(法 128) 특허권자는 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다(法 128①). 특허법은 손해액 산정에 관하여 양도수량에 따른 산정(法 128②), 침해자 이익액의 손해액 추정(法 128④), 실시료 상당액(法 128⑤) 등을 두고 있다.

(4) 신용회복청구권(法 131) 법원은 고의나 과실로 특허권을 침해함으로써 특허권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대하여 특허권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 신용회복에 필요한 조치를 명할 수 있다.

(5) 형사상 조치 특허권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하며(法 225①), 이 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(法 225②).

설문 4-2 — 손해배상청구에서 과실의 증명 (5점)

(1) 과실의 추정(法 130) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 **과실이 있는 것으로 추정된다**. 무체재산권인 특허권의 특성상 고의·과실의 증명이 어렵고, 특허발명의 내용이 공개특허공보·등록특허공보·특허등록원부 등으로 공시되었음에도 이를 간과하고 실시하는 것은 침해자의 과실로 볼 수 있으며, 업으로 발명을 하는 자에게 그 기술분야에서 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하기 때문이다(대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272; 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006).

(2) 추정의 복멸 권리자가 침해사실을 알면서 어느 정도 방관하였다거나 침해품으로 지목된 제품이 별도의 산업재산권을 등록받았다는 사정만으로는 추정이 깨지지 않는다. 추정을 복멸하려면 i) **특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정**이 있다거나, ii) **자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정**이 있다는 것을 침해자가 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006).

(3) 사안의 해결 甲은 丁의 과실을 따로 증명할 필요가 없고, 침해의 사실만 증명하면 丁의 과실은 추정된다. 丁이 책임을 면하려면 위 i)·ii)의 사정을 스스로 주장·증명하여야 한다. 더욱이 丁은 甲의 백신을 **복제**하여 시판하였으므로 고의까지 인정될 여지가 크다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2006후138	2007-08-24	1-1 사후적 고찰 금지
2007후3660	2009-11-12	1-1 사후적 고찰 금지
2005후1936	2006-08-25	1-2 온구기 — 치료방법의 산업상 이용가능성
90후250	1991-03-12	1-2 동물에 한정 명시한 경우
2009다75178	2011-07-28	설문2 공동발명자 판단기준
2000다48272	2003-03-11	4-2 과실 추정의 취지
2003다15006	2006-04-27	4-2 과실 추정의 취지·복멸 요건

교재: 리담특허법 제25판 — 산업상 이용가능성과 의료행위(335~339), 신규성(346~348), 진보성 판단방법(403~404), 공동발명(157), 권리의 귀속(555~556), 특허권의 이전청구(831~832), 과실의 추정(1716), 침해 구제수단(50, 1645~1646).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제29·30·32·33·37·38·44·99의2·103의2·126·128·130·131·133·225조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 산업상 이용가능성과 의료행위(335~339), 신규성(346~348), 진보성 판단방법(403~404), 발명자·공동발명(157), 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속(555~556), 특허권의 이전청구(831~832), 과실의 추정(1716), 침해 구제수단(50, 1645~1646). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 13

제13회 변호사시험 · 특허법

2024년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 3개

문 제

甲은 속도를 조절하는 자동변속장치가 장착된 자전거를 개발하여 특허등록을 받았다. 위 자전거 발명의 구성요소는 ‘자전거의 방향을 조향할 수 있는 핸들(A), 자전거를 이동할 수 있게 하는 2개의 바퀴(B), 위 바퀴를 구동하는 페달(C), 페달과 바퀴를 연결하는 체인(D)과 바퀴의 속도를 조절할 수 있는 자동변속장치(E)’이다(A+B+C+D+E, 이하 이를 ‘특허발명’이라 한다).

乙은 甲과 위 특허발명 제품을 생산·판매할 수 있는 전용실시권 설정계약을 체결하였지만, 전용실시권의 효력발생요건으로서 특허법 제101조 제1항 제2호에 정해진 특허원부에 전용실시권 설정등록을 하지 아니한 채, 위 특허발명을 실시하여 특허발명 제품을 생산·판매하고 있다.

丙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 A, B, C, D를 포함하나, 구성요소 E를 포함하지 않는 자전거(A+B+C+D, 이하 이를 ‘丙의 자전거’라 한다)를 생산·판매하고 있다.

丁은 甲의 특허발명의 구성요소 중 자동변속장치(E) 대신에 수동으로 변속을 하여야 하는 수동변속장치(E')가 장착된 자전거(A+B+C+D+E', 이하 이를 ‘丁의 자전거’라 한다)를 생산·판매하고 있다.

1. 특허권자 甲이 丙에 대하여 특허권침해를 주장하고자 한다. 구성요건완비의 원칙(All Elements Rule)을 적용하여 甲의 주장이 타당한지를 검토하시오. (30점)
2. 乙은 丙의 자전거 생산·판매 행위가 자신의 전용실시권을 침해하는 행위라고 생각하고 丙에 대하여 특허법 제126조에 규정된 전용실시권침해금지청구의 소를 제기하려고 한다. 이 경우 전용실시권 설정등록을 하지 않은 乙이 이러한 소송을 제기했을 때 자신의 전용실시권이 침해당했다는 주장이 소송에서 인용될 수 있는지를 검토하시오. (20점)
3. 甲은 자신의 특허발명과 丁의 자전거를 비교할 때, i) 두 물품이 본질적인 차이가 없어서 과제의 해결원리가 동일하고, ii) 자신의 특허발명의 필수적 구성요소인 자동변속장치(E)와 丁의 자전거에 장착된 수동변속장치(E')가 상호 치환가능성이 있을 뿐만 아니라 丁의 자전거가 자신의 특허발명과 다른 구성요소를 가지고 있더라도 그 구성요소는 자신의 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 기능을 수행하여 동일한 작용효과를 나타내고 있으며, iii) 자동변속장치(E)를 수동변속장치(E')로 변경하는 것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도의 기술수준이라고 주장하고 있다. 이 주장을 바탕으로 균등침해 이론을 적용하여 甲의 丁에 대한 특허권침해금지청구의 타당성을 검토하시오. (30점)

해 설

배점 80점 · 설문 3개(30·20·30). 문제 원문은 자료집(../변호사시험-지적재산권법-기출자료집.md) 참조.

사실관계 요지 — 특허발명은 핸들(A)+바퀴(B)+페달(C)+체인(D)+자동변속장치(E). 乙은 전용실시권 설정 계약을 맺었으나 **설정등록을 하지 않았다**. 丙은 **A+B+C+D**(E 결여)를, 丁은 **A+B+C+D+E'**(E 대신 수동변속장치)를 생산·판매한다.

설문 1 — 구성요소완비의 원칙과 甲의 침해 주장 (30점)

묻는 것: 구성요소완비의 원칙을 적용할 때, 甲의 丙에 대한 침해 주장이 타당한지.

1. 특허권 침해와 보호범위

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 업으로 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하면 침해가 성립한다. 특허발명의 보호범위는 **청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다**(法 97). 따라서 丙의 자전거가 특허발명의 보호범위에 속하는지가 선결문제이다.

2. 구성요소완비의 원칙

(1) 의의 「구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)」이란 **청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다**는 원칙이다. 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 그 각 구성요소가 **유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상**이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 확인대상발명이 청구항에 기재된 필수적 구성요소 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 등).

또한 **청구범위에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하므로**, 그중 일부를 권리행사 단계에서 비교적 중요하지 아니한 사항이라 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용되지 않는다(대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123; 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553). 이는 청구범위 해석에서 출원경과에 나타난 출원인의 의사를 참작하더라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181).

(2) 근거 이 원칙은 청구범위의 해석원리로서 **주변한정주의**의 해석방법이다. 주변한정주의 아래에서는 권리범위의 특징은 물론 구성요소의 선정까지 특허권자가 책임지므로, 스스로 선정한 구성요소가 상대 물건에 존재하지 않는 이상 그 실시자에게 침해책임을 지울 수 없다.

(3) 구체적 내용

- **부가의 원칙:** 청구항에 기재된 구성요소를 모두 포함하는 한 다른 구성요소를 더 포함하더라도 여전히 보호범위에 속한다. 「A+B+C」인 특허발명에 대하여 제3자가 「A+B+C+D」를 실시하는 경우가 이에 해당한다.

- **생략의 원칙**: 청구항의 구성요소 중 적어도 어느 하나가 생략되거나 다른 것으로 대체 되어 있으면 보호범위에 속한다고 할 수 없다. 「A+B+C」인 특허발명에 대하여 제3자가 「A+B」를 실시하는 경우가 이에 해당한다.

3. 사안의 해결

특허발명의 구성요소는 **A+B+C+D+E**이고, 이들은 모두 청구범위에 기재된 이상 필수적 구성요소이다. 반면 丙의 자전거는 **A+B+C+D**로서 **자동변속장치(E)**를 결여하고 있다.

이는 생략의 원칙이 적용되는 전형적인 경우로서, 丙의 자전거는 특허발명의 필수적 구성요소 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 것이므로 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다. E가 특허발명에서 차지하는 비중이 상대적으로 작다고 보아 이를 무시하는 해석은 청구범위의 사후적 확장에 해당하여 허용되지 않는다.

결론: 丙의 자전거는 특허발명의 보호범위에 속하지 않으므로 침해가 성립하지 않는다. **甲의 주장은 타당하지 않다.**

설문 2 — 설정등록을 하지 않은 전용실시권자의 침해금지청구 (20점)

묻는 것: 전용실시권 설정등록을 하지 않은 乙이 法 126의 전용실시권침해금지청구의 소를 제기한 경우, 전용실시권이 침해당했다는 주장이 인용될 수 있는지.

1. 침해금지청구권의 주체

특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있고(法 100①), 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 **설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다**(法 100②). 이처럼 전용실시권은 물권적 성질을 가지므로, 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자를 **특허권자 또는 전용실시권자**로 정하고 있다(法 126①). 따라서 乙이 전용실시권자의 지위에 있는지가 문제 된다.

2. 전용실시권 설정등록의 효력

(1) 등록이 효력발생요건이다 전용실시권의 **설정·이전**(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외)·**변경·소멸**(혼동에 의한 경우는 제외) 또는 처분의 제한은 **등록하여야만 효력이 발생한다**(法 101①Ⅱ). 특허권의 이전·포기에 의한 소멸·처분의 제한(法 101①Ⅰ), 질권의 설정 등(法 101①Ⅲ)도 같다.

이 점에서 전용실시권은 **통상실시권과 구별된다**. 통상실시권은 등록이 **대항요건**에 그치는 데 비하여, 전용실시권은 등록이 **효력발생요건**이다.

(2) 등록 전 계약의 효력 전용실시권은 등록이 효력발생요건이므로, 특허권자가 등록에 협조하지 아니하는 경우 계약서에 명시되어 있지 않더라도 전용실시권자는 특허권자에 대하여 **등록청구권**을 행사할

수 있다고 해석된다. 즉 설정계약 자체는 당사자 사이에서 효력을 가지지만, 그것만으로 전용실시권이 라는 물권적 권리가 발생하지는 않는다.

3. 사안의 해결

乙은 甲과 전용실시권 설정계약을 체결하였으나 특허원부에 **설정등록을 하지 아니하였다**. 전용실시권 의 설정은 등록하여야만 효력이 발생하므로(法 101①Ⅱ), 乙에게는 아직 **전용실시권이 발생하지 않았 다**. 따라서 乙은 法 126①이 정한 청구권자인 「전용실시권자」에 해당하지 아니하고, **전용실시권이 침해당했다는 주장은 인용될 수 없다**.

다만 乙은 甲에 대하여 설정계약에 기한 등록청구권을 행사하여 설정등록을 마칠 수 있고, 등록을 마치 면 그때부터 전용실시권자로서 침해금지를 청구할 수 있다.

한편 설문 1에서 본 바와 같이 丙의 자전거는 애초에 **특허발명의 보호범위에 속하지 아니하므로**, 乙이 설정등록을 마쳤다고 가정하더라도 丙의 행위를 침해로 볼 수 없다는 점도 함께 지적할 수 있다.

설문 3 — 균등침해와 甲의 丁에 대한 침해금지청구 (30점)

묻는 것: 甲이 주장하는 사정을 바탕으로 균등침해 이론을 적용할 때 丁에 대한 침해금지청구가 타당한 지.

1. 문제의 소재

丁의 자전거는 **A+B+C+D+E'**로서, 특허발명의 필수적 구성요소인 자동변속장치(E)가 수동변속장치 (E')로 **대체**되어 있다. 구성요소완비의 원칙 중 생략의 원칙에 따르면 구성요소가 다른 것으로 대체된 경우 문언상으로는 보호범위에 속하지 않는다. 그러나 문언에 엄격히 구속되면 사소한 변경만 으로 침해를 면하게 되어 특허권 보호가 형해화되므로, 실질적으로 동일한 경우에는 보호범위에 속한다고 보는 **균등론**이 문제 된다.

2. 균등침해의 요건

리담특허법은 균등침해의 요건을 다음 넷으로 든다.

제1요건 — 과제의 해결원리가 동일할 것. 이는 **발명 전체**로서 판단한다. 구성요소별로 판단하면 비본 질적 구성이 다소 바뀐 것만으로 제1요건이 부정되어 균등론의 도입 취지에 반하게 되기 때문이다. 대 법원도 발명의 설명에 기재된 어떤 구성의 기능이 그 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사 상의 핵심에 해당하는지를 기준으로, 구성요소별이 아니라 발명 전체로서 과제의 해결원리를 파악하고 있다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424).

제2요건 — 변경가능성이 있을 것(작용효과가 실질적으로 동일할 것).

제3요건 — 변경용이성이 있을 것(구성의 변경이 자명할 것). 그와 같이 변경하는 것 자체가 통상의 기 술자라면 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도이어야 한다. 그 **판단시점은 침해 시**이며, 이는 균등론에 의

한 발명 보호의 실효성을 높이기 위한 것이다(대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210). 따라서 출원 이후 침해 시까지 공지된 자료도 변경의 용이성 판단에 참작할 수 있다.

제4요건 — 특별한 사정이 없을 것. 「특별한 사정」이란 i) 확인대상발명이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, ii) 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 **의식적으로 제외된 것**에 해당하는 등의 사정을 말한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806). 자유기술의 영역에 속하는 부분이나 출원절차에서 의식적으로 제외된 부분까지 보호범위를 인정하면 제3자에게 불측의 손해를 끼치므로 균등범위에 제한을 둔 것이다. i)을 이유로 하는 항변을 **자유기술의 항변**이라 하고, ii)와 같이 출원절차에서 의식적으로 제외된 것에 균등범위를 인정하지 않는 것을 **출원경과참작의 원칙**이라 한다.

3. 사안의 해결

甲이 주장하는 세 가지 사정은 위 요건에 차례로 대응한다.

甲의 주장	대응 요건
두 물품에 본질적 차이가 없어 과제의 해결원리가 동일하다	제1요건
E와 E'가 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 기능을 수행하여 동일한 작용효과를 나타낸다	제2요건
E를 E'로 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도이다	제3요건

甲의 주장이 그대로 인정된다면 제1요건부터 제3요건까지 모두 충족된다. 제4요건은 소극적 요건으로서, 사안에는 丁의 자전거가 특허발명의 출원 시 공지기술이거나 그로부터 쉽게 발명할 수 있었다는 사정이나, 출원절차에서 수동변속장치가 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다는 사정이 나타나 있지 않다.

결론: 제1요건부터 제3요건이 충족되고 제4요건의 특별한 사정도 인정되지 않는 이상, 丁의 자전거는 특허발명과 **균등한 것으로서 보호범위에 속하고** 丁의 실시는 침해에 해당한다. 따라서 甲의 丁에 대한 침해금지청구는 **타당하다**(法 126①). 다만 제4요건은 丁이 항변으로 주장·증명할 수 있는 사항이므로, 丁이 자유기술의 항변을 하거나 출원경과에서의 의식적 제외를 주장하여 이것이 인정되면 결론이 달라질 수 있다.

인용 근거

판례(네 곳 대조 완료 — cases DB 또는 리답 교재에서 확인)

사건번호	선고일	인용한 곳
99다31513	2001-12-24	설문1 구성요소완비의 원칙
98후2351	2000-11-14	설문1 구성요소완비의 원칙
2004후3553	2005-09-30	설문1 구성요소는 모두 필수적
99후2181	2001-12-24	설문1 출원경과 참작해도 같다
2022다265123	2025-05-15	설문1 보호범위 해석 기준
2017후424	2019-01-31	설문3 제1요건은 발명 전체로 판단
2022후10210	2023-02-02	설문3 제3요건의 판단시점(침해 시)
2007후3806	2009-06-25	설문3 제4요건 특별한 사정

교재: 리담특허법 제25판 — 구성요소완비의 원칙(1553~1556), 균등론의 요건(1570~1581), 등록의 효력(1378~1379), 전용실시권과 통상실시권의 등록효력 대비(1786).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제94·97·100·101·126조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 구성요소완비의 원칙(1553~1556), 균등론의 요건(1570~1581), 전용실시권 등록의 효력(1378~1379, 1786). 인용 사건번호는 네 곳(cases · 하급심 · 리담 교재 · 국가법령정보센터) 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.

CHAPTER 14

제14회 변호사시험 · 특허법

2025년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 4개

문 제

甲은 평소 발명에 대한 관심을 많이 가지던 중, 창의 발명대회 ‘흑백(黑白) 발명가’가 열리는 것을 알게 되었다. 대회 참여를 고민하던 甲은 요리에 관심이 많은 어머니 乙에게 요리 도구에서 불편한 점이 무엇인지 물어보았고, “냄비의 온도가 어느 정도인지 알기가 어려워 냄비 손잡이를 다른 장비 없이 맨손으로 바로 잡아도 되는지가 항상 걱정이다.”라는 말을 들었다. 이에 甲은 냄비 손잡이에 내부 온도를 자동으로 표시해 주는 장치에 대한 발명을 생각해 내고 이를 토대로 발명대회에 나가 우수상을 받았다. 발명대회에서 입상한 발명은 공개가 되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태가 되었다. 이후 甲은 대회 수상에 그치지 않고 실제 특허 출원 및 등록을 받고자 하는 생각을 하게 되었다. 이에 ‘외부에 자동으로 내부 온도를 표시해 주는 냄비 발명(이하 ‘발명 X’라 함)’을 완성하였다.

1. 「특허법」은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며, 2명 이상이 공동으로 발명하였으면 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정한다. 「특허법」에 따르면 甲이 발명자가 될 수 있는지, 아이디어를 제공한 乙도 발명자에 해당하는지에 대하여 설명하십시오. (20점)
2. 甲은 자신이 직접 발명 X에 대한 권리를 가지기보다 관련 분야에서 사업을 하고 있는 삼촌 丙에게 이 권리를 양도하고자 한다. 특허를 받을 수 있는 자에 대해 설명하고 「특허법」 제37조에 따라 발명 X에 대해 甲이 발명 완성과 동시에 가지게 되는 권리의 성질 및 동 법 제38조에 따른 이 권리의 양도 요건에 관해 설명하십시오(甲이 발명 X에 대한 단독 발명자임을 전제로 한다). (20점)
3. 2.와 관련하여 丙이 발명 X에 대해 특허를 출원하게 되면, 甲이 해당 발명을 창의 발명대회에서 공개한 것으로 인해 「특허법」상 신규성 위반 또는 신규성 상실 예외에 해당하게 되는지 설명하십시오. (20점)
4. 丙이 발명 X를 출원하여 특허 등록을 받은 이후, 丁이 ‘외부에 자동으로 내부 온도를 표시해 주는 에어 프라이어 제품(이하 ‘제품 Y’라 함)’을 시판하였다. 제품 Y에는 발명 X의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 그대로 포함되어 있어 丙의 특허권을 침해하였다. 丙이 丁에 대하여 어떠한 조치를 취할 수 있는지 설명하십시오. (20점)

해 설

배점 80점 · 설문 4개(각 20점). 문제 원문은 자료집(../변호사시험-지적재산권법-기출자료집.md) 참조.

설문 1 — 발명자의 확정 (20점)

묻는 것: 甲이 발명자가 될 수 있는지, 아이디어를 제공한 乙도 발명자에 해당하는지.

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속

특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 승계인이 가진다(法 33①본문). 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며(法 33②), 그 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 특허출원을 하여야 한다(法 44). 따라서 乙이 공동발명자에 해당하는지에 따라 출원의 적법 여부가 달라지므로, 발명자의 확정이 선결문제가 된다.

2. 공동발명자의 판단기준

「공동발명」이란 2명 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 함께 완성한 발명을 말한다. 공동발명자가 되기 위해서는 **기술적 사상의 창작에 실질적으로 협력하였다는 객관적 요건**과 **상호 협력하여 발명행위를 수행한다는 주관적 요건**이 필요하다.

판례는 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 보아, 다음과 같이 나눈다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178).

공동발명자에 해당하지 않는 경우

- 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 경우
- 연구자를 일반적으로 관리한 경우
- 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우
- 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 경우

공동발명자에 해당하는 경우

- 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 경우
- 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 경우
- 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우

교재는 발명자에 해당하지 않는 자의 예로 「**희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 아니한 자**」와 「단순후원자·위탁자」, 「단순보조자」를 들고 있다.

3. 사안의 해결

(1) 甲 — 발명자에 해당한다. 甲은 "냄비의 온도를 알기 어렵다"는 문제를 인식하는 데 그치지 않고, **냄비 손잡이에 내부 온도를 자동으로 표시해 주는 장치**라는 구체적인 착상을 스스로 제시하였으며, 이를 토대로 발명 X를 완성하였다. 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상을 제시하고 이를 구체화한 것이므로 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다.

(2) 乙 — 발명자에 해당하지 않는다. 乙이 말한 것은 "냄비의 온도가 어느 정도인지 알기가 어려워 손잡이를 맨손으로 바로 잡아도 되는지 걱정된다"는 불편, 곧 해결되었으면 하는 희망조건에 그친다. 乙은 그 불편을 어떤 수단으로 해결할 것인지에 관하여 아무런 착상을 제공하지 않았다. 이는 위 기준 중 「단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 경우」이자 교재가 드는 「희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 아니한 자」에 해당하므로, 乙은 공동발명자가 아니다.

(3) 결론 발명 X는 甲의 **단독발명**이고, 특허를 받을 수 있는 권리는 甲에게 원시적으로 귀속된다(法 33①본문). 공유가 아니므로 공동출원의무(法 44)도 문제 되지 않는다.

설문 2 — 특허를 받을 수 있는 자, 권리의 성질과 양도 요건 (20점)

묻는 것: 특허를 받을 수 있는 자, 法 37에 따라 甲이 발명 완성과 동시에 가지는 권리의 성질, 法 38에 따른 양도 요건(甲이 단독발명자임을 전제).

1. 특허를 받을 수 있는 자

특허를 받을 수 있는 권리는 **발명자 또는 그 승계인**이 가진다(法 33①본문). 다만 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다(法 33①단서). 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 그 권리를 공유한다(法 33②).

2. 특허를 받을 수 있는 권리의 성질

「특허를 받을 수 있는 권리」란 발명의 완성에 의하여 발생하고 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로, 특허출원에 대한 특허거절결정이 확정되거나 설정등록되기 전까지 인정되는 권리를 말한다. 특허법은 이전(法 37, 38)·수용 및 제한(法 41)·정당한 권리자의 보호(法 34, 35)에 관한 규정을 두면서도 그 성질에 관하여는 명문 규정을 두지 않아 해석에 맡겨져 있다.

- **특허부여 요구권설(공권설)**: 국가에 대하여 특허권의 부여라는 행정처분을 구하는 공법상 청구권이 있다고 본다.
- **발명자권설(사권설)**: 발명자가 발명의 완성과 동시에 출원 전이라도 사용·수익·양도할 수 있는 권리라고 본다.
- **병합설**: 두 측면이 병합된 권리로 본다. **다수설이다**.

발생시점에 관하여는 발명이 완성되면 인정된다는 주관설과 특허요건을 구비함을 전제로 한다는 객관설이 있으나, 특허법이 출원 전 승계(法 38①)를 규정한 점에 비추어 **특허요건의 구비 여부와 별개로 발명의 완성에 의하여 발생**한다고 보는 주관설이 타당하다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 참조).

그 효력은 i) **특허부여 요구권적 효력**(특허출원을 통한 권리부여의 요구, 출원공개에 따른 선출원·공지기술·확대된 선출원의 지위에 의한 타인출원의 등록금지)과 ii) **발명자권적 효력**(일신전속적 인격권적 효력으로서 특허증에 발명자로 게재될 권리, 재산권적 효력으로서 실시와 침해에 대한 보호)으로 나뉜다.

3. 양도의 요건

(1) **이전 가능성(法 37①)** 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다(法 37①). 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다. 이전계약은 **명시적으로는 물론 묵시적으로도** 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705).

(2) **공유인 경우의 제한(法 37③)** 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다. 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력 여하가 다른 공유자의 이해관계에 지대한 영향을 미치기 때문이다.

(3) **출원 전 승계의 대항요건(法 38①)** 특허출원 전에 이루어진 승계는 **그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다**. 출원 전의 이 권리는 공시수단이 없고 무체재화이므로 점유도 있을 수 없어 출원을 대항요건으로 삼은 것이다. 여기서 「제3자」란 승계인의 지위와 **양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람**을 말하며, 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087).

4. 사안의 해결

甲은 발명 X의 단독발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 甲에게 원시적으로 귀속되며(法 33①본문), 그 성질은 병합설에 따라 국가에 대한 특허부여 요구권인 동시에 발명자권으로서의 사권이다. 이 권리는 재산권으로서 이전할 수 있으므로(法 37①) 甲은 丙에게 이를 양도할 수 있다. 甲이 단독발명자인 이상 공유가 아니므로 法 37③의 동의 요건은 문제 되지 않는다. 다만 이 양도는 **출원 전 승계**이므로, 丙이 제3자에게 승계를 주장하려면 **丙이 특허출원을 하여야 한다**(法 38①).

설문 3 — 신규성 위반인지, 공지에외에 해당하는지 (20점)

묻는 것: 丙이 발명 X를 출원할 때, 甲이 발명대회에서 공개한 것이 신규성 위반이 되는지 또는 신규성 상실의 예외에 해당하는지.

1. 신규성 상실

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허를 받을 수 없다 (法 29① I). 사안에서 발명대회에서 입상한 발명은 **공개되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태**가 되었으므로 공지에 해당하고, 그대로라면 발명 X는 신규성이 부정된다.

2. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)

(1) **의의·취지** 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 法 30①각호에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면, 法 29①·②를 적용할 때 그 발명은 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다. 자기 발명의 공개로 출원이 특허를 받지 못하게 되는 것은 가혹하다는 데에 취지가 있다.

(2) 요건

- **주체적 요건**: 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지 등이 되었을 것. 다만 **권리자가 직접 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다**. 제3자가 독자적으로 완성하여 공지시킨 경우에는 적용되지 않는다.
- **객체적 요건**: 法 29①각호의 공지 등에 해당하고 法 30①각호의 사유에 해당할 것. 자기 의사에 의한 공지(法 30① I 본문)와 의사에 반한 공지(法 30① II)가 있으며, 조약·법률에 따라 국내외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외된다(法 30① I 단서).
- **시기적 요건**: **최선의 공지일부터 12개월 이내에 특허출원할 것**.

(3) **절차** 자기 의사에 의하여 공지된 경우 적용받으려는 자는 **특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에** 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 30②). 다만 보완수수료를 납부하면 法 30③이 정한 기간에도 그 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출할 수 있다.

3. 사안의 해결

발명대회에서의 공개는 甲의 의사에 의한 공지로서 法 30① I 본문의 사유에 해당한다. 공개 당시 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 甲이었고 丙은 그 승계인이므로 **주체적 요건은 충족** 된다(권리자가 직접 공개할 것을 요하지 않는다).

따라서 丙이 **공지일로부터 12개월 이내에 출원하면서 法 30②의 취지 기재와 증명서류 제출 절차를 밟으면**(또는 보완수수료를 납부하고 法 30③의 기간에 제출하면) 공지예외가 적용되어, 그 공개는 法 29①을 적용할 때 공지된 것으로 보지 않으므로 신규성이 부정되지 않는다.

반대로 **12개월을 넘겨 출원하거나 위 절차를 밟지 않으면** 공지예외를 적용받을 수 없고, 발명대회에서의 공개로 인하여 발명 X는 **法 29① I의 신규성 상실**에 해당하게 된다.

설문 4 — 침해에 대하여 취할 수 있는 조치 (20점)

묻는 것: 제품 Y가 발명 X의 특허권을 침해한 경우 丙이 丁에 대하여 취할 수 있는 조치.

사안은 제품 Y에 발명 X의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 **그대로 포함되어** 있어 침해가 성립함을 전제하고 있으므로, 침해 성립 여부가 아니라 구제수단을 답하면 된다.

1. 민사상 조치

(1) **침해금지 및 예방청구권(法 126①)** 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 특허권은 물권에 준하는 권리이므로 그 지배상태가 침해된 때에 물권적 청구권과 같은 권리가 인정되는 것이다. 이 청구권은 **현재 또는 장래의 침해**에 대하여 행사하는 점에서 과거의 침해에 대한 손해배상·부당이득반환 청구와 구별되며, 침해에 대한 가장 유효하고 직접적인 구제수단이다. 다만 특허권의 존속기간이 만료된 후에는 행사할 수 없다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876).

(2) **폐기·제거 등 청구(法 126②)** 위 청구를 할 때에는 **침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위**를 함께 청구할 수 있다. 사안에서 丙은 제품 Y의 폐기와 그 생산설비의 제거를 청구할 수 있다.

(3) **손해배상청구권(法 128①)** 특허권자는 **고의 또는 과실로** 특허권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. 특허법은 손해액의 산정에 관하여 양도수량에 따른 산정(法 128②), 침해자 이익액의 손해액 추정(法 128④), 실시료 상당액(法 128⑤) 등의 규정을 두고 있다.

(4) **신용회복청구권(法 131)** 법원은 고의나 과실로 특허권을 침해함으로써 특허권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대하여, 특허권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복에 필요한 조치를 명할 수 있다.

2. 형사상 조치

특허권을 침해한 자는 **7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금**에 처한다(法 225①). 이 죄는 **피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다**(法 225②). 형사책임은 고의가 있는 경우에 한하여 물을 수 있다.

3. 사안의 해결

丙은 丁에 대하여 i) 제품 Y의 생산·판매 금지 및 예방청구(法 126①)와 함께 제품 Y의 폐기, 생산설비의 제거를 청구할 수 있고(法 126②), ii) 丁의 고의 또는 과실을 요건으로 손해배상을 청구할 수 있으며(法 128), iii) 업무상 신용이 훼손된 경우 신용회복에 필요한 조치를 청구할 수 있다(法 131). 나아가 丁에게 고의가 있는 경우 iv) 침해죄로 형사책임을 물을 수 있다(法 225).

4. 심판절차 — 적극적 권리범위확인심판(法 135)

민·형사 조치와 별도로, 丙은 특허심판원에 **적극적 권리범위확인심판**을 청구할 수 있다. 권리범위확인심판은 **확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지를 확인** 하는 절차이고, 특허권자 또는 전용실시권자가 상대방의 실시발명이 자기 권리범위에 **속한다는** 확인을 구하는 것이 적극적 권리범위확인심판이다. 심판청구서에는 **특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면**을 첨부하여야 한다(法 140③).

다만 그 심결은 침해소송에서 **유력한 증거로 활용될 수 있으나 법원을 기속하지 못하므로**, 침해를 실제로 멈추게 하고 손해를 전보받으려면 위 민사상 청구가 본체가 된다.

이 항목은 처음 작성할 때 「보강 검토 필요」로 남겨 두었던 것이다(교재의 구체수단 개관은 法 126·128·131·225만 든다). 이후 제7회 해설을 쓰면서 권리범위확인심판의 절차·심리 절차(2163~2164)를 통독하여, 교재가 **특허권자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판**을 전제로 서술하고 있음을 확인하고 보강했다. 자세한 내용은 제7회 해설 설문3-나 참조.

인용 근거

판례(전부 cases DB 대조 완료)

사건번호	선고일	인용한 곳
2009다75178	2011-07-28	설문1 공동발명자 판단기준
2009후2463	2011-09-29	설문2 권리의 발생시점(주관설)
2011다67705	2012-12-27	설문2 이전계약의 묵시적 성립
2020후10087	2020-05-14	설문2 法 38①의 제3자
2007다45876	2009-10-15	설문4 존속기간 만료 후 금지청구

교재: 리담특허법 제25판 — 공동발명(157~158), 특허를 받을 수 있는 권리(554~556), 이전·승계(564~569), 공지의예외(788~799), 침해금지청구권(1645~1646), 구제수단 개관(50).

조문: 특허법(2025. 11. 11. 시행) 제33·37·38·29·30·44·126·128·131·225조 — 국가법령정보센터 현행 조문 대조.

집필 근거 — - 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따라 썼습니다. 검색으로 나온 조각만 보고 요건 목록을 구성하지 않았습니다. - 인용한 사건번호는 모두 cases DB에서 실재와 취지를 확인했습니다(6건 전부). 확인되지 않은 번호는 쓰지 않았습니다. - 현행법 기준입니다(조문은 2025. 11. 11. 시행 특허법).

CHAPTER 15

제15회 변호사시험 · 특허법

2026년 시행 · 제1문 · 배점 80점 · 설문 4개

문 제

甲은 스마트폰 케이스를 제작하여 판매하는 업종을 영위하는 개인사업체를 운영하고 있었다. 당시 지갑(A)과 스마트폰 케이스(B)는 각각 공지되어 있었다. 甲은 자석을 이용하여 스마트폰 케이스와 지갑을 부착시키는 경우 사용자가 이를 용이하게 탈부착하고 관리할 수 있다는 점에 착안하여 자석형 스마트폰 케이스 지갑을 발명하고자 하였다. 다만 자석을 이용하여 스마트폰 케이스와 지갑을 결합시킨 후 이에 스마트폰을 보관하는 경우 스마트폰의 통신 기능이 저하되는 문제가 있었고, 위와 같은 기술적인 문제로 인하여 자석형 스마트폰 케이스 지갑을 제작하는 것은 불가능하다고 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람들 사이에서 일반적으로 인식되고 있던 상황이었다.

甲은 자석을 이용하여 스마트폰 케이스와 지갑을 결합한 스마트폰 케이스 지갑에 스마트폰을 보관하더라도 스마트폰의 통신 기능이 저하되지 않고 유지되는 기술을 개발하기 위하여 연구하였고, 결국 이러한 목적을 달성할 수 있는 자성(磁性) 스마트폰 케이스 지갑을 발명하였다. 甲은 위와 같은 기술이 구현된 발명(A+B+C)에 대하여 특허출원을 한 다음 그 발명의 구성요소로 이루어진 자성 스마트폰 케이스 지갑을 시장에 출시하였는데, 이용자들의 호응을 얻어 상업적 성공(commercial success)을 크게 거두었다.

위와 같은 사실관계에 기초하여 아래 각 사항에 대하여 논의하시오.

1. 甲의 위 발명(A+B+C)이 「특허법」 제29조 제1항에 규정된 신규성 요건을 충족하는지 검토하시오. (25점)
2. 甲의 위 발명(A+B+C)이 「특허법」 제29조 제2항에 규정된 진보성 요건을 충족하는지 검토하시오. (25점)
3. 2.에 따른 진보성 충족 여부를 판단함에 있어서 甲이 시장에 출시한 제품이 ‘상업적 성공’을 이루었다는 사실이 고려될 수 있는지 검토하시오. (10점)
4. 甲이 위 발명(A+B+C)에 대하여 특허권 설정등록을 받았다고 가정하자. 乙이 그 후 甲으로부터 허락을 받지 않고 위 발명과 동일한 구성요소(A+B+C)로 이루어진 제품을 제조·판매하고 있다면, 甲이 乙에 대하여 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있는지 검토하시오. (20점)

해 설

배점 80점 · 설문 4개(25 · 25 · 10 · 20). 문제 원문은 자료집 참조.

사실관계 요지 — 스마트폰 케이스 판매업을 하는 甲이 자석으로 **지갑(A)**과 **스마트폰 케이스(B)**를 부착시키는 착상을 하였다. **A와 B는 각각 공지되어 있었으나**, 자석으로 결합하면 **스마트폰의 통신 기능이 저하되는 문제가 있어 「자석형 스마트폰 케이스 지갑을 제작하는 것은 불가능하다」**고 통상의 기술자들 사이에서 **일반적으로 인식되고 있었다**. 甲은 통신 기능이 유지되는 기술을 개발하여 **A+B+C**를 출원하고 제품을 출시하여 **상업적 성공**을 크게 거두었다.

이 문제의 설계 — 사실관계에 사실상 정답이 숨어져 있습니다. 「**각각 공지되어 있었다**」는 설문 1(하나의 공지기술과만 대비)을, 「**제작하는 것은 불가능하다고 ... 일반적으로 인식되고 있었다**」는 설문 2(기술적 편견)를, 「**상업적 성공**」은 설문 3을 각각 겨냥한 문구입니다. 결론은 셋 다 **甲에게 유리한 쪽**이고, 채점은 **결론이 아니라 법리를 얼마나 정확히 세워 포섭했는지**로 갑니다. 25 · 25점짜리 설문의 결론이 한 줄로 나온다고 해서 짧게 쓰면 안 되는 문제입니다.

설문 1 — 신규성 요건의 충족 여부 (25점)

I. 신규성의 의의와 취지

「**발명의 신규성**」이란 발명의 내용이 **사회일반에 아직 알려지지 아니한 발명으로서 객관적 창작성이 있는 것**을 말한다. 특허법 제29조제1항은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 i) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **공지되었거나 공연히 실시된 발명**, ii) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명**을 제외하고는 특허를 받을 수 있다고 하여 신규성 상실사유를 규정한다.

특허법은 i) 신규한 발명을 공개한 자에게만 **공개의 대가**로 특허권을 부여하고, ii) 공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위하여 신규성을 특허요건으로 삼는다. 다만 **신규성 상실사유를 제한할 목적으로** 규정하여, 열거된 사유에 해당하지 아니하면 신규성이 상실되지 않은 것으로 봄으로써 객관성을 확보하고 있다.

II. 신규성 상실사유 (法 29①)

- **공지(法 29① I 전문)** — 불특정인이 널리 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것. 여기서 「불특정인」이란 비밀유지의무가 없는 자를 말한다.
- **공연실시(法 29① I 후문)** — 실시에 의하여 발명이 불특정인에게 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것. 「공연」이란 발명의 주요부에 대한 비밀상태가 해제된 것이다.
- **반포된 간행물에 게재(法 29① II 전문)** — 「반포」란 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여 있는 것이고, 「게재」는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도여야 한다.
- **전기통신회선을 통한 공중의 이용가능(法 29① II 후문).**

사안에서 **지갑(A)과 스마트폰 케이스(B)는 각각 공지되어 있었으므로 A와 B는 각각 위 공지기술에 해당한다.**

Ⅲ. 신규성의 판단 (★ 이 설문의 골격)

1. 판단의 대상 — 청구항에 기재된 발명 전체

신규성은 **청구범위의 청구항에 기재된 발명**을 공지기술과 대비하여 판단한다. 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 **각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상**이 판단의 단위이지, 각 구성요소가 독립하여 판단대상이 되는 것이 아니다.

따라서 구성요소의 일부가 공지라는 사정만으로 청구항에 기재된 발명의 신규성이 부정되지 않는다. 이 점을 명확히 세워 두지 않으면 "A도 공지, B도 공지이니 신규성이 없다"는 잘못된 결론으로 흐른다.

2. 공지기술의 수 — 단일 인용의 원칙 (★★)

신규성 판단 시에는 **하나의 공지기술과 대비하여야 하며, 복수의 공지기술을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비하여서는 아니 된다.** 이를 「Single Source Anticipation Rule」이라 하며, 출원기술의 신규성을 상실시키려면 **하나의 공지기술에 출원기술의 모든 요소가 명시적으로 또는 본래적으로 포함되어 있어야 한다는 의미이다.** 복수의 공지기술의 조합에 의한 판단은 **진보성의 문제이지 신규성의 문제가 아니다.**

3. 시기적·지역적 기준

「**특허출원 전**」을 기준으로 하며, 이는 「특허출원일 전」과 달라 출원일과 공개일이 **같은 날인** 경우에도 시·분·초를 따져 적용된다(시각주의). 지역적으로는 **국내 또는 국외**를 기준으로 한다(국제주의).

4. 판단방법 — 동일성

청구항의 구성과 공지기술을 대비하여 **구성요소가 동일한가**에 의하여 판단하고 발명의 효과도 참작하되, 구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 **주지관용기술의 부가·삭제·변경으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 동일성이 있다고 보아야 한다**(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472).

Ⅳ. 사안의 해결

1. 공지기술 A와 각각 대비

지갑(A)은 甲의 발명 A+B+C 중 **한 구성요소에 불과하다.** A에는 스마트폰 케이스(B)도, 통신 기능을 유지시키는 기술(C)도 포함되어 있지 않다. **동일성이 인정되지 않는다.**

2. 공지기술 B와 각각 대비

스마트폰 케이스(B) 역시 마찬가지로 A와 C를 포함하지 않는다. **동일성이 인정되지 않는다.**

3. A와 B를 조합하여 대비할 수 있는지

할 수 없다. 앞서 본 단일 인용의 원칙상 신규성 판단에서 복수의 공지기술을 조합하는 것은 허용되지 않는다. 설령 조합이 허용된다고 가정하더라도, **A+B에는 C가 없다.** 통신 기능 저하 문제를 해결하는 기술 C가 甲의 출원 전에 공지되었다는 사정은 사실관계에 나타나 있지 않으며, 오히려 **그러한 제작은 불가능하다고 인식되고 있었다**는 것이므로 C가 공지기술에 포함되어 있었다고 볼 수 없다.

4. 차이가 미세한 차이에 불과한지

C는 자석 결합 시 통신 기능이 저하되던 문제를 해소하는 구성으로서, 그 부가로 인하여 **종래 불가능하다고 인식되던 제품을 구현할 수 있게 되었다.** 이는 주지관용기술의 단순한 부가로서 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이가 아니다.

V. 결론

甲의 발명(A+B+C)은 특허법 제29조제1항의 신규성 요건을 충족한다.

설문 2 — 진보성 요건의 충족 여부 (25점)

I. 진보성의 의의와 취지

「발명의 진보성」이란 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제29조 제1항 각 호의 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것을 말한다(法 29②). 진보성 없는 발명에 특허를 허여하면 i) 특허권의 난립으로 분쟁을 유발할 뿐 아니라 ii) 창의적인 발명보다 남의 발명을 모방하는 경향을 조장하여 발명의 질을 떨어뜨림으로써 오히려 산업발전을 저해하므로, **공지기술보다 비약적이고 누진적인 발명에 대해서만** 특허를 허여하기 위한 요건이다.

II. 판단기준

- **주체적 기준** — 심사관·심판관·법관이 **통상의 기술자의 입장에서** 판단한다. 「통상의 기술자」란 출원 시 그 기술분야의 **기술상식을 보유하고** 통상의 수단·능력을 자유롭게 구사할 수 있으며 출원 시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수할 수 있는 자로 가정한 **특허법상 상상의 인물**이다.
- **객체적 기준** — 청구항에 기재된 발명을 공지기술과 대비하며, **신규성과 달리 둘 이상의 인용대상을 상호 조합**할 수 있다. 조합의 용이 여부는 i) 통상의 기술자가 결합할 가능성, ii) 인용대상의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지, iii) 결합을 관련지을 만한 합리적 근거가 있는지를 고려한다.
- **시기적 기준** — 특허출원 시. **지역적 기준** — 국내 또는 국외(국제주의).

III. 판단방법

가장 가까운 인용대상(주선행발명)을 선택하여 청구항 발명과 대비해 차이점을 파악한 뒤, 그 차이에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지를 다른 인용대상·기술상식·경험칙에 의하여 판단한다. 구체적

으로는 **구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작**하여 종합 판단한다. 대법원도 **구성의 차이와 작용효과를 고려하여 창작의 난이도를 판단**하고 있다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

1. 구성의 곤란성

통상의 기술자가 공지기술로부터 i) **동기 유발**에 의하여 또는 ii) **통상의 창작능력 발휘**를 통하여 청구항 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지의 기준이다. 동기 유발의 유형으로는 공지기술에 시사가 있는 경우, 과제가 공통되는 경우, 기능·작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우가 있다. 통상의 창작능력 발휘의 유형으로는 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화, 균등물에 의한 치환, **기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**, 단순한 용도의 변경이 있다.

2. 효과의 현저성

그 발명으로부터 초래되는 효과가 출원 당시의 기술수준으로 보아 **예측할 수 없는 유리한 효과**인지의 기준이다. 유리한 효과란 i) 인용대상의 효과와 **성질을 달리하는 이질적 효과**나 ii) 성질은 동질이나 **현저하게 우수한 효과**를 말한다. 현저한 효과는 **구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료**가 되며, 구성의 곤란성 판단이 불분명하더라도 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 다만 **구성의 곤란성을 따져보지 않고 효과의 현저성만으로 진보성을 판단해서는 안 된다**(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609).

3. 사후적 고찰의 금지 (★)

진보성 판단은 객관적 타당성에 의하여야 하고 **사후적 고찰(ex post facto)**을 하여서는 아니 된다. 통상의 기술자로서 해당 특허의 이론을 알고 난 뒤에는 공지기술로부터 그 해결을 쉽게 이끌어낼 수 있는 경우가 극히 많기 때문이다. 따라서 **출원 전의 상태로 돌아가 그 특허의 지식을 알지 못한다는 상태에서 판단하여야 한다**(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660).

IV. 사안의 해결

1. 대비 — 차이점의 확정

공지기술은 지갑(A)과 스마트폰 케이스(B)이고, 甲의 발명은 A+B+C이다. 차이점은 i) **A와 B를 자석으로 결합하였다는 점**과 ii) **결합 상태에서도 통신 기능이 유지되도록 하는 구성 C**이다.

2. 구성의 곤란성 — 기술적 편견 (★★ 이 설문의 핵심)

A와 B가 각각 공지이고 두 물건을 자석으로 붙인다는 착상 자체는 단순해 보인다. 그러나 **사실관계는 그 반대를 말하고 있다.**

자석을 이용하여 스마트폰 케이스와 지갑을 결합시킨 후 이에 스마트폰을 보관하는 경우 스마트폰의 통신 기능이 저하되는 문제가 있었고, 위와 같은 기술적인 문제로 인하여 **자석형 스마트폰 케이스 지갑을 제작하는 것은 불가능하다고 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람들 사이에서 일반적으로 인식되고 있었다.**

이는 통상의 기술자가 A와 B를 결합하려는 시도 자체를 단념하고 있었다는 뜻이다. 곧 공지기술은 결합의 동기를 제공하기는커녕 오히려 결합을 저해하고 있었다. 교재는 진보성 긍정의 참고자료로 「발명이 그 기술분야에서 특정 기술과제에 관한 연구 및 개발을 방해하는 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용하여 그 기술과제를 해결한 경우」를 들고 있는데, 사안이 바로 그 전형이다.

나아가 甲이 채용한 구성 C는 그 기술적 장애를 해소하기 위하여 별도의 연구를 거쳐 개발한 것으로서, 적합한 재료의 선택이나 단순한 설계변경 등 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다고 할 수 없다. 구성의 곤란성이 인정된다.

3. 효과의 현저성

甲의 발명은 자석에 의한 용이한 탈부착과 관리라는 편의를 제공하면서도 통신 기능의 저하를 일으키지 않는다. 이는 종래 양립할 수 없다고 인식되던 두 가지를 동시에 달성한 것으로서, 출원 당시의 기술수준에서 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 효과에 해당한다. 효과의 현저성이 인정되고, 이는 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 된다.

4. 사후적 고찰의 경계

甲의 발명 내용을 알고 난 지금의 시점에서 보면 "지갑과 케이스를 자석으로 붙이는 것뿐"으로 보일 수 있다. 그러나 출원 전의 상태로 돌아가면 그것은 불가능하다고 여겨지던 일이었다. A와 B가 각각 공지라는 사정만으로 결합이 쉬웠다고 판단하는 것은 전형적인 사후적 고찰로서 허용되지 않는다.

V. 결론

甲의 발명(A+B+C)은 특허법 제29조제2항의 진보성 요건을 충족한다.

설문 3 — 상업적 성공의 고려 가부 (10점)

I. 원칙 — 진보성은 구성과 효과로 판단한다

진보성은 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 비교하여 판단함이 원칙이다. 상업적 성공은 청구항에 기재된 발명의 구성 그 자체에 관한 사정이 아니라 시장에서 사후적으로 나타난 사정이므로, 진보성 판단의 본래적 자료가 아니다.

II. 참고적 판단방법으로서의 지위

다만 진보성이 있는지 모호한 경우에는 진보성 긍정의 참고자료가 될 수 있다. 교재가 드는 참고자료는 i) 상업적 성공에 의한 모방품의 발생, 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실, ii) 기술적 효과가 큼에도 오랫동안 해결되지 못하였던 과제의 해결, iii) 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용하여 과제를 해결한 경우, iv) 다른 사람이 해결하려다 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안의 제시, v) 새로운 첨단 기술분야에 속하여 관련 선행기술이 전혀 없는 경우 등이다.

참작의 요건 (★)

상업적 성공이 참작되려면, 그 상업적 성공이 청구항에 기재된 발명의 기술적인 특징에 의한 성공으로서 판매기술·선전광고기술 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장·증명하여야 한다(대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302; 대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817).

Ⅲ. 한계 — 그것만으로 진보성을 인정할 수는 없다 (★★)

참고적 판단방법 자체만으로 진보성이 있는지를 판단해서는 아니 된다. 상업적 성공은 발명품이 가지는 우수성과 아무런 상관 없이 시장의 판매여건, 적극적인 광고 전략, 판매자의 독점적 지위, 제조설비나 관련 작업자의 우수성 등에 의하여 달성될 수도 있기 때문이다.

대법원도 "발명품의 판매가 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터의 호평, 그 밖의 모방품의 출현 등은 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있을지라도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없고, 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 한다"고 판시하였다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546; 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052).

IV. 사안의 해결

- 고려될 수 있다 — 다만 보조적 자료로서만. 甲의 자성 스마트폰 케이스 지갑이 이용자들의 호응을 얻어 크게 성공하였다는 사실은 진보성 긍정의 참고자료가 될 수 있다.
- 참작되려면 甲이 그 성공이 구성 C의 기술적 특징(자석 결합에도 통신 기능이 유지된다는 점)에 의한 것이고, 광고·판매전략 등 기술 외적 요인에 의한 것이 아님을 주장·증명하여야 한다.
- 그 사실만으로 진보성을 인정할 수는 없다. 상업적 성공은 디자인·가격·유통망 등에 의하여도 달성될 수 있기 때문이다.
- 이 사안에서는 결론을 좌우하지 않는다. 앞서 본 것처럼 甲의 발명은 기술적 편견의 극복에 따른 구성의 곤란성과 효과의 현저성만으로 이미 진보성이 인정되므로, 상업적 성공은 「진보성이 모호한 경우」에 동원되는 참고자료로서의 역할에 그친다.

요컨대 상업적 성공은 진보성 판단에서 고려될 수 있으나, 그것은 구성과 효과에 의한 판단을 보강하는 자료일 뿐 그 판단을 대체하지 못한다.

설문 4 — 침해금지 및 손해배상 청구 (20점)

I. 특허권 침해의 성립

「직접침해」란 특허권의 존속기간 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하는 것을 말한다. 요건별로 본다.

요건	사안
존속기간 중	설정등록을 받은 후이고 존속기간 만료의 사정이 없다 ○
정당한 권원 없음	乙은 甲으로부터 허락을 받지 않았다 ○
업으로서	乙은 제품을 제조·판매하고 있다 ○
특허발명의 실시	물건발명의 실시인 생산·양도에 해당한다(法 2Ⅲ가) ○
보호범위에 속함	A+B+C로 동일하므로 문언침해 ○

「문언침해」란 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우를 말하며, 판단은 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)에 따른다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351). 乙의 제품은 위 발명과 동일한 구성요소(A+B+C)로 이루어져 있으므로 구성요소를 모두 갖추었다. 직접침해가 성립한다.

Ⅱ. 침해금지 및 예방청구 (法 126)

1. 근거와 성질

특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(法 126①). 특허권은 물권에 준하는 권리이므로 그 지배 상태가 침해된 때에는 소유물 방해제거·방해예방청구권과 유사한 물권적 청구권이 인정된다. 이는 현재 또는 장래의 침해에 대한 것으로서, 과거의 침해에 대한 손해배상과 구별되며 침해에 대한 구제수단으로서 가장 유효하고 직접적이다.

2. 요건 — 고의·과실 불요 (★)

침해자의 고의·과실·책임능력은 요구되지 않으며 객관적인 위법요소만 있으면 된다. 이 점이 고의·과실을 요하는 손해배상청구와 다르다. 사안에서 乙이 甲의 특허권의 존재를 몰랐다고 하더라도 금지청구는 인용된다.

3. 폐기·제거청구 (부대청구)

금지청구에 수반하여 i) 침해행위를 조성한 물건의 폐기, ii) 침해행위에 제공된 설비의 제거, iii) 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(法 126②). 다만 이는 단독으로 행사할 수 없고 반드시 침해금지소송과 함께 행사하는 「부대청구」이다.

4. 가처분

본안 확정 전 긴급한 필요가 있으면 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분을 신청할 수 있다. 다만 본안판결과 같은 내용의 부작위 의무를 부담시키는 만족적 가처분이므로 처분의 긴급성(보전의 필요성)에 대한 고도의 소명이 필요하다.

5. 한계

특허권의 존속기간이 만료된 후에는 침해금지청구권을 행사할 수 없다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876).

Ⅲ. 손해배상청구 (法 128)

1. 요건

특허권자는 **고의 또는 과실로** 특허권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法 128①). 요건은 i) 침해자에게 **고의·과실**이 있을 것, ii) **침해행위**가 있을 것, iii) 침해행위로 인해 **손해가 발생**하였을 것, iv) 침해행위와 손해발생 사이에 **인과관계**가 있을 것이다.

2. 과실의 추정 (法 130) (★)

타인의 특허권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(法 130). 무체재산권인 특허권의 특성상 고의·과실의 증명이 어렵고, **특허발명의 내용이 특허공보·특허 등록원부 등에 공시되었음에도 이를 간과하고 실시하는 것은 과실로 볼 수 있으며**, 업으로서 발명을 하는 자에게 그 기술분야에서 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하기 때문이다(대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272; 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006).

추정을 복멸하려면 乙이 i) 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 ii) 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있음을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006). 사안에서 乙은 **甲의 발명과 동일한 구성요소로 이루어진 제품**을 제조·판매하고 있으므로 두 번째 사유를 주장할 여지가 없고, 달리 추정을 복멸할 사정도 보이지 않는다.

3. 손해액의 산정

침해사실과 손해액의 증명이 일반 재산권 침해보다 훨씬 곤란하므로 특허법은 증명책임의 완화 내지 전환을 위한 특별규정을 두고 있다.

- **양도수량에 의한 산정(法 128②)** — 침해자의 양도수량 중 특허권자의 생산가능수량에서 실제 판매수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 **단위수량당 이익액**을 곱한 금액(제1호), 이를 넘는 수량 등에 대해서는 **합리적으로 받을 수 있는 금액**(제2호).
- **침해자 이익액의 손해액 추정(法 128④).**
- **합리적 실시료 상당액(法 128⑤) 및 그 초과액의 청구(法 128⑥).**
- **상당한 손해액의 인정(法 128⑦)** — 손해 발생은 인정되나 손해액 증명이 성질상 극히 곤란한 경우.
- **징벌적 배상(法 128⑧)** — 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

IV. 그 밖의 조치

- **신용회복청구(法 131)** — 고의·과실로 업무상 신용을 떨어뜨린 경우, 손해배상에 갈음하거나 이와 함께 청구할 수 있다.
- **부당이득반환청구** — 고의·과실이 없는 경우에도 가능하다.
- **자료의 제출(法 132)·구체적 행위태양 제시 의무(法 126의2)** — 침해와 손해액의 증명을 위한 절차적 수단이다.
- **형사적으로는 침해죄(法 225①, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금)가 성립할 수 있으며, 반의사불벌죄다(法 225②).**

V. 乙의 대응 가능성과 그 당부

乙은 특허무효심판을 청구하면서 **특허가 무효로 될 것임이 명백하다는 이유로 권리남용의 항변**을 하거나 **자유기술의 항변**을 할 수 있다. 그러나 앞서 본 것처럼 甲의 발명은 신규성과 진보성을 모두 충족하므로 이러한 항변은 받아들여지지 않는다.

VI. 결론

甲은 乙에 대하여 **침해금지(法 126①)와 그에 부대하는 폐기·제거(法 126②)를 청구할 수 있고, 손해배상(法 128①)도 청구할 수 있다.** 금지청구에는 乙의 고의·과실이 필요 없고, 손해배상에 필요한 과실은 제130조에 의하여 추정되며 乙이 이를 복명할 사정도 없다.

출제 포인트 정리

1. **설문 1의 25점은 「단일 인용의 원칙」에서 나온다.** "A도 공지, B도 공지"라는 문구에 끌려 신규성을 부정하면 안 된다. i) 판단대상은 **청구항 전체**이지 개별 구성요소가 아니고, ii) **복수의 공지기술을 조합하여 대비할 수 없으며**, iii) 설령 조합하더라도 **C가 없다.** 이 세 겹을 모두 써야 배점이 채워진다.
2. **설문 2의 축은 「기술적 편견」이다.** 「제작하는 것은 불가능하다고 통상의 기술자들 사이에서 일반적으로 인식되고 있었다」는 문장은 **결합의 동기가 없었음을 넘어 결합이 저해되고 있었음을** 뜻한다. 여기에 **사후적 고찰 금지**를 붙여야 논증이 닫힌다. 지금 보면 쉬워 보이는 것이 출원 당시에는 불가능하다고 여겨졌다는 점이 전부다.
3. **설문 3은 「고려될 수 있다」와 「그것만으로는 안 된다」를 모두 써야 한다.** i) 참고적 판단방법으로서의 지위, ii) **기술적 특징에 의한 성공임을 출원인이 주장·증명해야** 한다는 요건(95후1302·94후1817), iii) 광고·판매전략 등으로도 달성될 수 있으므로 그 자체로 단정할 수 없다는 한계(2004후3546·2006후3052) — 이 3단이 10점의 전부다.
4. **설문 4에서 갈리는 지점은 두 청구의 요건 차이다.** 금지청구는 **고의·과실을 요하지 않고**, 손해배상은 **요하되 제130조로 추정된다.** 폐기·제거가 **부대청구**라는 점, 존속기간 만료 후에는 금지청구를 할 수 없다는 점(2007다45876), 고의적 침해 시 **5배 증액(法 128⑧)**까지 적으면 20점이 완성된다.

집필 근거 — 리담특허법(제25판)의 해당 절을 순서대로 읽고 그 체계를 따랐습니다 — 신규성(347~380), 진보성(388~415), 침해에 대한 민사적 조치(1644~1660), 과실의 추정(1716), 직접침해의 유형(1628~1641). 인용 사건번호는 네 곳 대조를 거쳤고, 조문은 현행 특허법(2025. 11. 11. 시행)과 대조했습니다.